

مفهوم الدولة و العناصر المكونة لها

مقدمة:

نشأت الدولة بعد تطور إجتماعي و سياسي و تاريخي و إقتصادي طويل حيث ينقسم العالم حاليا إلى وحدات إقليمية يطلق عليها اسم " الدولة " والتي يبلغ عددها حوالي 197 دولة، وقد إختلفت وجهات النظر في نشأتها و تكوينها فمن الكتاب من يرى أن هذا التطور منبعه العائلة التي إجتمعت و إتحدت مكونة بذلك القبائل ثم المدينة التي إجتمعت في شكل مدن فكونت الأقاليم (المقاطعات) و أخيرا إجتمعت هذه الأخيرة مشكلة الدولة .

عرفت الدولة عدّة تعاريف من طرف عدد كبير من المختصين، فهناك من يعرفها من زاوية القانون الدستوري وآخر من زاوية القانون الإداري وآخرون من زاوية علم الإجتماع.

أولا- أصل نشأة الدولة: تعددت النظريات التي قيلت بشأن تفسير نشأة الدولة وأساس السلطة السياسية، وتبرير ظاهرة خضوع المحكومين للحكام ونتناول أهم هذه النظريات بإيجاز:

- **النظرية التيقراطية:** هي المذاهب التي يطلق عليها بعض رجال الفقه اسم المذاهب الدينية وهي أقدم الأفكار السياسية وفحواها أن الدولة نظام إلهي (الفراغة في مصر) وأن الحكام هم ظل الله في أرضيه فلا يسألون أمام سواه وعلى المحكومين طاعته.

- **نظرية العائلة:** فحواها أن الدولة قد تطورت من الجماعة البدائية الأولى (العائلة) لتتحد فيما بينها مكونة العشيرة فالقبيلة فالقرى لتتحد هذه الأخيرة مكونة المدينة ويعد أرسطو مؤسس هذه النظرية، فيرى أن الدولة نظام طبيعي ينمو تبعا لسنة التطور.

- **النظرية الديمقراطية:** تقوم هذه النظرية على أساس أن سلطة الدولة مصدرها الشعب أو الجماعة وبذلك لا تكون السلطة الحاكمة مشروعة إلا إذا كانت وليدة الإرادة الحرة للجماعة التي تحكمها. وأساس هذه النظرية فكرة العقد الاجتماعي الذي يرى أن نشأة الدولة تم نتيجة لنوع من التعاقد أو الإتفاق بين أفراد المجتمع الذين كانوا يعيشون حياة الفطرة على إيجاد سلطة عليا في المجتمع تقوم بتحقيق السلام والأمن والعدل بين أفرادها أي الإنتقال إلى

الحياة المدنية، ورغم قدم نظرية العقد الإجتماعي التي تعود إلى العهد اليوناني إلا أنها تبلورت بشكل واضح على يد الفلاسفة الثلاث، هوبز، لوك وروسو.

- **نظرية القوة والغلبة:** ترى هذه النظرية أساس السلطة السياسية لنشأة الدولة إلى القوة والقهر، وهي تنطلق من فكرة غريزة الإنسان في السعي إلى القوة وللرغبة في تأكيد الذات الدولة، مما يؤكد ذلك الحروب التي تنشب بين العشائر والقبائل في المجتمعات البدائية والتي من خلالها استطاع شيوخ القبائل تأسيس سلطتهم وفرضها على القبائل المغلوبة، وقد كانت تلك بداية نشأة الدولة الحديثة.

- **نظرية التطور التاريخي:** ترى هذه النظرية أن الدولة لم تنشأ نتيجة لعامل واحد فهناك عدة عوامل تاريخية، فمنها ماهو ديني وماهو إجتماعي وسياسي وإقتصادي وعائلي ومن مؤيدي هذه النظرية الفقيه دوجي وكثير من الكتاب من العصر الحديث.

ثانيا - تعريف الدولة:

عرف القانون الدولي العام الدولة كما يلي "تلك الوحدة الإجتماعية التي تحكم نفسها حكما ذاتيا كاملا و منه تكون لها القدرة على إنشاء القواعد القانونية الدولية على أساس التراضي القائم بينها".

غير أن التعريف الأمثل للدولة هو "أنها مجموعة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة تحت تنظيم سياسي معين يتيح لبعضهم تولي مسؤولية الحكم". يتضح من خلال هذا التعريف للدولة أننا أمام دولة بالمعنى القانوني، وتوجد الدولة عندما تتوفر ثلاثة عناصر و هي:

- **العنصر البشري: السكان.**
- **العنصر المادي: الإقليم.**
- **العنصر الشكلي السيادة (السلطة السياسية): على الإقليم والمجموعة البشرية (السكان).**

ثالثا: أركان الدولة:

1- السكان:

هم المجموعة البشرية التي تقيم على إقليم الدولة ولا يشترط القانون الدولي عددا محددا من الأفراد لتكوين الدولة، فهناك دول يزيد عدد مواطنيها عن مليار و هناك أخرى

تتشكل من بعض الآلاف، و لا فرق بين الدولتين من الناحية القانونية، و يقسم رجال القانون السكان إلى قسمين: المواطنين و الأجانب.

والوضع الطبيعي أن يكون السكان في دولة معينة مكونين أمة واحدة، ولكن لا يجب أن نخلط بين مفهوم الأمة والشعب والدولة.

- **فالأمة:** عبارة عن مجموعة من الناس الذين يرتبطون فيما بينهم بجامع مشترك أو عدة جوامع كاللغة والأصل المشترك والدين والتاريخ وما إلى ذلك كما ويرتبط هؤلاء الأفراد فيما بينهم بالمصالح المشتركة التي تجمع شملهم، مما يولد لديهم الشعور والرغبة في العيش معا وهي قد تستقر على بقعة أرض متصلة أو منفصلة.

- **أما الشعب:** فهو الركيزة الأولى لوجود الدولة، له عدة أهداف مشروعة يسعى لتحقيقها وللشعب مفهومان إجتماعي و سياسي، فالأول يعني مجموعة من الأفراد الذين يعيشون على إقليم الدولة والذين ينتسبون إليها عن طريق التمتع بجنسيتها ويطلق على هؤلاء بالمواطنين إذا كانوا يعيشون في دولتهم أو رعايا إذا كانوا يعيشون خارجها، أما الثاني فيعني أن كل من ينتمي إلى شعب ما برابطة الجنسية يتمتع بمجموعة من الحقوق السياسية منها على سبيل المثال لا الحصر حق الانتخاب و حق الترشح طالما توفرت الشروط القانونية لذلك، وحرية الرأي والتعبير والحق في تولي الوظائف العامة.

- **أما الدولة:** فهي شعب موحد برابطة قانونية (الجنسية) ورابطة سياسية تنشيء حقوق وواجبات بينها وبين الأفراد الذين ينتمون إليها، وعليه قد يكون عنصر السكان في الدولة جزء من أمة واحدة مثل الأمة العربية الموزعة على عدد من الدول ويقسم رجال القانون السكان إلى:

أ- **المواطنون:** هم الأشخاص المقيمين على إقليم الدولة و يرتبطون بها برابطة قانونية تسمى "الجنسية" وهي تقوم على أساس الحماية من طرف الدولة لمواطنيها والولاء والطاعة من طرف الأفراد لدولتهم و تقوم الدولة بحماية مواطنيها داخل الوطن و خارجه و في هذا الإطار نصت المادتين (26) و (27) من القانون رقم 01-16، المؤرخ في 06 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري لبلادنا على مايلي "الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل إحترام القانون الدولي والإتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة

والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة. " وتتمثل حماية الدولة لمواطنيها داخل إقليمها في المظاهر التالية:

- حمايتهم من أي عدوان خارجي.
 - حماية ممتلكاتهم العقارية و المنقولة.
 - لا يجوز للدولة أن تنفي أبناءها إلى دولة أخرى و لا أن تسلمهم لدولة أخرى لمحاكمتهم.
- ويترتب على الجنسية تمتع المواطن بمجموعة من الحقوق أهمها: الحق في التعليم والعمل والسكن اللائق والمواصلات والصحة العمومية والتنقل بكل حرية داخل التراب الوطني ليلا ونهارا، وتسمى هذه الحقوق بالحقوق العامة، وهناك حقوق أخرى تسمى بالحقوق السياسية والتي تمارسها فئة من المواطنين عندما تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة كالسن والحرية والأهلية وتتمثل هذه الحقوق في حق الترشح للمناصب السياسية وحق التصويت وحق تولي المناصب العليا في القضاء والإدارة وكذا حق تكوين أحزاب سياسية وإنشاء جمعيات وحرية التعبير والإضراب في حدود القانون.

ب- الأجانب:

هم الأشخاص الذين يقيمون على إقليم دولة غير دولتهم و يحملون جنسية غير جنسية تلك الدولة المقيمين فيها، و تتحدد الأوضاع القانونية لهؤلاء من قبل القوانين الوطنية في دولة الإقامة، فمثلا ينص الدستور الجزائري في المادة (81) على مايلي: " يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون."، في الجزائر تنظم وضعية الأجانب فوق إقليمها إستنادا إلى قوانين وطنية وهي ملزمة بالتقيد واحترام قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأجانبو من بين هذه القواعد:

- أن يعامل الأجنبي بصفته إنسانا، فيحترم في شخصه كما تحترم حقوقه المكتسبة في البلد الذي يقيم فيه.

- يجب على الدولة المستقبلية لهؤلاء الأجانب أن تسمح لهم بالإستفادة من مرافقها العمومية كالمستشفيات ووسائل النقل والمحاكم وغيرها، طبقا للشروط الموضوعية، غير أنه يمنع الأجنبي من ممارسة بعض الحقوق السياسية كحق الإنتخاب، و حق الترشح للمناصب النيابية و تولي الوظائف العامة كالوزارة و القضاء و غيرها.

- يرتبط عادة بالأجانب مصطلحان هما، حق اللجوء السياسي و حق الطرد.

- حق اللجوء السياسي:

هو حق يمنحه القانون الدولي للأشخاص الذين تدفعهم أو تضطربهم الظروف الأمنية السيئة في بلادهم إلى الهروب إلى بلدان أخرى طلباً للعافية والأمان وخوفاً من الإضطهاد والموت، وقد نصت على هذا الحق المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء فيها مايلي: " لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الإلتجاء إليها هرباً من الإضطهاد " لا يمكن التذرع بهذه الحقوق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة .

- حق الطرد أو الإبعاد:

هو تصرف تقوم به الدولة إتجاه الأجانب المقيمين في إقليمها ويتمثل في طردهم عندما يصبحون في وضعية تهدد أمن الدولة وسلامتها، وتقوم الدولة بهذا التصرف بكل حرية وليست ملزمة بتقديم أي تبريرات.

2-الإقليم:

الإقليم هو الرقعة الجغرافية التي تمارس الدولة عليها سيادتها ويتواجد بها السكان، وحسب العميد "موريس هوريو" أن " الدولة هي إتحاد ذو قاعدة إقليمية" ولهذا فلا يمكن تصور الدولة بدون وعاء إقليمي مرسوم عبر الحدود، وهذا ما يكون عبر ثلاثة أشكال:

أ- الحدود البرية :

ترسم هذه الحدود بناء على حدود طبيعية (المياه أو خط القمم أو الأنهار و الأودية)، بينما تحدد الحدود الإصطناعية بناء على المعاهدات والإتفاقيات التي تعد من طرف لجان مختصة تنشأ لهذا الغرض.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط القانون الدولي مساحة معينة للإقليم أو أن يكون أجزاء الإقليم متصلة وبالتالي فلا يؤثر زوال أو إنفصال جزء من إقليم الدولة البري في شكلها أوفي أركانها.

ب-الحدود البحرية:

يشمل البحر الذي يمتد على طول سواحل الدولة ابتداء من المياه الداخلية ويسمى (البحر الإقليمي)، وتدخل في الحسابان البحيرات، فتقوم الدولة بممارسة إختصاصها كالذي

تمارسه على إقليمها البري، على مسافة تعتبر إقليما مغمورا يطلق عليه اسم البحر الإقليمي من جهة وأيضا فوق منطقة تسمى " الجوف القاري"، ومسافة البحر الإقليمي هي اثنتا عشر ميلا (12) إنطلاقا من الساحل، لقد أصبحت البلدان وأولها فرنسا تستغل المياه الإقليمية المعترف بها تقليديا مضيعة إلى ذلك مئة وثمانية وثمانون (188) ميلا بحريا من أجل إستغلال البحر الإقليمي من الجانب البيولوجي وغير البيولوجي من الثروات الطبيعية، فأصبح اليوم الإمتداد البحري للسيادة هو 12+188 ميلا، و الجزائر منذ سنة 1963 تأخذ بـ 12 ميلا.

ج - الحدود الجوية:

يتمثل في الفضاء الذي يغطي إقليم الدولة البري و البحري (12) ميلا أو (12 + 188 ميلا) و تمارس الدولة سيادتها على هذا الجزء، و قد بدأ الإهتمام به بعد إختراع الطائرات، و قد تجلّى هذا الإهتمام في إتفاقية باريس 1919، ثم إتفاقية شيكاغو في 07 ديسمبر 1944 التي تسمح للطائرات المدنية أن تحلق في أجواء الدول أثناء السلم. إذن يخضع المجال الجوي لهذه الإتفاقيات الجماعية والإتفاقيات الثنائية التي تبرم بين الدولة بشأن مرور الطائرات عبر إقليمها وعموما فإن الطائرات الحديثة تعبر أجواء الدولة دون ترخيص من سلطات الدولة المعنية.

وفيما يتعلق بتحديد حدود المجال الجوي فإن فقهاء القانون الدولي يحددونها أفقيا تبعا لمساحة الإقليم البري و البحري، أما عموديا ففي إتجاه السماء، رغم الإختلاف بين الفقهاء إلا أن الرأي الغالب أن المجال الجوي الذي يخضع لسيادة الدولة ينتهي عندما تعجز الطائرات العادية عن تجاوز هذا الحد و خارج هذا المجال يعتبر فضاء خارجي.

ملاحظة:

لقد تبنى الدستور الجزائري أحكام القانون الدولي المتعلقة بالإقليم حيث تنص المادة (13) منه على مايلي: " تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، و مجالها الجوي، و على مياهها، كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها".

3- السيادة (السلطة السياسية):

هو عنصر أساسي و قانوني في تكوين الدولة و يعتبرها رجال القانون الدولي صفة أساسية في الدولة وهي المعيار الحاسم للتمييز بين الدولة و الوحدات السياسية الأخرى الموجودة في المجتمع الدولي كالمنظمات الدولية و الدول المشكلة للإتحادات الفيدرالية. "تعرف السيادة بأنها حرية الدولة في ممارسة اختصاصاتها على الإقليم و السكان و التعامل بكل حرية في العلاقات الدولية، ولهذا فإن بعض رجال القانون يساويها بالإستقلال أي قيام علاقة مساوية بين السيادة والإستقلال المطلق".

كان مفهوم السيادة عند ظهوره مفهوما واسعا و مطلقا و لكن مع مرور الزمن عرف تقيدا كبيرا، بحيث أصبحت الدول مقيدة في ممارسة سيادتها بقواعد القانون الدولي العام لأن نمو العلاقات بين الشعوب وتقدم وسائل الإتصال بينها، فرض عليها تغليب المصلحة المشتركة، و من ثمة التخلي عن جزء من سيادتها و لكن مع ظهور العولمة أصبحت سيادة الدول مقيدة أكثر في الجانب الإقتصادي، و لقد أكد ميثاق الأمم المتحدة على سيادة الدول و خاصة المادة (2/8) منه التي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول إحتراما لسيادتها، غير أن المنظمات الدولية و باقي أعضاء المجتمع الدولي أصبحت تطالب بالتدخل في شؤون الدول إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

أ- الشخصية المعنوية:

يقصد بالشخصية المعنوية مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترصد لتحقيق مصالح و أهداف يعجز عنه الفرد أو المال الخاص عن تحقيق ذلك و يصبح هذا الشخص القانوني المعنوي يتمتع بأهلية قانونية تسمح له من إكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات.

* أنواع الشخصية المعنوية:

قسمها الفقه إلى أشخاص معنوية خاصة و عامة:

1- الأشخاص المعنوية الخاصة:

هي التي تخضع لأحكام و قواعد القانون الخاص إلا ماكان منها لصيقا بالشخص الطبيعي كحق الزواج، أما النتائج المترتبة عن الشخص الطبيعي فإنها تنترتب على الشخص المعنوي أيضا.

و نلاحظ أن دلالة الشخصية المعنوية و إن كانت تحتل مكانة في إدارة قواعد القانون الخاص إلا أنها تكتسي أهمية بالغة في دراسة الشخص المعنوي العام.

2- الأشخاص المعنوية العامة:

هم الأشخاص الخاضعون للقانون العام كقاعدة عامة وقد نصت المادة (49) من القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 (القانون المدني) على أن الأشخاص الاعتبارية هي:

- الدولة، الولاية، البلدية.
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- الشركات المدنية والتجارية.
- الجمعيات و المؤسسات.
- الوقف.
- كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون "شخصية قانونية".
- و تنقسم الأشخاص المعنوية العامة إلى نوعين:

أ- الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية:

* **الدولة:** هي أهم الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية على الإطلاق، و فكرة الشخصية المعنوية للدولة خاضعة أساسا لقواعد القانون العام أي تكون حياتها واختصاصاتها على كل أجزاء الإقليم و إن كل الأشخاص المعنوية الأخرى تحت سلطة الدولة.

* **الولاية:** عرفت المادة الأولى (01) من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية كما يلي: "الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة. وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة..... وتحدث بموجب القانون..".

* **البلدية:** لقد عرفت المادة الأولى (01) من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 22 يونيو 2011، المتعلق بالبلدية كما يلي: "البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، و تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، و تحدث بموجب قانون..".

ب- الأشخاص المعنوية العامة المرفقية (المصلحية):

قد يطلق عليها كذلك الهيئات العامة أو المؤسسات الإدارية العامة.

- النتائج المترتبة على منح الشخصية القانونية:

نصت المادة (50) من القانون المدني الجزائري عن الآثار القانونية التي تترتب على منح الشخصية المعنوية، وعليه الشخص المعنوي مهما كان نوعه، خاص أو عام، يتمتع بجميع الحقوق التي يقرها القانون، إلا ما كان منها ملازما للشخص الطبيعي ومن النتائج التي تترتب على منح الشخصية المعنوية:

- ذمة مالية.

- أهلية، في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقرها القانون.

- موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر، يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.

- حق التقاضي.

- نائب يعبر عن إرادتها.

مظاهر إنتهاك السيادة:

يترتب التعدي على دولة ما، فقدان سيادتها أو نقصانها، فتفقد السيادة في حالة الإستعمار و تنقص في حالات الحماية، الإنتداب و الوصاية.

1- الإستعمار:

نقصد هنا الإستعمار المباشر، أي سيطرة دولة بقواتها العسكرية على جميع أجزاء إقليم دولة أخرى، و التصرف في شؤونها الداخلية و الخارجية، أما الحالات التي تؤدي إلى نقصان في سيادة الدولة فهي: الحماية، الإنتداب و الوصاية.

2- الحماية:

يقصد بها قيام دولة قوية بحماية دولة ضعيفة ويتم ذلك إما بناء على معاهدة بين دولتين، الحامية والمحمية كما حدث بين تونس وفرنسا عام 1881 و كذلك المغرب

وفرنسا عام 1912 و إما أن تتم بالقوة، أي تفرض على الدول الضعيفة، كما حدث بالنسبة لمصر سنة 1914 حين فرضت عليها بريطانيا حمايتها، حيث تحافظ الدولة المحمية على تسيير شؤونها الداخلية في حين تتولى الدولة الحامية الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع.

3- الإنتداب:

نظام أقرته عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى لتبرير النظام الإستعماري الذي كان سائدا آنذاك وإعطائه الصيغة القانونية، وقد نصت على هذا النظام المادة (22) من عهد عصبة الأمم. ويقصد بالإنتداب إشراف دولة قوية من الدول الأعضاء في عصبة الأمم على شعب من الشعوب التي كانت تابعة للدولة العثمانية التي كانت مستعمرة من طرف ألمانيا والتي تعتبر في نظر عصبة الأمم غير قادرة على تسيير شؤونها بنفسها، وقد أنشأت عصبة الأمم لجنة خاصة لمراقبة الدول المكلفة بالإنتداب والشعوب الخاضعة لها، وقد ساد هذا النظام مع بداية القرن 20، أي من 1919 إلى غاية إنشاء منظمة الأمم المتحدة 1945، حيث حل محله نظام آخر هو " نظام الوصاية".

4- الوصاية:

جاء بهذا النظام ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 و هدفه وضع الأقاليم غير المستقلة والتي كانت خاضعة للإنتداب تحت إشراف دولة من الدول الكبرى مع خضوعها لمراقبة منظمة الأمم المتحدة، و في هذا الشأن تنص المادة (75) من الميثاق على مايلي "تنشئ الأمم المتحدة تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية، و ذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقيات فردية لاحقة للإشراف عليها و يطلق على هذه الأقاليم بالأقاليم المشمولة بالوصاية"، و الهدف من الوصاية العمل على ترقية أهالي أو سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة، الاجتماع، الاقتصاد، التعليم و العمل على الوصول بها إما إلى الحكم الذاتي أو الإستقلال حسب ما يلائم ظروف كل شعب.

الأنظمة السياسية

مقدمة:

تختلف الأنظمة السياسية في الدول التي تأخذ بالديمقراطية على أساس مبدأ الفصل ما بين السلطات، حيث تقوم على النظام البرلماني أو النظام الرئاسي أو النظام المختلط بينما نجد الدول التي تمزج أو تدمج السلطات تسمى بالنظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية، كما هناك أنظمة إستبدادية والتي تأخذ بالنظام الشمولي ونذكر من بين هذه الأنظمة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أولاً: النظام الرئاسي:

1- مفهوم النظام الرئاسي:

هو نوع من أنظمة الحكم يضع الهيئة التنفيذية بيد رئيس الدولة يعاونه وزراء يعدون بمثابة مستشارين وأحياناً يطلق عليهم إسم سكرتير كما الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ويكون رئيس الدولة هو رئيس الحكومة بالوقت نفسه، ويكون غير مسؤول سياسياً أمام السلطة التشريعية، ويختار رئيس الدولة من قبل الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يعطي البعض تعريف للنظام الرئاسي فيرى أنه النظام الذي ترجح فيه كفة رئيس الدولة في ميزان السلطات. وهناك من عرفه على أنه النظام السياسي الذي يتم فيه إنتخاب رئيس الدولة بصورة مباشرة من قبل أفراد الشعب مباشرة وفي هذا النظام يقوم الرئيس بتعيين مساعدين ووزراء له للقيام بالمهام التنفيذية ويكون الوزراء والمساعدون مسؤولين أمامه حيث يخضع الوزراء خضوعاً تاماً للرئيس وهم مسؤولون أمامه فقط، وهم لا يشكلون مجلس وزراء وبهذا النظام يطبق نظام الفصل بين السلطات الثلاث ولا يكون هناك رئيس للوزراء حيث أن الرئيس نفسه رئيس الوزراء، أي لأنه يجمع بين الدولة و الحكومة ويكون الرئيس أمام البرلمان بمرتبة متساوية معه أمام الجماهير، وهو ممثل لرئاسة الدولة ولرئاسة السلطة التنفيذية معاً، ولا يصلح تطبيق هذا النظام إلا في النظام الجمهوري ولا يصلح في النظام الملكي.

إنّ ذلك النظام الذي تعبر عنه الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم على أساس محورية السلطة التنفيذية في العملية السياسية، ولا سيما في المجال الخارجي يتمتع رئيس

الدولة بسلطات واسعة، مع نوع من التوازن في المجال الداخلي بين سلطة الرئيس وسلطة البرلمان، أي أن هناك رئيسا قويا وبرلمانا قويا يحتاج كلاهما الآخر لأداء عمله.

2- أركان النظام الرئاسي:

يقوم النظام الرئاسي على مجموعة من الأركان والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وهذه السياسة الأخرى وهذه الأسس و المتطلبات هي:

أ- وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:

يقوم النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب، ويجمع بين صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة وقصدا وضعا الدستور الأمريكي مثلا بذلك تحقيق المساواة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فقد ركزوا السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة المنتخب من الشعب، ولذلك أصبح في مركز متعادل مع البرلمان الذي يستمد سلطته من الشعب هو الآخر.

ب- الفصل الجامد للسلطات:

إن توزيع الصلاحيات والإختصاصات في النظام الرئاسي يقوم على أساس فصل مطلق، إذ أن الرئيس والبرلمان مستقلان عن بعضهما البعض، فالبرلمان لا يستطيع مساءلة الرئيس أو وزرائه أو حجب الثقة عن الحكومة الرئاسية، كما أن الرئيس لا يستطيع حل البرلمان، وعلى الطرفين التعايش مع بعضهما مما يوفر الثبات والإستقرار للحكومة الرئاسية.

- الفصل بين الأفراد:

يقصد بفصل الأفراد أن من يتولى منصبا في السلطة التشريعية لا يجوز له أن يتولى منصبا في السلطة التنفيذية، والعكس صحيح وبعبارة أخرى من يشارك في عملية صنع القانون لا يجوز أن يشارك في عملية تنفيذ القانون، وذلك حتى لا يكون هناك تركزا في السلطة.

- الكوابح والتوازنات:

يقصد بذلك أن تمنح كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظم الرئاسية قدرا متساو من السلطة حتى تكبح كلا منهما الأخرى، توازنهما بما يحول دون طغيان أيهما.

ج- إختيار الوزراء: في الانظمة الرئاسية وخصوصا في الولايات المتحدة الامريكية يقوم رئيس الدولة دون تدخل من أحد بتعيين وزرائه أو مساعديه وهو يعينهم كما يحق له إقالتهم دون تدخل من أحد وهكذا ظفرت السلطة التنفيذية متمثلة بشخص رئيس الدولة بصلاحيات واسعة وسلطات عظيمة، ويسيطر الرئيس تماما على وزرائه ويخضعون له ولهم سلطات إستشارية فقط معه.

د- وجود مرونة حزبية: إن النظام الرئاسي يتطلب توافر درجة عالية من المرونة الحزبية، أي عدم التصويت ككتلة حزبية واحدة لأن السلطة التشريعية تمتلك الكثير من السلطات من بينها السلطة المالية، والحكومة لا تنبثق من حزب الأغلبية البرلمانية في النظام الرئاسي.

3- مزايا وعيوب النظام الرئاسي:

أ- مزايا النظام الرئاسي:

- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وللحكومة في نفس الوقت ويتم إنتخابه من قبل الشعب مباشرة ولا توجد علاقة مباشرة رسمية بينه وبين البرلمان وبالتالي لا يعتمد على إرضاء البرلمان في إتخاذ قراراته هذا الفصل بين السلطتين يحمي الشعب حماية كافية من تعسف أي من السلطتين.

- يمكن القول بأن النظام الرئاسي هو أكثر الأنظمة إستقرارا لأسباب عديدة لعل من أهمها أن موعد الإنتخابات ثابت ويحدده القانون، فرييس الجمهورية وأعضاء البرلمان يتم إنتخابهم لفترات زمنية ثابتة، وفي بعض المناصب قد يحدد القانون مدة محددة للبقاء في المنصب.

- تأمين إستقرار الحكومة بغض النظر عن الإتجاهات الحزبية المعارضة.

- إن الرئيس في النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرة و هيبة مهمة لأنه مرشح ومنتخب من الأمة بشكل مباشر.

- إنه نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكاملة والتي يكون فيها مستوى النضوج والوعي السياسيين عاليا.

- لا يوجد رئيس الوزراء في هذا النظام ومجلس الوزراء أو الأمناء كما يطلق عليهم في النظام الأمريكي يختاره رئيس الجمهورية لمساعدته في تنفيذ سياساته، ولا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزاري أو أي منصب وظيفي آخر في الحكومة أو خارجها.

- في هذا النظام يمكن تحقيق التوازن والمراقبة بين السلطات الثلاث بسهولة.

ب- عيوب النظام الرئاسي:

- يلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.

- يرى روسو أن فيه تجزئة للسيادة، ويرى بعض الفقهاء بأن الفصل بين السلطات يؤدي إلى هدم وحدة الدولة.

- يؤدي إلى إستبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئيس سياسيا ودستوريا في الحياة الوطنية وإعادة إنتخابه لأكثر من مرة.

ثانيا: النظام البرلماني:

1- مفهوم النظام البرلماني:

يقوم النظام البرلماني على التوازن والمساواة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويوجد هذا النظام في الأنظمة الملكية والجمهورية.

وقد كانت الدولة الأولى التي عرف فيها هذا النظام البرلماني هي إنجلترا ثم فرنسا (في عهد النظام الملكي 1814 - 1848) ثم بلجيكا عام 1831، أما أول بلد جمهوري أخذ بهذا النظام البرلماني فقد كانت فرنسا في دستور الجمهورية الثالثة عام (1875).

2- أركان النظام البرلماني:

تتلخص الأركان التي يقوم عليها النظام البرلماني فيما يلي:

- عدم مسؤولية رئيس الدولة .
- المسؤولية السياسية الجماعية للحكومة.
- التوازن (التعاون) بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.

أ - عدم مسؤولية رئيس الدولة:

يفترض بالنظام البرلماني وجود سلطة تنفيذية مكونة من عنصرين، رئيس الدولة والحكومة على أن يكون رئيس الدولة مستقلا عن الحكومة وعن البرلمان، والميزة الأساسية لرئيس الدولة أنه غير مسؤول جنائيا ولا سياسيا.

- **عدم المسؤولية السياسية:** يقصد بذلك أن رئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيس الجمهورية غير مسؤول أمام البرلمان عن شؤون الحكم، إنما المسؤولون هم رئيس الحكومة و الوزراء.

و يرى معظم الفقهاء أنه يترتب على إنتقال المسؤولية من رئيس الدولة إلى الحكومة إنتقال السلطة الفعلية إلى الحكومة و بالتالي لا يتدخل رئيس الدولة في الادارة الفعلية لشؤون الحكم إذ لا تعد له سوى مجرد وظائف شرفية لا تتعدى إستقبال الضيوف، و يبررون ذلك بما يلي:

- بالرغم من أن رئيس الدولة له حق تعيين و عزل الوزراء إلا أنه مقيد بإختيارهم من حزب الأغلبية.

- بالرغم من أن رئيس الدولة له حق إصدار مراسيم القوانين في فترة العطلة الصيفية للبرلمان، فإن الذي يتولى إعدادها هو مجلس الوزراء على أن تعرض على البرلمان في أول إنعقاد له لإقرارها أو إلغائها.

- بالرغم من أن رئيس الدولة يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة شكليا إلا أنه من الناحية الواقعية، فإن القيادة يتولاها ضباط سامون.

- يترتب على عدم مسؤولية رئيس الدولة أنه لا يجوز توجيه نقد له بسبب السياسة العامة للحكومة و إنما النقد يوجه إلى الحكومة.

- **عدم المسؤولية الجنائية :**

تختلف بحسب الأحوال:

- إذا كان رئيس الدولة ملكا فالقاعدة في الدساتير الملكية أن " **الملك ذاته مصونة لا تمس** " و معنى ذلك أنه غير مسؤول جنائيا عن تصرفاته سواء كانت متعلقة بمهام وظيفته كالخيانة العظمى أم كانت جرائم عادية كارتكاب جناية قتل فرد أو تزوير أو سرقة أو جنحة (سب و ضرب، قتل خطأ)، و هذه القاعدة وليدة النظام البرلماني الإنجليزي وأصلها قاعدة أخرى هي " **أن الملك لا يخطئ** " .

– أما إذا كان رئيس الدولة رئيس الجمهورية، فإن القاعدة العامة أنه لا يسأل جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها خارج حدود وظيفته، أما الجرائم المتعلقة بوظيفته فهو يسأل عنها جنائيا في بعض الحالات كجريمة الخيانة العظمى.

ب - المسؤولية السياسية الجماعية للحكومة:

يقصد بالمسؤولية السياسية الجماعية أن الحكومة مسؤولة عن تصرفاتها المتعلقة بإدارة شؤون الدولة أمام البرلمان وأن عليها أن تكون حائزة على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان (أو بالأقل أغلبية أعضاء مجلس الوزراء) بحيث يجب عليها أن تقدم إستقالتها إذا فقدت هذه الثقة، و هذه المسؤولية جماعية بمعنى أن الوزراء جماعيا يكونون وحدة يمثلها رئيس الوزراء، فالوزراء مسؤولون بالتضامن عن السياسة العامة للحكومة.

و يعهد رئيس الدولة إلى زعيم الحزب الغالب في البرلمان بتشكيل الحكومة ويقوم هذا الأخير باختيار الوزراء، و من الجميع يتكون مجلس الوزراء و هذا الأخير يعتبر أعلى هيئة في الحكومة، فهو الذي يهيمن على مصالح الدولة و يرسم السياسة العامة من كل نواحي الحياة ثم يقوم كل وزير بتنفيذها في وزارته و مناقشتها بسرية بحيث لا تسجل في محاضر ولا يجوز لأي وزير أن يذيعها و يختار عادة الوزراء من نواب الأغلبية.

ج - التوازن و التعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية:

إن النظام البرلماني يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهم سلاحين يضمنان هذا التوازن هو حق البرلمان في الإقتراع بعدم الثقة في الحكومة و حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان.

نجد عادة أن الحكومة حين تختلف مع البرلمان فإنها إما أن تخضع لمشيئته و إما أن تستقيل، و لكن قد يحدث أن تجد الحكومة أن سياستها تتفق مع إتجاهات الرأي العام رغم أن البرلمان لا يوافق عليها، ففي هذه الحالة تتقدم الحكومة إلى رئيس الدولة للموافقة على إصدار مرسوم أو قرار بحل البرلمان، أما التعاون فيقصد به وجود إتصال بين هاتين السلطتين:

فمن ناحية، نجد أن للوزراء حق الدخول في البرلمان والإشتراك في جلساته ومناقشاته كما أن للحكومة حق تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان كما لها حق دعوة

البرلمان إلى الإنعقاد و حق تأجيله، و من ناحية أخرى، نجد أن البرلمان يستطيع أن يشكل من بعض أعضائه لجانا للتحقيق في بعض تصرفات السلطة التنفيذية كما أن لأعضائه حق توجيه أسئلة و إستجابات للوزراء (قد تنتهي بالإقتراع بعدم الثقة بالوزارة لإرغامها على الإستقالة و إسقاطها).

3- مزايا و عيوب النظام البرلماني:

أ- مزايا النظام البرلماني:

- تساعد الأنظمة البرلمانية في الحفاظ على تماسك وإستقرار الدول التي يتصف تركيبها السكاني بالتعددية وذلك من خلال قدرتها على تمثيل مختلف الفئات الإجتماعية في العملية السياسية.

- تساعد الأنظمة البرلمانية الدول المتخلفة إقتصاديا على تحقيق التنمية بشكل أسرع لأن دمج السلطات يوفر ميزتين في نفس الوقت، التمثيل السياسي والسرعة في إتخاذ القرارات وذلك على عكس الأنظمة الرئاسية التي تتصف بالبطء الشديد في إتخاذ القرارات، وقد يصل يصل ذلك البطء إلى الجمود التام في بعض الحالات.

- يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلا منها مكمل للآخر.

- يرسخ الديمقراطية ويمنع الإستبداد.

- هناك المسؤولية السياسية مما يعني إستحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.

- يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.

ب- عيوب النظام البرلماني:

- العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتسم بالدقة والحساسية، حيث يسهل الإخلال بميزان القوي أي لحظة.

- قد تركز السلطة في يد رئيس الوزراء وتضعف الرقابة في حالة وجود إنضباط حزبي قوي، وقد تضعف قدرة الحكومة على إتخاذ قرارات سريعة في حال تعدد الأحزاب داخل البرلمان والتحالفات المعقدة وهذا يسبب سقوط الحكومات.

- غياب الفصل بين السلطات الثلاثي هذا النظام، هذا الإنصهار بين السلطات الثلاث، هذا الإنصهار بين السلطات الثلاث قد يقود إلى إستغلال السلطة والإستبداد بها خصوصا في الدول النامية والتي تفتقد لمؤسسات معاصرة وقوية.
- معد الإنتخابات غير ثابت في هذا النظام ومن حق رئيس الوزراء البقاء منصبه طالما يملك ثقة الأغلبية في البرلمان.
- إنه يجعل على رأس السلطة التنفيذية شخصين مختلفين هما رئيس الدولة و رئيس الحكومة، ووجود شخصين على رأس جهاز واحد يؤدي في الغالب إلى قيام صراع بينهما بغية أن ينفرد أحدهما بالسلطة، و هذا ما يؤدي إلى نتائج وخيمة و بالتالي إصابة الجهاز التنفيذي بالشلل.

ثالثا: نظام حكم الجمعية:

- 1- مفهوم نظام حكم الجمعية تقوم حكومة الجمعية على أساس وضع إختصاص السلطتين التنفيذية و التشريعية في يد جمعية نيابية (أي هيئة منتخبة من الشعب)، و تقوم حكومة الجمعية على أساس فكرة وحدة السيادة في الدولة و عدم إمكانية تجزئتها، لذا وجب أن تتفرد الهيئة المنتخبة بتمثيل الأمة والتعبير عن إرادتها في كافة المجالات.
- ولما كان البرلمان يستحيل عليه مباشرة جميع أعمال الوظيفة التنفيذية بنفسه فإنه عهد بها إلهيئة إختارها بنفسه وحدد لها صلاحياتها بحيث تبقى تابعة له و خاضعة لسلطاته خضوعا كاملا.

2 - أركان حكومة الجمعية:

تنحصر أركان حكومة الجمعية فيما يلي:

- أ- تركيز السلطة في يد البرلمان و تبعية السلطة التنفيذية له.
- ب- يعهد البرلمان بالسلطة التنفيذية إلى عدة أفراد أو "وزراء " و يختار من بينهم رئيسا لهم يسمى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية و أحيانا يوكل البرلمان فردا واحدا للقيام بمهمة السلطة التنفيذية و يكون ذلك في أوقات الأزمات و الظروف الإستثنائية التي تحتاج إلى سرعة التصرف و الحزم في معالجة الأمور.

ج- يكون أعضاء السلطة التنفيذية مسؤولين سياسيا أمام البرلمان الذي يستطيع عزلهم إذا أساءوا التصرف أو حاولوا الانحراف بالسلطة عن هدفها المشروع، و غايتها في تحقيق الصالح العام للشعب.

3- مزايا وعيوب نظام حكومة الجمعية:

أ- مزايا نظام حكم الجمعية:

- يمثل مرحلة إنتقالية تستطيع الدول من خلالها تجاوز مرحلة حرجة من تاريخها.
- الهيئة التنفيذية مسؤولة مسؤولية سياسية أمام البرلمان مما يمنع إستبداد السلطة التنفيذية.
- الشعب من الناحية النظرية هو من يمارس السلطة الحقيقية وهي الديمقراطية الحقيقية بل يرى البعض أن النظام المجلسي هو أكثر النظم ديمقراطية.

ب- عيوب نظام حكومة الجمعية:

- إن نظام حكومة الجمعية النيابية يمنع إستبداد السلطة التنفيذية غير أنه لا يمنع إستبداد الهيئة التشريعية.
- من الناحية العملية هناك هيئة تابعة للسلطة التشريعية هي من تنفذ القوانين وليس الشعب أي أن السلطة الحقيقية هي للهيئة التشريعية وليس للشعب.
- نجاح نظام حكومة الجمعية النيابية في سويسرا يعود للظروف الخاصة، إلا أنه في دول أخرى قاد إلى الإستبداد والديكتاتورية كما حدث في فرنسا بعد الثورة الفرنسية عام 1789 وفي تركيا بعد سنة 1924.

رابعا: النظام شبه الرئاسي:

1- مفهوم النظام شبه الرئاسي:

النظام شبه الرئاسي أو ما يعرف بالنظام الرئاسي البرلماني هو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني، يكون فيه رئيس الدولة ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة وتوزيع السلطات بينهما يختلف من بلد لآخر حيث يختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الدولة يتم إختياره من قبل الشعب وأنه مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله إذا أراد.

إذن هو ذلك النظام الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ومثاله النظام الفرنسي الذي يعد النموذج الرئيسي للنظام المختلط أو شبه الرئاسي وتتجلى في:

- مظاهر النظام الرئاسي التي تتمثل في أن الرئيس منتخب من قبل الشعب ويتولى رئاسة مجلس الوزراء ويعين الوزير الأول ويعين الوزراء ويقيّلهم ويعين كبار الموظفين والعسكريين ويتمتع بالسلطة التنظيمية وإصدار القرارات.

- أما مظاهر النظام البرلماني فتتمثل في ثنائية السلطة التنفيذية إذ يوجد رئيس رئيس حكومة وكذلك يقوم البرلمان بمراقبة عمل الحكومة ويمكنه سحب الثقة منها، كذلك يمكن للسلطة التنفيذية أن تشارك في الوظيفة التشريعية بإقتراح المشاريع ومناقشتها داخل البرلمان.

2- أركان النظام شبه الرئاسي:

أ- السلطة التنفيذية مزدوجة:

حيث يتقاسمها رئيس دولة منتخب ووزارة يرأسها رئيس حكومة، وكل منهما له صلاحيات وسلطات تنفيذية، وعليه فإن توزيع السلطات ينطوي على صعوبة في ظل ثنائية السلطة التنفيذية.

ب- وجود رئيس منتخب من الشعب:

الرئيس منتخب من الشعب مباشرة مثله مثل البرلمان مما يضعه في موضع ممثل الشعب على درجة من المساواة مع البرلمان، كما يجعل مركزه متفوقا على مركز رئيس الوزراء.

ج- وجود وزارة مسؤولة سياسيا:

الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان الذي له الحق في مساءلتها والرقابة عليها وحجب الثقة عنها، لكن البرلمان لا يستطيع مساءلة رئيس الدولة أو عزله لأنه منتخب مباشرة من الشعب، والبرلمان بصفته السلطة التشريعية يمارس سلطة رقابة الحكومة، إذ لا تستطيع الحكومة الإستمرار في العمل دون نيل ثقة البرلمان كما يجري في الأنظمة البرلمانية.

3- مزايا وعيوب النظام شبه الرئاسي:

أ- مزايا النظام شبه الرئاسي:

- يوفر الإستقرار السياسي لقمة هرم السلطة السياسية متمثلا برئيس الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى الإستبداد، ويكون هناك رمز للأمة تلتف حوله الجماهير، ويكون هناك للبرلمان

سلطة موازية يستطيع من خلالها حجب الثقة عن الوزراء بالإستناد إلى إستفتاء شعبي وهذا سيؤدي إلى محاسبة المسؤول عن الخطأ.

- من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الدولة على ذلك.
- للحكومة الحق في إقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب ويمكن أن تسترط على مجلس الشعب الكيفية التي يجب أن يتم بها مناقشة هذه القضايا بدون تعديل ولا إضافة أو أن يتم التصويت عليها بنعم أو لا.

- هذا النظام يعطي لرئيس الدولة حق حل مجلس الشعب والمطالبة بإنتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء إستخدام هذا الحق بمعنى أن لا يطلب بإجراء الإنتخابات جديدة للمجلس لأكثر من مرة واحدة في السنة.

- من جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم.

لرئيس الدولة الحق في فرض حالة الطوارئ.

- لرئيس الدولة الحق في إستفتاء الشعب في قضايا يراها هامة ونتأجه لها قوة القانون في الدولة.

- المرجعية الدستورية في هذا النظام في يد رئيس المجلس الدستوري، وإختيار هذا المجلس يختلف من دولة لأخرى.

ب- عيوب النظام شبه الرئاسي:

- المشكلة الأساسية التي تواجه هذا النظام هي عندما تتصادم مصالح رئيس الدولة ومصالح رئيس الوزراء الذي يمثل مصالح البرلمان وهذه المشكلة عرفت في السياسة الفرنسية بمشكلة التعايش المزدوج، وهي الحالة التي يتم فيها إختيار رئيس الدولة من إتجاه فكري مناقض للإتجاه الذي يمثله رئيس الوزراء.

- إمكانية إساءة إستخدام قانون الطوارئ من قبل رئيس الدولة.

- إمكانية قيام رئيس الدولة بإساءة إستخدام حقه في إستفتاء الشعب كما هو سائد اليوم في كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسي.

خامسا: الإتحاد الكونفدرالي:**1- مفهوم الإتحاد الكونفدرالي:**

هو تحالف عدة دول بقصد تنظيم بعض الأمور المشتركة، مثل تنسيق بعض الشؤون الاقتصادية، الثقافية والدفاعية ومنع الحروب والمنازعات الداخلية مع إحتفاظ كل دولة بسيادتها وكذلك برئيسها،

وينشأ الإتحاد الكونفدرالي بموجب معاهدة دولية، كما تنشئ المعاهدة هيئة مشتركة تضم ممثلي الدول (على قدم المساواة) وتتمثل وظيفتها في الإشراف على تنفيذ الأهداف المشتركة.

ولكن ليس لها سلطات مباشرة على رعايا الدول الأعضاء، كما أنها لا تستطيع أن تتعدى صلاحياتها المنصوص عليها في بنود المعاهدة، أو تتوسع فيها إلا بناء على إتفاق جديد.

وبما أن هذا الإتحاد يقوم على السيادة الكاملة للدول الأعضاء، لذلك فلا تتخذ القرارات إلا بالإجماع (الهامة منها على الأقل).

أما تنفيذ قرارات الإتحاد فهي من إختصاص أجهزة الدول الأعضاء لأن الهيئة لا تملك أجهزة خاصة بها.

ويعتبر الإتحاد الكونفدرالي في مرحلة إنتقالية للوصول إلى نوع أعلى مثل إتحاد سويسرا 1776، الذي إنتقل إلى إتحاد مركزي سنة 1815، كذلك إتحاد الولايات الأمريكية الذي تطور سنة 1787 إلى إتحاد مركزي، ومن أمثلة الإتحاد الكونفدرالي الدول المشتركة في ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الوحدة بين ليبيا والمغرب المبرمة من سنة 1984 إلى 1986.

سادسا: النظام الشمولي:**1- مفهوم النظام الشمولي:**

هو نظام حكم، تصبح فيه الحكومة إستبدادية في تصرفاتها داخل الدولة، وتقوم بالتدخل في جميع الشؤون الداخلية بما في ذلك الحياة اليومية للمواطنين، حيث تسعى الحكومة الإستبدادية للسيطرة، ليس فقط على جميع المسائل الاقتصادية والسياسية ولكنها

تسعى أيضا للسيطرة على تصرفات ومعتقدات المواطنين أي تقوم بمعاملتهم على أنهم أشياء يحكموها كمؤسسات الدولة.

2- أهداف النظام الشمولي:

الحكومات الشمولية المختلفة تكون لهم أهداف إيديولوجية مختلفة فعلى سبيل المثال الإتحاد السوفياتي في عهد ستالين وألمانيا النازية وجمهورية الصين الشعبية تحت حكم ماو سي تونغ والفاشية الإيطالية هذه الأنظمة كانت تسعى إلى تحقيق الرضا العالمي للبشرية من خلال إنشاء مجتمع مثالي.

3- الخصائص والصفات المشتركة: على الرغم من وجود العديد من الاختلافات بين الدول الشمولية إلا أن لديهم العديد من الخصائص المشتركة مثل :

- وجود طريقة تفكير معينة تتطرق إلى جميع جوانب الحياة وتحدد وسائل معينة لتحقيق الهدف النهائي.

- وجود حزب جماهيري واحد يتم فيه تعبئة الشعب من أجل حشد الطاقة والدعم الشعبي، ويتم قيادة هذا الحزب عموما بواسطة ديكتاتور. كما يعمل الحزب من أجل السيطرة على النظام الحكومي الذي يضم الجيش، الشرطة، الاتصالات، النظم الإقتصادية والتعليم ويتم ترؤيع و تخويف الناس بواسطة الشرطة السرية.

4- الشمولية والديمقراطية:

وفي ستينات القرن الماضي حدث إنخفاض حاد في شعبية الشمولية في أوساط المتعلمين والمتقنين، خاصة بعد تراجع طريقة الحكم للمركزية السوفياتية بعد وفاة ستالين، كما أثبتت النازية عدم كفاءتها وإنهيار الإتحاد السوفياتي ، كل هذه الأحداث أثبتت أن إنشاء النموذج المثالي هو شيء وهمي وغير واقعي.

بالإضافة إلى ذلك فإن (الديمقراطية و الشمولية تشترك في بعض النقاط ففي كلاهما يكون الأشخاص الموجودون في السلطة يسيطرون على القوة العسكرية وأيضا على بعض أشكال وسائل الإعلام ويمكنهم قمع المعارضة.

الحريات الأساسية والضمانات

مقدمة:

إن حماية حقوق الإنسان والحريات العامة مسألة جوهرية وحساسة، كونها تمس بكرامة الإنسان و المواطن إذ أنه مهما كانت الجهود و المساعي الدولية في توفير هذه الحماية إلا أن المسؤولية الأولى والأخيرة تلقى على عاتق الدولة من أجل تطبيق النصوص الدولية والداخلية في مجال حماية الحرياتو تكريسا لهذا المجال فالجزائر تعمل على دعم حماية الحقوق والحريات من خلال العديد من القوانين و التنظيمات الداخلية، بسن النصوص التي تضمن الحماية، سواء على الصعيد الوطنيأو كطرف دولي و وضع تلك النصوص التي سبق سنها موضع التنفيذ و هذه الأخيرة هي الغاية التي من المفترض الوصول إليها.

أولا: حماية الحريات في النظام الجزائري:

- **الدستور الجزائري:** إن الدستور هو أسمى قانون بالدولة فهو الذي يحدد نظام الحكم والعلاقة بين السلطات وأيضا الحقوق والحريات وبتفحص الدستور الجزائري نجده قد تضمن الحقوق و الحريات في الفصل الرابع، من المادة (32) إلى غاية المادة (73) حيث شمل الحريات الآتية:

أ- **الحريات الشخصية:** أي الحريات التي تتصل بشخص الإنسان وتهدف إلى الحفاظ على كرامته مثل:

- **حق الأمن:** هو حق الإنسان في سلامة بدنه وحمايته من الإعتداء و قد كرسته المادة (58) من الدستور الجزائري "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم."، والمادة (59) التي حضرت توقيف الشخص أو حجزه إلا في الحالات المحددة قانونا، والمادة (60) التي حددت مدة التوقيف للنظر بأن لا تتجاوز 48 ساعة إلا في حالات معينة منصوص عليها قانونا، ونص الدستور أيضا على المعاقبة على كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات بصفة عامة والمساس بسلامة الإنسان بصفة خاصة سواء كان الإنتهاك من الأفراد أو من الأعوان الممثلين للسلطة وعليه يمنع كل أشكال التهديد

والتعسف والإعتداء على سلامة الإنسان الذي ينجر عنه المساس بعدة حقوق منها، الحق في الحياة، حق الإنسان في التصرف في جسده، الحق في الزواج وتكوين أسرة.

- **حرية التنقل:** سواء داخل الدولة أو خارجها، ويمكن تقييد التنقل للمصلحة العامة بقيود إدارية أو مادية، و قد تم النص عليها في المادة (55) من الدستور "يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته وأن يتنقل عبر التراب الوطني، حق الدخول للتراب الوطني و الخروج منه مضمون له".

- **حق مناهضة التمييز العنصري:** بالرغم من صدور مجموعة من النصوص القانونية الدولية لمناهضة ظاهرة التمييز العنصري وقمعها وإعتبارها وصمة عار في جبين الإنسانية، إلا أن أفعال التمييز العنصري لم تنته، بل وتفاقمت، خاصة في البلدان التي تتشكل من بشرية مختلفة، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي لقمع جريمة التمييز العنصري والمعاقبة عليها، ومن هذا المنعرج، ناهض الدستور الجزائري بكل أشكال التمييز العنصري كما جاء في نص المادة(32) مايلي " كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو إجتماعي." ، ونصت المادة (36) أيضا على أنه " تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل." كما أشارت المادة (40) على مايلي " تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان."، وفي نفس السياق وتعزيزا لمبدأ محاربة كل أشكال التمييز العنصري، سن المشرع الجزائري قانونا خاصا يحمل رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها.

ب- **الحريات السياسية:** تتمثل في مشاركة المواطن في تسيير شؤون دولته و توجيه أداة الحكم بها، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة و تشمل الحريات السياسية:

- **حرية الإنتخاب:** هو حق و واجب شخصي للفرد، أشارت إليه المادة(62) من الدستور الجزائري كمايلي : " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب". و الشروط المطلوبة في الناخب حددها القانون رقم 16-10، المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالإنتخابات.

- **حرية إنشاء الجمعيات والإجتماع:** أشارت إليها المادة (48) من الدستور التي جاء بها ما يلي: "حريات التعبير وإنشاء الجمعيات و الإجتماع، مضمونة للمواطن. "، وعليه فإنه لكل مواطن الحق أن ينشئ جمعية، وأن ينظم إجتماع، شريطة أن لا تخرج عن إطارها القانوني وأن لا تمس بالنظام العام، وتضيف المادة (54) من نفس القانون مايلي: "حق إنشاء الجمعيات مضمون"، وتشجع الدولة إزدهار الحركة الجمعوية، وفضلا أن القانون يحدد شروط و كفايات إنشاء الجمعيات.

- **حق إنشاء الأحزاب السياسية:** إن حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون وهذا ما أشارت إليه المادة (52) من الدستور، ولكن لا يجب على هذه الأحزاب أن تتخذ هذا الحق كذريعة لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته، فلا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي و لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية أو إتباع أي شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

ج- الحريات الفكرية والدينية: أي لكل إنسان الحق في أن يختار الدين الذي يشاء، بل ويختار ألا يكون مؤمنا بأي دين كان إذا أراد ذلك، وأن يمارس شعائر دينه بحرية وكذا حرية الفكر والتعبير.

- **حرية المعتقد:** بمعنى حرية الإنسان في إعتناق أي دين وممارسة شعائره ومراسيمه في العلنية والخفاء وحرية في ألا يعتقد بأي دين و من حقه ألا يفرض عليه دين معين، لكن هناك قيود تفرضها الأنظمة المختلفة، تتمثل في النظام العام الذي يحول بين الفرد وبين الدعوة إلى ما يخالفه، كما أن للقضاء سلطة وضع الحدود التي تتلاءم وتطور المجتمع، لذلك لا يجوز في البلد المسلم مثلا الدعوة إلى الإلحاد أو إنكار أحكام الدين.

- **حرية الرأي والتعبير:** مفادها حق الإنسان في الإدلاء برأيه بكل حرية عن طريق جميع الوسائل الإعلامية و التعليمية والدينية على أن لا تتحول هذه الحرية إلى وسيلة للقذف والعدوان على الغير، ويجب أن تتم في إطار التنظيم التشريعي المقرر وفي نطاق النظام العام، وهذا ما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) و أكدته المادة (42) من الدستور الجزائري "حرمة حرية الرأي".

د- الحريات الاقتصادية: يضمن الدستور حرية الإستثمار والتجارة التي تمارس في إطار القانون، كما تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على إزدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، كما تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين ويمنع الإحتكار والمنافسة غير النزيهة.

- الحق في التعليم والعمل: إن الحق في التعليم حق كرسه الدستور في المادة (65) ويكون مجانيا وإجباريا، حسب الشروط التي يحددها القانون، كما أن الدولة تسهر على أن يكون فيه تساوي في الإلتحاق بالتعليم و التكوين المهني. كما جاء في المادة (69) من الدستور مايلي: "لكل المواطنين الحق في العمل، ويضمن في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن والنظافة، الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كفايات ممارسته كما يضمن القانون حق العامل في الضمان الإجتماعي وتشغيل الأطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون، كما تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على إستحداث مناصب الشغل".

- الحق النقابي وحق الإضراب: لقد أشارت المادة (70) من الدستور إلى الحق النقابي، حيث أنه حق معترف به لجميع المواطنين، وينطبق الحق على الإضراب و ذلك حسب ما أشارت إليه المادة (71) من نفس القانون، إلا أن هذا الحق له حدود و يجب أن يمارس في إطار القانون، حيث يمنع القانون ممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.

ثانيا: حماية الحريات افي القوانين الأخرى:

أ- قانون العقوبات: أكدت المادة (107) على: "معاقبة كل من يمس بالحرية الشخصية للفرد أو الحقوق الوطنية للمواطن. "، أيضا المواد (150) إلى (154): "تعاقب على الإعتداء على المدافن وحرمة الموتى. " والمادة (295) تؤكد على أن عقوبة من يعتدي على حرمة المنازل هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبالتالي فقد تناول هذا القانون عقوبات تتراوح بين السجن والحبس والغرامة لكل من يعتدي على الحريات الفردية وشرف الأشخاص و منازلهم.

ب- القانون المدني: نص على عدم التعسف في إستعمال الحق و أكدت المادة (124) من القانون المدني على التعويض جبرا للضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية.

ج- قانون الأسرة: منح للزوجة الحرية في التصرف في مالها، أي إستقلالية الذمة المالية لكلا الزوجين و أيضا حرية إبداء رضاها بالزواج من بين الحقوق و الواجبات لكلا الطرفين.

ثالثا: الضمانات و حماية الحريات العامة:

أ- الضمانات الدستورية:

* وجود دستور الدولة: يعتبر الدستور الضمانة الأولى والأساسية للحريات العامة فهو الذي يعين نظام الحكم و يبين وضع السلطات العامة و يحدد الحقوق و الحريات.

* مبدأ المشروعية: يقصد به خضوع جميع تصرفات الأفراد للقانون بمعناه العام والمجرد، وقد يتحقق هذا المبدأ من خلال " مبدأ سمو الدستور " بإعتباره التشريع الأعلى في الدولة ويعتبر الدستور الجزائري من أرقى الدساتير في باب الحقوق والحريات"، إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ إختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارس السلطات ويكفل الحماية القانونية، ورقابة السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية.

* مبدأ الفصل بين السلطات: أي الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا عضويا وشكليا، وبذلك يكون لكل جهاز إختصاصه المحدد وبالتالي تفادي الإعتداءات.

- فالوظيفة التشريعية: تتمثل في سن القوانين العامة والمجردة لضبط وتحديد سلوك الأفراد في المجتمع حكاما ومحكومين " يجب أن يكون كل مشروع أو إقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه. " حسب المادة (1/138) من الدستور.

- أما الوظيفة التنفيذية: تتمثل في تطبيق القوانين من خلال إدارة وتسيير المرافق العامة للدولة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، حيث أن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء حسب المادة (3/93) من الدستور.

- بينما الوظيفة القضائية: فتنحصر مهمتها في حل المنازعات الناشئة بين الأفراد والهيئات وطبقا للنصوص القانونية السائدة " و يختص القضاء بإصدار الأحكام. " حسب المادة (164) من الدستور.

ب- الضمانات القانونية: تتمثل في:

- ضرورة تكفل النصوص القانونية بالحريات العامة، أي وجوب تواجد نص قانوني يملئ واجبات و يفصل في الحقوق بين الأفراد بقوة القانون (فمثلا لا يمكن تجريم فعل إرتكبه شخص ما إلا إذا كان هناك نص قانوني يجرم ذلك الفعل وهو ما يعرف بـ "الركن الشرعي")، لا سيما أن الحياة العامة للناس تقتضي التعامل فيما بينهم لإشباع حاجاتهم وتحقيق غرائزهم وهو ما أدركه المشرع الجزائري في المادة (32) من الدستور الجزائري، إذ جعل كل المواطنين سواسية أمام القانون.

- إلزامية حماية السلطة القضائية للحريات العامة: حماية الحريات العامة واجب منصوص عليه دستوريا و يتجسد دور القاضي في حماية الحريات من خلال عدة مهام، منها مثلا أنه من واجب القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه، و أيضا حياد الإدارة و الرقابة وتجسيد هذا المبدأ يكون بالتمييز بين رجال السياسة و رجال الإدارة العاملين في النطاق الحكومي.

- الرقابة الإدارية و القضائية على أعمال الإدارة، و تكون بواسطة القضاء الإداري الذي يراقب مدى إحترام الإدارة للقوانين.

ج- الضمانات القضائية:

- مبدأ إستقلال القضاء: من المسلم به بصفة عامة أن مبدأ إستقلال القضاء يعتبر أحد المبادئ القانونية العامة و المستقرة، ليس فقط في عموم الدساتير الوطنية و إنما أيضا في مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و كذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تطرق في مجمل المادتين (8) و (10)، أنه لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه و أن تنتظر قضيته أمام محاكم مستقلة و نزيهة، كما جاء في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، أنه لكل فرد الحق في النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه و إلتزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكم عادلة و علنية، مستقلة و مختصة إستنادا للقانون.

و عليه من أهم المقومات الأساسية للديمقراطية أن تتحرر السلطة القضائية من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية و التنفيذية في الدولة و عدم خضوع القاضي في ممارسة

مهامه إلا للقانون و هو ما كرسه الدستور في المادة (165)، الذي أكد على أنه لا يخضع القاضي إلا للقانون.

- الرقابة على دستورية القوانين: تتم بواسطة رقابة سياسية أو قضائية، فعندما يلاحظ أنه لا يوجد تطابق بين القوانين، يتم إلغاء القانون الذي لا يتوافق و أحكام الدستور.

الجماعات الضاغطة

مقدمة:

ينخرط الفرد بالإضافة إلى الأحزاب السياسية إلى نوادي رياضية أو ثقافية أو فكرية أو إلى نقابات أو إتحادات مهنية أو جمعيات معينة تدافع عن مصالح أو مبادئ أو حاجيات معينة... الخ، كل هذه التنظيمات قد تشكل بما يسمى بالجماعات أو المجموعات الضاغطة. الجماعات الضاغطة تعرف بجماعات التأييد أو اللوبيات أو جماعات الحملات أو جماعات المصالح تستخدم أشكالاً متنوعة من التأييد للتأثير على الرأي العام والسلطة السياسية. كما لعبت دوراً هاماً في تطوير وتحسين الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي تختلف أو تتباين من حيث الدافع، الحجم و التأثير، وقد تكون أهدافها ظرفية أو طويلة المدى وهي قد تنشأ كرد فعل لقضية أو مسألة حالية. و يمكن أن تستند في دوافع عملها إلى موقف سياسي، عقائدي، أخلاقي أو تجاري مشترك و تعتمد على أساليب مختلفة لتحقيق أهدافها على سبيل المثال الضغط السياسي، الحملات الإعلامية، الحيل الدعائية.... الخ.

أولاً: تعريف الجماعات الضاغطة:

يمكن الجزم إلى حد ما، على أنه لا يوجد خلاف كبير حول تعريف مفهوم الجماعات والقوى الضاغطة، فكل التعاريف تقريبا تجمع على اعتبارها مجموعة من جماعات المصالح التي تسعى إلى تحقيق أهداف معينة مرتبطة بمصالح السلطة السياسية دون الرغبة في الوصول إلى السلطة.

وقد سميت بجماعات الضغط من منطلق الضغوطات التي تمارسها على السلطات لتحقيق أهدافها، وقد وصفها البعض بأنها جماعات غير سياسية، فهي تجمعات تشمل كل جوانب الحياة الإنسانية من إقتصادية، إجتماعية، ثقافية ومهنية، وهي أيضا جماعات سياسية لأنها تستهدف في بعض الأحيان تحقيق غايات سياسية كاللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، فهو لوبي سياسي إقتصادي و إجتماعي.

ويصفها البعض أيضا بأنها تجمعات غير رسمية، فقد تكون القوى الضاغطة رسمية معتمدة من السلطات الرسمية، كجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، أو التنظيمات النقابية

للعمال، وقد تكون حكومية تشكل لتحقيق هدف معين، كجمعيات الصداقة بين الشعوب، كما في النظم الإشتراكية الزائلة في الإتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية أو النظم العسكرية المتحكمة في السلطة.

- الفرق بين الجماعات الضاغطة والأحزاب السياسية:

تختلف الجماعات الضاغطة عن الأحزاب في أهدافها ووسائل تكوينها، فمن أهدافها تحقيق مصالح مرتبطة بتركيباتها الإجتماعية والطبقية، فإذا كانت لها مصلحة إقتصادية كالنقابات العمالية فإنها تدافع عن الأجور، المنح، الحماية من الوقوع في حوادث العمل والتقاعد بوسائل مختلفة كالإضراب عن العمل وإحتلال المصانع والإدارات وبينما تهدف الأحزاب الوصول إلى السلطة وتكون وسائلها كسب التأييد الشعبي والنجاح في الإنتخابات، وإستخدام الوسائل الأجدر للترويج لمبادئها والأحزاب السياسية حين تفشل في الإنتخابات، تتحول إلى معارضة سياسية.

بينما تبقى الجماعات والقوى الضاغطة ساعية لتحقيق مكاسب لأعضائها سواء نجحت في ذلك أو فشلت، ولعل الجماعات والقوى الضاغطة هي أكثر نشاطا من بعض الأحزاب لا سيما أحزاب الأطر التي لا تنشط إلا في أوقات الإنتخابات، وقد تلتقي الجماعات والقوى الضاغطة مع الأحزاب السياسية في التنظيم والعضوية والتمويل وربما يكون التأثير الضاغط على الحكومات لدى هذه الجماعات أقوى من تأثير الأحزاب إذا كانت مرتبطة مع بعضها، وهناك أحزاب سياسية لها جماعات وقوى ضاغطة متحالفة معها لتحقيق بعض الأهداف المعينة.

وقد تتحول بعض الجماعات والقوى إلى أحزاب سياسية كنقابة التضامن البولندية التي كان لها دور كبير في زعزعة النظام الإشتراكي الماركسي في بولندا قبل إنهيارالإتحادالسوفياتي، ثم تحولت إلى حزب سياسي فاز في أول إنتخابات بعد إنهيار الحكم السابق والوصول إلى الحكم، بالإضافة إلى أن وسائل الجماعات والقوى الضاغطة التي تستخدمها قد لا تكون علنية أو شرعية، بينما الأحزاب تستخدم أساليب معلنة ومشروعة، ومن الناحية التنظيمية فإن الجماعات الضاغطة قد لا تكون منظمة عكس الأحزاب السياسية التي لها هياكل تنظيمية ولا تخضع هذه الجماعات للرقابة الشعبية بينما تخضع الأحزاب السياسية لها.

ثانيا: خصائص الجماعات الضاغطة:

تتميز الجماعات الضاغطة بمجموعة من الخصائص وهي على الشكل التالي:

- أنها تتشكل من جماعة من الأشخاص وتعتبر عن إنشغالهم، أرائهم وأهدافهم .
- مصالح مشتركة تربط بين هؤلاء الأشخاص ببعضهم البعض، بغض النظر عن إرتباطاتهم الإيديولوجية، حيث يحتمل أن تكون مختلفة وقد تكون متجانسة.
- إنها لا تستهدف الوصول إلى مراكز السلطة أو الإستيلاء عليها، وكل ما تستهدفه التأثير في قرارات السلطة وسياساتها لتوجهها في الإتجاه الذي ينسجم مع مصالحها.

- قد تتنوع الجماعات في إهتماماتها، فقد تكون جماعات عامة، حيث يمثل أفرادها قطاعا جماهيريا عاما في المجتمع، مثل النقابات أو الجمعيات الإجتماعية المختلفة، وقد تكون جماعات خاصة حيث يمثل أفرادها مجموعة من الأشخاص الذين تربطهم مصالح شخصية خاصة، وقد تكون جماعات إجتماعية تتحدد أهدافها في الدفاع عن بعض المصالح الإجتماعية، وقد تكون جماعات سياسية تتحدد مصالحها في الدفاع عن مصالح سياسية معينة (الجماعات الصهيونية في أمريكا) و قد تكون جماعات إقتصادية أو إدارية... وتتحدد أهدافها بالدفاع عن مصالح خاصة إقتصادية أو إدارية أو غيرها كل حسب إهتمامها الرئيسي.

- تعتمد الجماعات في ممارستها لوظائفها وفي إتصالاتها بالسلطة بهدف التأثير فيها، على عدة أساليب وغالبا ما تكون متميزة بالسرية والإتصالات الشخصية في إطار ما يسمى "الإتصالات ما وراء الكواليس" ومن خلال هذه المعطيات يمكن القول بأن الجماعات والقوى الضاغطة هي تنظيمات حديثة تقريبا.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والمجتمعات الأوروبية الغربية بشكل عام الحقل الأساسي الذي نشأت فيه والميدان الواسع لنشاطها، أما ظاهرة الجماعات بشكل عام، فهي قديمة قدم وجود الجماعة البشرية الأولى.

ثالثاً: أنواع الجماعات الضاغطة:

تم تقسيمها إلى جماعات مصالح عديدة ومتنوعة نذكر منها ما يلي:

• **جماعات المصلحة الترابطية:** هي التي تعبر عن مصالح أعضائها في الأساس وهي النمط الشائع.

• **جماعات المصلحة غير الترابطية:** التي تكون على أساس جغرافي أو طبقي أو ديني أو لغوي أو فكري أو مهني .

• **جماعات المصلحة المؤسسة:** يغلب عليها الطابع الحكومي الرسمي، كالبيروقراطية المدنية والعسكرية، لكن العاملين فيها يصبحون جماعة مصلحة حينما يعمدون للتأثير في صانعي القرار لتحقيق منافع خاصة بهم.

• **جماعة المصلحة الفوضوية:** هي التي تعول على المظاهرات والإضرابات وأعمال الشغب وليس لها هيكل تنظيمي، ويغلب على نشاطها التلقائية والعنف.

يمكن تصنيف الجماعات الضاغطة حسب طبيعتها على الشكل التالي:

1- **جماعات المصالح السياسية:** هي التي لها مصالح سياسية بحتة، ويطلق عليها (الوبي) كاللوبي الصهيوني.

2- **جماعات المصالح شبه السياسية:** هي التي لها أهداف سياسية و إقتصادية في آن واحد كنقابات العمال و إتحادات أصحاب الأعمال.

3- **جماعات المصالح الإنسانية أو الخيرية:** هي التي تمارس نشاطات متعلقة بحقوق الإنسان ورعاية الطفولة وجمعيات الرفق بالحيوان.

4- **جمعيات المصالح المهنية:** هي التي تهتم بالدرجة الأولى بتحقيق أهداف أصحاب المهنة الواحدة.

رابعاً: وسائل الجماعات الضاغطة و وظيفتها:

- وسائلها:

يمكن تحديد أهم الوسائل التي تستخدمها الجماعات والقوى الضاغطة على الشكل

التالي:

أ- **الإقناع:** هو أهم الوسائل التي تسعى جماعات المصلحة من خلاله لكسب

الأتباع وإقناع الحكومات بأهدافها، عبر اللقاءات و الاجتماعات الخاصة والعامة، وعبر

وسائل الإعلام بمختلف جوانبها، ويتمتع رجال الأعمال بميزة القدرة على الإقناع، مستخدمين إمكانياتهم المادية وخبراتهم العلمية وبذل الجهود للوصول إلى الهدف المطلوب. وتستعين هذه الجماعات بأصحاب الخبرة من العناصر الناجحة في توليها المناصب المختلفة كالقضاة والمشرعين النزهاء بعد التقاعد أو الوزراء السابقين أو كبار الموظفين مستغلة سمعتهم الجيدة للإقناع، كما أن هذه الجماعات تؤثر على أعضاء الحكومة والبرلمان والمشرعين عبر تقديم معلومات وبحوث ودراسات، وإن كانت غير صحيحة وتستخدم التنقلات والدعوات لغرض الإلتقاء والتباحث والإقناع.

ب- التهديد: هو من المسائل المهمة للضغط على السلطات الرسمية والتشريعية والقضائية، كإرسال الرسائل والبرقيات، مقابلة الأشخاص المطلوب التأثير عليهم، ويأخذ التهديد أشكالاً متعددة منها التهديد بسحب الثقة من أعضاء البرلمان، وعدم تأييد العضو الراض في المستقبل، وقد يشمل التهديد شكل العقوبات والقتل، وما إلى ذلك من أعمال العنف أو خلق أزمات مالية وإقتصادية للحكومات، كالتحريض على عدم دفع الضرائب أو التهديد باستخدام القوة المتمثلة بالإضرابات عن العمل.

ج- الضغط على السلطات الحكومية: نظراً لأهمية السلطات الحكومية في إصدار القرارات لا سيما في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية فضلاً عن السياسة والتي تخص مختلف شرائح المجتمع، فإن جماعات المصلحة تسعى للإلتصال المباشر بالمعنيين في الجهاز التنفيذي والإداري بدءاً من رئاسة الدولة والوزراء إلى المسؤولين الكبار، فقد تعتمد إلى وقف تنفيذ قانون ما، فتطلب من رئيس السلطة التنفيذية ذلك عبر الرسائل والبرقيات بعدم التصديق عليه، أو التوجه بحذف بعض مواد أو إضافة أخرى.

وبالإضافة إلى هذه الوسائل، هناك وسائل أخرى توظفها الجماعات والقوى الضاغطة من أجل الوصول إلى غاياتها مثل التمويل، المقاضاة وتعبئة الرأي العام لصالحها، وكذلك التأثير في أعضاء البرلمان، حيث تشكل هذه أهم الوسائل التي توظفها في الضغط إتجاه إستصدار قوانين وقرارات تخدم مصالحها.

د- تأثير الجماعات الضاغطة على الرأي العام: يلعب الرأي العام دوراً هاماً في الحياة السياسية وتعزيز الحكم، حيث يعتبر من أهم آليات الرقابة الشعبية على سلطات الدول بما يكفل سلامة تصرفاتها، لذلك يأتي في مقدمة الآليات التي تسخرها جماعات الضغط، على

إعتبره المحرك الرئيسي لتغيير سياسات الحكومات وإسقاطها إذا خرجت عن صوابها، فهو أنجح الوسائل لإثارة الشعب وتهيئته لتقبل التغيير.

- وظيفتها:

تمثل الجماعات الضاغطة أحد مستويات التفاعل وربما الصراع التي تؤثر على الحياة السياسية، مثلها مثل الأحزاب السياسية، رغم أنها تختلف عنها من حيث أهدافها وأساليبها (كما سبق الإشارة لذلك)، إلا أن هذا الاختلاف لا يبعدها عن بعضها البعض بقدر ما يجعلها بمثابة قناتين أساسيتين في عملية التمثيل الشعبي، حيث تشكل الأحزاب قناة التمثيل السياسي بينما تمثل الجماعات وخاصة العامة منها قناة التمثيل الوظيفي.

وهذا يعني أن وظيفتها الأساسية لا تكمن في تقديم القيادات السياسية الممثلة للجمهور، كما الحال بالنسبة للأحزاب بل تركز وظيفتها بالدرجة الأولى في تجميع إهتمامات ومطالب الفئات التي تمثلها وتقوم بتقديمها للسلطة والعمل من أجل تحقيقها. كما أنها تقوم بتحضير قطاعات الشعب صاحبة المصلحة بذلك ليقوموا بتأييد ودعم السلطة حين تستجيب لذلك، أو لمعارضتها ومجابتها حين تكون إستجابة السلطة سلبية.

وهذا بالطبع لا يلغي دورها في تقديم القيادات السياسية وتوصيلها للسلطة، إلا أنها تبقى وظيفة ثانوية وغير مباشرة وذلك بقيامها بدعم حزب معين ماليا وإعلاميا من أجل نصرته في الحصول على الأصوات اللازمة لنجاحه أو مواجهته لبرامج الأحزاب الأخرى التي تتناقض مع مصالحها.

- حدودها:

هناك مجموعة من العوامل الأساسية التي تحدد طبيعة و دور الجماعات ودرجة قوتها أو ضعفها وأهمها:

أ- البيئة السياسية: تمثل أهم هذه العوامل، حيث تتحدد البيئة السياسية عادة بطبيعة النظام السياسي، هل هو ليبرالي أم شمولي، ديمقراطي أو ديكتاتوري؟ فالنظم الليبرالية تعتبر المرتع الخصب اللازم لنمو هذه الجماعات، وبالذات الجماعات الخاصة، وذلك نظرا لعدم الممانعة من قبل الإيديولوجية العامة للنظام، حيث تقوم على حرية عمل مثل هذه الجماعات وغيرها.

أما النظام الديكتاتوري، فإنه لا يسمح بنمو هذه الجماعات وغالبا ما نجدها، حيث توجد محدودة وضعيفة، وخاصة الجماعات العامة، بينما قد تكون للجماعات الخاصة فرصة كبيرة، خاصة الجماعات الإقتصادية، حيث ليس من السهل تقييد حريتها ببساطة، خاصة أنها تعمل بالطرق الخفية عادة.

كذلك الأمر بالنسبة للنظم الشمولية، وإن كانت هذه النظم تقاوم بشدة وجود الجماعات الخاصة، مع تسامحها بعض الشيء فيما يتعلق بالجماعات العامة، شريطة أن تظل مستوعبة داخل أجهزة السلطة، أما أن تبرز هذه الجماعات بصفة مستقلة عن أجهزة السلطة فغالبا ما يكون ذلك أمرا مرفوضا.

وبالطبع فإن ظاهرة الجماعات تظل موجودة في أي مجتمع وخاصة الجماعات الخاصة، لأنها ظاهرة حتمية لا يستطيع أي نظام تجنبها، والجماعات تملك أساليب متنوعة للتعبير عن نفسها مما يمكنها من البروز بطرق مختلفة، يساعدها على ذلك تضخم المجتمعات المعاصرة، وتعقيد علاقاتها.

ب- التنظيم أو التشكيل الرسمي للسلطة: يتضمن هذا العامل عنصرين رئيسيين لهما قوتها في التأثير على الجماعات الضاغطة من حيث قدرتها وقوتها وهما: مدى الأخذ بأسلوب اللامركزية أو المركزية في النظام، فمعظم النظم التي تطبق أسلوب السلطة المركزية الواحدة والقوية، تتميز بعدم وجود الجماعات الضاغطة أو القدرة على عقد صفقات مع السلطة ، وتأثير هذه الجماعات لا يمكنها من فرض مطالب محددة ولا يتعدى في أحسن الأحوال سوى تقديم إلتماسات أو تظلمات أو آراء.

أما في النظم ذات التوجه اللامركزي، فإن فرصة نمو وتغلغل هذه القوى، تكون مضاعفة كثيرا بالقياس مع الحالة الأولى، وذلك لأن تعدد مراكز السلطة عبر المستويات التنظيمية المختلفة تزيد عدد القوى التي قد تلجأ إليها هذه الجماعات فيما لو فشلت على المستوى المركزي أو على بعض المستويات اللامركزية الأخرى.

مدى الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، فتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يخلق ويضاعف الفرصة الحقيقية لتمارس هذه الجماعات نشاطها وفعاليتها، فإذا فشلت في الضغط على إحدى السلطات تتحول للسلطات الأخرى.

- وضع الأحزاب السياسية: إن متابعة طبيعة العلاقة بين أوضاع الأحزاب السياسية ودرجة قوتها، وبين أوضاع الجماعات الضاغطة وفعاليتها تولد إستنتاجا يبرز غالبا كقاعدة عامة، مفادها أن قوة وفعالية الجماعة الضاغطة تتناسب مع مدى ضعف أو قوة الأحزاب السياسية.

إن العلاقة بين هذين العاملين قد تبرز ضمن إحدى الصورتين التاليتين:

- علاقة واقعية فعلا، حيث أن كل طرف منهما يحاول أن يملأ الفراغ الذي لم يستطع الآخر أن يملأه.

- علاقة إستبدالية بحيث يبرز أحد هذين الطرفين كبديل للطرف الآخر وربما على أنقاضه، ومتابعة الظروف المختلفة في النظم السياسية تؤكد هذه النتيجة.

خامسا - سلبيات و إيجابيات الجماعات الضاغطة:

أ- السلبيات:

- تقوم على أساس تحقيق مصالح فئات مما يتعارض والمصلحة العامة.
- غالباً ما تفرض على أعضائها الولاء لها، وهذا ينافي مع ولاء العضو للجماعة الكبرى وهي الدولة.

- تتبع معظم جماعات الضغط أساليب ملتوية في سبيل تحقيق أغراضها.
- جماعات الضغط لا تمثل المصالح المتعارضة لجميع فئات المجتمع، قد يحدث أن تحقق جماعات الضغط أهدافها على حساب فئة أو فئات أخرى من الشعب وإن كانت أكثر منها عدداً.

ب- الإيجابيات:

- إنّ جماعة المصلحين الذين ينددون بمساوئ جماعات الضغط هم أنفسهم في حاجة إلى أن ينظموا في جماعات كي يمكنهم التغلب على هذه المساوئ.
- نمو الجهاز الحكومي و إزدياد عدد موظفيه يهدد بالقضاء على حريات الأفراد، مالم ينظم هؤلاء الأفراد في جماعات قوية تستطيع أن تكون ندا لهذا الجهاز عند الضرورة، وأن تحمي حرياتهم من إستفحال نموه.

- تقوم جماعات الضغط بالتأثير في الحكومة طوال الفترات بين الانتخابات العامة، بينما يكون الفرد في هذه الفترات عاجزا عن إحداث أي تأثير يقابله.
- تملك هذه الجماعات بحكم تخصصها وممارستها لمهامها وسائل الوقوف على البيانات والاتصال بالجهات الموثوق بها وأهل الخبرة في مختلف المجالات، مما يسهل على الحكومة دراسة مشروعات القوانين المقترحة وأحسن الطرق لتنفيذها، فالجماعات أكثر تأثرا بالقرارات الحكومية من الأفراد وأقدر منهم على إستثارة المعارضة السريعة الفعالة إتجاه القرارات الحكومية المجحفة بحقوق الأفراد والضارة بالمصلحة العامة.
- من خلال ما تم عرضه يتضح جليا أن الجماعات الضاغطة تلعب دورا محوريا في التأثير على الرأي العام والحكومة على حد سواء، على أساس إمتلاكها للأموال، هذه الأخيرة تسهم في إستخدام جميع وسائل الإعلام لنشر مسائلها وقضاياها في الوقت المناسب، وبالتالي الحصول على تعاطف الرأي العام معها، بالإضافة إلى إمكانية إطلاعها على أسرار الحكومة والتي تستعمل كوسائل إكراه والضغط في حالة عدم الإنصياع لرأيها ورغبتها.
- فالجماعات الضاغطة تتمتع بدور هام على صعيد الحياة العامة، إلا أن هذا الدور يفترض ضرورة الحذر إزاءه، لبروزه كسيف ذو حدين، فقد يبرز من زاوية معبرة عن إحساسات تدافع عن مصالح أو مبادئ أو حاجيات معينة.

الأحزاب السياسية

مقدمة:

تعتبر الأحزاب السياسية من الجماعات المؤثرة بشكل رسمي في السياسة العامة للدولة، ويكاد يقترب وجود النظام الديمقراطي في بلد ما بوجود الأحزاب السياسية، حيث تتمكن هذه الأخيرة من المشاركة في الحكم عن طريق الانتخابات التي تحشد لها الانصار المتعاطفين مع المشروع السياسي الذي يحمله الحزب، ويسعى الحزب من خلال مشاركته في الانتخابات إلى تحقيقه و قد يكون مشاركا في الحكم أو معارضا له أو بعض المعارضة أحيانا والتأييد أحيانا أخرى.

وأما عن تأثير الأحزاب في مجريات الحياة وتسيير الشأن العام فيكون من خلال البرلمان، الحكومة و الجماعات المحلية التي تشكل من الأحزاب الفائزة بالانتخابات التي تنظم دوريا، إذا ما هي الأحزاب السياسية؟ وما هي خصائصها؟ وما أهميتها؟ و وظائفها؟ في المجتمع و الدولة.

أولا: تعريف الأحزاب السياسية:

الحزب السياسي هو جماعة من الناس لهم نظام و أهداف و مبادئ يلتقون حولها ويدافعون عنها ويسعون إلى تحقيقها عن طريق الوصول إلى السلطة أو الإشتراك فيها. وعليه فالحزب السياسي هو مجموعة من الأفراد يجمعهم السعي نحو تحقيق المصلحة القومية إنطلاقا من أفكار معينة تتوافق عليها، أي أن الحزب هو تنظيم سياسي لطبقة واعية في مجتمع ما، يسعى إلى السلطة بغرض التطبيق السياسي وعندما يصل إلى السلطة فإنه يحكم لصالح طبقة لكن بإسم الشعب.

ثانيا: خصائص الأحزاب السياسية:

يكاد يجمع الباحثون على أن للحزب خمسة خصائص على ضوء كل التعاريف المتداولة وإن كانت هذه الخصائص لا تتحقق دائما:

1- التنظيم الدائم: عمر الحزب يتجاوز عمر من أنشأه، حيث يستمر و يدوم مما يعطيه جذورا تاريخية بخلاف بعض المجموعات العرضية التي سرعان ما تنقرض، لأن الحزب يحمل مشروع سياسي.

2- تنظيم وطني: هو تنظيم من القمة إلى القاعدة يغطي كل قطر التراب الوطني بخلاف التنظيمات المحلية أو الجهوية، يتأسس على قيادة مركزية وقيادات ولائية ثم لجان أو مكاتب بلدية.

3- السعي للوصول إلى السلطة: لابد للحزب أن يسعى للوصول إلى السلطة لكي يتولى الحكم سواء منفردا أو بالإشتراك مع أحزاب أخرى، وذلك لتحقيق وتجسيد البرنامج الذي يحمله والوفاء بوعود الحملة الانتخابية.

4- السعي للحصول على الدعم الشعبي: يحقق الحزب السياسي أهدافه عن طريق قاعدة شعبية تسنده وتدعمه في الانتخابات ويسعى لذلك عن طريق الإقناع والحوار المباشر.

5- يحمل مذهب سياسي: لابد للحزب أن يتبنى مذهبا سياسيا يدافع عنه، يضمه المشروع المعروض على الشعب للتصويت عليه، وهو يحمل المبادئ والأهداف والوسائل.

ثالثا: تصنيف الأحزاب السياسية:

أ- التصنيف البنوي: يميز هذا التصنيف نوعين من الأحزاب:

- **أحزاب أطر:** هي أحزاب قديمة في الغالب تركز على الشخصيات، فهي لا تهتم بالكم الجماهيري أي تعتمد على الأعيان (رجال الدين، أصحاب الجاه، المثقفين...)، تمتاز بثلاث خصائص، قلة عدد المنخرطين، البنية المرنة وهيمنة القيادة على القاعدة.

- **أحزاب جماهيرية:** تمتاز بالانتساب الكثيف للمنخرطين والعمل دائما على تكوينهم لتكوين طليعة من المواطنين القادرين على تحمل أعباء الحكم (مدرسة للتربية السياسية)، كما تمتاز بالتنظيم القوي الذي يحقق الانضباط، مما جعلها ذات فعالية في الحياة السياسية حيث أن النواب يخضعون إلى قيادة الحزب بصفة صارمة وتكثر في هذا الحزب الاجتماعات والمؤتمرات لوضع برنامج الحزب، و نجدها غالبا في الأحزاب الاشتراكية .

ب- التصنيف الإيديولوجي: في هذا التصنيف قسمت الأحزاب إلى:

- **أحزاب اليمين:** هي أحزاب محافظة ذات آراء رأسمالية، هدفها الدفاع عن ثروات الملاك، وتلجأ هذه الأحزاب إلى دعايات واسعة عن طريق شراء الصحف والكتب ولتأييد أفكارها تعتمد على إنفاق الأموال الطائلة لتجد صدى لأفكارها في أوساط الجماهير.

- **أحزاب اليسار:** هي أحزاب معارضة ذات آراء إشتراكية، هدفها تحقيق مبادئ الحزب حيث تركز هذه الأحزاب على قوة العمال وعلى الدعوة بينهم.
- **أحزاب الوسط:** هذه الأحزاب تؤمن بفكرة التطور في سبيل السير بالبلاد نحو التقدم، تعمل على الحد من سيطرة الإحتكارات والرأسماليات وعلى رفع مستوى معيشة الفرد و تحقيق العدالة الإجتماعية.

أشكال (أنظمة) الأحزاب السياسية:

هناك ثلاث أشكال للأحزاب السياسية:

- نظام الحزب الواحد.
 - نظام الثنائية الحزبية.
 - نظام التعددية الحزبية.
- أ- **نظام الحزب الواحد:** هو نظام يقوم فيه حزب واحد بالسيطرة على مظاهر الحياة دون أي منافسة من حزب آخر، فهو يوصف بأن له نظاما جامدا، كما يتميز بإعتماده الشديد و الطاعة المطلقة من طرف القاعدة للقيادة (عادة ماتستمد شرعيتها من الثورة كحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر من 1962 إلى 1989).

ب- **نظام الثنائية الحزبية:** يقوم على حزبين كبيرين يتنافسان على السلطة و يتداولانها بإستمرار، رغم وجود أحزاب أخرى إلا أن تمثيلها النيابي قليل مثل ما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية (الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري) .

ج- **نظام التعددية الحزبية:** يقصد بها وجود أكثر من حزبين تتقارب فيما بينها من حيث القوة والوزن والأهمية، ولا تكون لأحد منه السيطرة الكاملة على السلطة، هذه التعددية الحزبية تجعل النظام ديمقراطيا مثل فرنسا و إيطاليا.

رابعا: أهمية الأحزاب السياسية ووظائفها:

1- أهمية الأحزاب السياسية :

تكمن أهمية الحزب في وظيفته ومنه يمكن أن تجمل فيما يلي:

- هي مدارس للتكوين والتنقيف السياسي.
- هي أداة للرأي العام في التعبير عن إتجاهاته وتطلعاته.

- قناة للتحاور مع السلطة السياسية وتقديم الإنشغالات الشعبية، إضافة إلى إقتراح حلول للقضايا المطروحة.

- هي أداة التصدي للإستبداد الحكومي وتحقيق التداول على السلطة.
- تقوم بتنشيط الحياة السياسية داخل المجتمع عن طريق عرض البرامج والتنافس فيما بينها و السعي إلى كسب التأييد و الدعم الجماهيري.
- حصر المشاكل القائمة و إقتراح الحلول المناسبة لها.

2- الرأي المعارض لوجود الأحزاب:

- الذين يعارضون الأحزاب السياسية يرون أنها:
- تعمل على تفكيك الوحدة الوطنية و وحدة الأمة (أي الفرقة و الضعف)، لكونها تدعو إلى التنافس و تشجع روح الإنقسام بين المواطنين، و هي تعمل على معارضة و نقد ما يقدمه غيرها من برامج و أفكار وحلول للمشاكل.
- الأحزاب تفضل الصالح الحزبي على الصالح القومي، أي تعمل على تحقيق مصالح الحزب و أعضائه الخاصة بالدرجة الأولى على حساب المصلحة العامة.
- الأحزاب تدعي الديمقراطية وبمجرد الوصول إلى الحكم و تولي السلطة تتحول إلى أحزاب ديكتاتورية.
- التعددية الحزبية تؤدي إلى الاختلاف وبالتالي كثرة الأزمات السياسية في المجتمع و منه ضعف الحكومات.
- تسمح لإقليم معين بالسيطرة على الحكم على حساب الأغلبية، خاصة في أنظمة الحزب الواحد.

إنّ كل هذه المبررات التي تدل على سلبية الأحزاب السياسية ليست ظاهرة عامة، كما أنها مرتبطة بعوامل أخرى تتعلق بطبيعة النظام السياسي في ذلك البلد وهل التعددية السياسية لديه كخيار إستراتيجي أم مجرد تحايل على الناس والعالم ... إلخ.

خامسا: النظام القانوني لتأسيس حزب سياسي في الجزائر:

من أجل تأسيس أي حزب سياسي، لابد من التقيد بمجموعة من الشروط، شكلية وموضوعية، ولابد من إتباع مجموعة من الإجراءات، وذلك في ظل نظام قانوني وضعه المشرع الجزائري مع مراعاة أحكام الدستور.

وبعد إستيفاء الأعضاء، سواء المؤسسين منهم أو المنخرطين، لكل الشروط اللازمة وبعد المرور والخضوع لكل الإجراءات المقررة، يحصل الحزب على الإعتماد من طرف وزير الداخلية، والذي يكسبه شخصية إعتبارية ترخص له مباشرة نشاطاته السياسية و أهدافه التي أنشئ من أجلها، و بالتالي يتلقى دعم مالي من كل الجوانب، شرط أن يكون هذا الدعم شرعي وغير متعارض مع أحكام القانون.

غير أن الإعتماد الذي يحصل عليه الحزب يمكن أن يكون غير كاف، وهذا عائد إلى الرقابة الصارمة التي وضعها المشرع على نشاط و موارد الحزب، مما قد يؤدي بمصير الحزب إلى توقيف نشاطاته السياسية أو إلى الحل الذي هو نوعين إداري وقضائي، كما يمكن أن يخضع الأشخاص المسؤولين عن ذلك الحزب إلى عقوبات سواء الحبس أو غرامات مالية مقرر قانونا.

سادسا: القيود الواردة على تأسيس الأحزاب السياسية:

يعترف الدستور الجزائري بموجب المادة (24) منه بحق إنشاء الأحزاب السياسية، و لقد قيد المشرع الجزائري حرية تأسيس الأحزاب وتشكيلها بجملة من الشروط منها شكلية و موضوعية و القيود الإجرائية على تأسيس حزب سياسي.

1- الشروط الأساسية لتأسيس الأحزاب السياسية:

أ- الشروط الشكلية: نصّ المشرع الجزائري في القانون العضوي 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية على شروط يراها ضرورية لتأسيس الأحزاب السياسية، بعضها شروط خاصة بتسمية الحزب وفق ما نصت عليه المادة (06) من القانون العضوي المذكور أعلاه "لا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه إسما أو رمزا كاملا أو علامة كاملة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها و كان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها."

وشروط أخرى خاصة بالأعضاء، إستنادا لأحكام المادة (17) من نفس القانون السالف الذكر: "يتمتع العضو المؤسس بالجنسية الجزائرية، أن يكون عمره 25 سنة على

الأقل، أن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية، و أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة، ولم يرد له الإعتبار".

ب- الشروط الموضوعية لتأسيس الأحزاب السياسية: وضع المشرع الجزائري جملة من الشروط الموضوعية لإنشاء حزب سياسي تطرق فيها بالتفصيل في المواد من (07 إلى 09) من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

إن المادة (52) من الدستور نصت على ما يلي: "حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون"، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، و الوحدة الوطنية و أمن التراب الوطني و سلامته وإستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظل إحترام أحكام الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

و لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.

يحظر على الأحزاب السياسية على شكل من الأشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى إستعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحدد إلتزامات و واجبات أخرى بموجب قانون عضوي.

وحتى لا تتحول الأحزاب السياسية من أداة للديمقراطية و الحرية و البناء إلى أداة للهدم والتخريب، يتوجب عليها إحترام الشروط المذكورة أعلاه، فبالإضافة إلى ما تضمنه الدستور من شروط، إرتأى إعادة تصنيفها في مواد القانون العضوي 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية ذلك للأهمية التي تكتسبها، ولا بأس أن نتطرق إلى نص المواد من (07 إلى 09) كما سلف ذكره.

فنصت المادة (07) على "يجب أن يكون إنشاء الحزب السياسي وسيره وعمله ونشاطه مطابقا لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي".

ونصّت المادة (08) على "لا يجوز طبقاً لأحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة.

- للقيم و المكونات الأساسية للهوية الوطنية،
- لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الخلق الإسلامي،
- للوحدة و السيادة الوطنية،
- للحريات الأساسية،
- لإستقلال البلاد و سيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة،
- لأمن التراب الوطني و سلامته، تمنع على الأحزاب السياسية كل تبعية للمصالح الأجنبية أيا كان شكلها. "

كما نصّت المادة (09) من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: "لا يمكن للحزب السياسي أن يلجأ إلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما. كما لا يمكنه أن يستلهم من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا".

2- القيود الإجرائية على تأسيس حزب سياسي:

إنّ إنشاء حزب سياسي يخضع لبعض الإجراءات الواجب التقيد بها من طرف الأعضاء المؤسسين وهي منصوص عليها في القانون العضوي 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية وهي مذكورة على سبيل الحصر في المادة (16) من هذا القانون، التي نصت على مايلي: " يخضع تأسيس حزب سياسي إلى الكيفيات الآتية:

- التصريح بتأسيس الحزب السياسي في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون لدى الوزير المكلف بالداخلية،

- تسليم قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي في حالة مطابقة التصريح،
- تسليم إعتاماد الحزب السياسي بعد التأكد من إستيفاء الشروط المطابقة لأحكام هذا القانون العضوي. "

من خلال ما سبق ذكره، فإن تأسيس الحزب السياسي يخضع لثلاثة إجراءات قانونية، مع مراعاة الترتيب التالي:

- التصريح بتأسيس حزب سياسي وفق المادة (18) من القانون العضوي رقم 04-12 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- عقد مؤتمر تأسيسي حسب المواد من (21 إلى 27) من القانون العضوي رقم 04-12 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- طلب الإعتماد حسب المواد من (27 إلى 32) من القانون العضوي رقم 04-12 المتعلق بالأحزاب السياسية.

سابعا: العوارض القانونية لنشاط الأحزاب السياسية:

تكتسب الأحزاب السياسية شرعية الوجود أبعد ما تحصل على الإعتماد النهائي من طرف وزير الداخلية، فتتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية مما يسمح لها بالدخول في الحياة السياسية وممارسة النشاط السياسي في ظل الشفافية، لكن هذا الإجراء الأخير ألا وهو الإعتماد لايعطي الحرية المطلقة للأحزاب لممارسة نشاطاتها.

لهذا، قد وضع المشرع عقوبات في حالة مخالفة الأحكام المقررة قانونا، وهذه العقوبات يمكن أن تكون عقوبات مقررة على الأحزاب أو عقوبات مقررة على الأشخاص.

1- العقوبات المقررة على الأحزاب: يعطي الإعتماد حرية للأحزاب في مزاوله نشاطاتها السياسية، إلا أنها تخضع لرقابة مما قد يؤدي بمصيرها إلى التوقيف والحل.

أ- التوقيف:

يتم توقيف نشاط الحزب السياسي في حالة خرق الأعضاء المؤسسين للحزب لقوانين المعمول بها أو لإلتزاماته قبل إنعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده، وفي حالة الإستعجال والإضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام .

وهنا نميز حالتين، حالة ما إذا كان الحزب غير معتمد سواء قبل إنعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده، يصدر القرار من طرف الوزير المكلف بالداخلية الذي يأمر بقرار مغل تعليلا قانونيا توقيف كل النشاطات الحزبية للأعضاء المؤسسين وغلق المقرات التي تتم فيها هذه النشاطات.

فيجب أن يبلغ القرار للأعضاء المؤسسين فور صدوره و يكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة، أما إذا كان الحزب معتمد، يصدر الأمر بتوقيف كل ما ذكر أعلاه من طرف مجلس الدولة الذي يحضره الوزير المكلف بالداخلية قانونا.

التوقيف يكون مؤقتا فقط، بحيث يكون بإعذار سابق من الوزير المكلف بالداخلية في أجل محدد بشأن الإلتزام بمدى مطابقة نشاطاته لأحكام القانون العضوي، ففي حالة عدم الإستجابة لهذا الإعذار بعد إنقضاء الأجل المحدد، يخطر الوزير المكلف بالداخلية مجلس الدولة، ليفصل في التوقيف المؤقت لنشاطات الحزب لمدة معينة يحددها القاضي في أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ إيداع العريضة الإفتتاحية.

أقر المشرع الجزائري في المادة (64) أعلاه بتوقيف نشاطات الحزب من طرف الوزير المكلف بالداخلية في حالة الإستعجال أو الخطر الوشيك، لكن هذه الحالات لم يحددها ، مما قد يجعل هذا الإجراء أداة في يد وزير الداخلية لإتخاذ قرار التوقيف.

ب- الحل:

نصّت المادة (68) من القانون 04-12 المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: "يمكن أن يكون حل الحزب السياسي إما إراديا وإما عن طريق القضاء"، يتبين لنا من خلال هذه المادة أن الحل نوعين، إرادي و قضائي.

- الحل الإرادي: يتم من قبل الهيئة العليا للحزب و يتم إعلام الوزير المكلف بالداخلية بإنعقاد هذه الهيئة و بموضوعها."، على إعتبار أن الحزب السياسي المعتمد يتمتع بالشخصية المعنوية و له قانون أساسي ، فالمفروض أن يكون بإمكانه حل نفسه إختياريا طبقا للأحكام والأشكال المتضمنة في قانونه الأساسي. (المادة (69) من القانون العضوي رقم 04-12 المتعلق بالأحزاب السياسية) .

أشرنا سابقا أن كل شخص إستوفى الشروط الشكلية والموضوعية لتأسيس حزب سياسي، الحرية في تكوين هذا الأخير، وبالتالي فهو يتمتع بحرية كاملة فيما إذا أراد إنهاء حياة حزبه وإلغاء وجوده القانوني والسياسي، وهذا يتم طبقا لما أقره المشرع في نص المادة (69) المذكورة أعلاه، بحيث ينحل طبقا لقانونه الأساسي بموجب قرار من هيئته العليا، ويجب إعلام الوزير المكلف بالداخلية.

- الحل القضائي: خول القانون لمجلس الدولة سلطة حل الحزب السياسي بناء على طلب من وزير الداخلية، وهذا حسب أربع (04) حالات حددها المشرع في المادة (70) من القانون العضوي 04-12 المتعلق بالأحزاب السياسية، وهي كالتالي:

- قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غير تلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي.

- عدم تقديمه مرشحين لأربعة إنتخابات متتالية تشريعية ومحلية على الأقل.

- العود في مخالفة أحكام المادة (66) أعلاه بعد أول توقيف.

- ثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي.

إنّ سلطة حل الحزب السياسي من حق مجلس الدولة بطلب من الوزير المكلف بالداخلية، لكن هذا الأخير قد خول له المشرع سلطة توقيف أي عمل ممكن لحزب سياسي ضمن نشاطاته قبل الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة في حالة الإستعجال.

كما يمكن للحزب المعني بالتوقيف في هذه الحالة هو الآخر تقديم طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الإستعجالية لطلب إلغاء الإجراء التحفظي المقرر، لكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ القرار.

وبعد الفصل في الدعوى التي تقضي بالحل القضائي للحزب، حسب المادة (72)

يترتب ما يلي:

- توقف نشاطات كل هيئاته،

- غلق مقراته،

- توقف نشرياته،

- تجميد حساباته.

أضافت المادة (73) من القانون العضوي 12-04 في حالة الحل النهائي للحزب السياسي، فإن أملاكه تعود لدمته المالية الخاصة به طبقا لما تنص عليه أحكام قانونه الأساسي، ما لم يقضي قرار قضائي على خلاف ذلك.

2- العقوبات المقررة على الأشخاص:

فرضت على الأحزاب السياسية كأشخاص معنوية عقوبات متمثلة في التوقيف والحل، فنجد أيضا الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب كأشخاص طبيعيين، لا يخلون من عقوبات جزائية تصدر في حقهم على المخالفات المنصوص عليها في القانون العضوي والتشريع الساري المفعول.

فغرامة مالية تتراوح بين ثلاثة مائة ألف دينار (300000 دج) وستة مائة ألف دينار (600000 دج) لكل شخص يخالف أحكام هذا القانون العضوي بتأسيسه، أو إدارته، أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته، ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص يدير حزبا سياسيا أو يسيره أو ينتمي إليه، يكون قد إستمر في نشاطه أو أعاد تأسيسه خلال مدة توقيفه أو بعد حله.

كما يعاقب على تحويل أو إختلاس أملاك الحزب السياسي و كذا إستعمالها لأغراض شخصية طبقا للتشريع المعمول به.

كما تنصّ المادة (80) من نفس القانون على ما يلي: "تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على كل فعل معاقب عليه يحدث في إطار نشاط الحزب السياسي و تسييره. "

وفي هذا الشأن نجد المادة (39) من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته تنص على: "دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول، المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، يعاقب كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية، بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 200000 دج إلى 1000000 دج. "

في الأخير، قام المشرع بعملية نشر وتبسيط لمواد الأمر 97-09 الملغى ليضعها في قالب جديد هو القانون العضوي 12-04، الذي أعاد من خلاله بناء هيكله القانون، موزعا بعض المواد على أبواب جديدة و مركزا على بعض الأحكام المشتتة في مواد أخرى، لكن الواقع و التطبيق يضعنا في مواجهة إحتياجاتنا الفعلية، فنحن - في الجزائر - نحتاج إلى قانون أحزاب سياسية يحمل ثوابت راسية تنظم أعراف الحياة الحزبية و تضبط ملامحها بدقة وتحفظ في الآن ذاته مرونة سماتها التي تتأثر تمدا و تقلصا بموجات تغيير المجتمع.

الديمقراطية

مقدمة:

الديمقراطية هي مفهوم واسع ساهم في إثرائه عبر عقود طويلة من الزمن الكثير من المفكرين السياسيين كل حسب نظريته لهذا المفهوم، الذي يجمع في داخله العديد من التيارات الفكرية التي تتفق على بعض الخطوط العامة و تختلف في معظم التفاصيل، والتي تبلورت بمرور الزمن في الديمقراطيات الحديثة المطبقة بشكل أو بآخر في الغرب.

أولاً: مفهوم الديمقراطية:

الديمقراطية كلمة إغريقية الأصل، مكونة من كلمتين الأولى ديموس (DEMOS) وتعني الشعب و لثانية كراتس (KRATOS) وتعني الحكم أو السلطة وبذلك أصبح المدلول اللغوي لإصطلاح الديمقراطية هو " سلطة الشعب "أو "حكم الشعب " .
و لكلمة الشعب مدلولان:

- المدلول الأول: مدلول إجتماعي، ويعني جميع الأفراد الذين يعيشون على إقليم الدولة أي الذكور والإناث، العقلاء، المجانين، الكبار، الصغار، المواطنين والأجانب.
- المدلول الثاني: مدلول سياسي، وهو أضيق من المدلول الإجتماعي، ولا يضم إلا من لهم حق ممارسة الحقوق السياسية، فيستثني من ذلك فاقد الأهلية (المجانين وصغار السن) أو ناقصيها (من لم يبلغوا سن الرشد) والأجانب والإناث في بعض المجتمعات.

ثانياً: أنواع الديمقراطية:

1- الديمقراطية المباشرة و تطبيقاتها:

للمدولة الديمقراطية المباشرة مفهومين، نظري وعملي:

أ- المفهوم النظري:

الديمقراطية المباشرة تعني أن يتولى الشعب بنفسه كافة الشؤون، ويمارس كافة السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية، فالشعب هو الحاكم، ومن تم فلا يوجد في هذا النظام هيئة برلمانية لأن الشعب هو بنفسه يتولى التشريع، كما لا وجود للوزارات والوزراء، ولا وجود للمحاكم و للقضاة، فتلك كلها أمور يباشرها الشعب بنفسه بدون تفويض

أو تمثيل أو إنابة أو توكيل، ومن هنا عرفت الديمقراطية المباشرة بأنها " حكومة الشعب بواسطة الشعب ".

ب - المفهوم العملي:

يقصد به، ممارسة الشعب للسلطة التشريعية مع فرض رقابته على السلطتين التنفيذية والقضائية، وبعبارة أخرى ممارسة الشعب للسلطة عبر المؤسسات الشعبية في المجال التنفيذي والقضائي، وذلك أن الشعب بإمكانه أن يمارس مهام ووظائف السلطة التشريعية وتقرير السياسة العامة للدولة، إلا أنه من غير المتصور عقلا أن يتولى الشعب مهام ووظائف السلطتين التنفيذية والقضائية إذ يقف دوره فقط في تعيين الموظفين واختيار القضاة دون إمكانية ممارسة مهامهما.

ج - تطبيقات الديمقراطية المباشرة:

- في المدن اليونانية القديمة:

إذ كانت كل مدينة تعتبر دولة، وكان يحيط بكل منها سور بداخله المساكن وفي وسطها ميدان فسيح، هو السوق وكان يتولى السلطة في هذه الدولة بعض أفراد الشعب حيث كانوا يجتمعون كلما دعت الضرورة لتدبير أمورهم كوضع القوانين، إختيار القضاة تقرير الحرب و السلام و إبرام المعاهدات.

- في الولايات السويسرية:

توجد بسويسرا ثلاث ولايات تطبق نسبيًا النظام الديمقراطي المباشر، حيث يقوم النظام في هذه الولايات على أساس إجتماع الشعب السياسي في الولاية على هيئة "جمعية عمومية" تسمى بـ "الجمعية الشعبية"، تتعقد مرة في السنة، في ميدان واسع و في حالة عدم صحوه الجو تتعقد في كنيسة الولاية بحيث تبدأ بإحتفال ديني وتنتهي كذلك، إن إطلاق لفظ التطبيق النسبي للديمقراطية المباشرة في الولايات السويسرية يرجع إلى ما يأتي:

* إن إختصاص الجمعية الشعبية ينحصر في إقرار القوانين التي تعرض عليها أو رفضها.

* ليس للجمعية إختصاصات تنفيذية، إذ يتولى السلطة التنفيذية جهاز على رأسه رئيس هو رئيس الولاية.

* ليس للجمعية الشعبية أي إختصاصات تتعلق بالأمور الخارجية، إذ أن الحكومة الاتحادية هي التي تتولاها.

* للولاية مجلس نيابي منتخب يسمى "مجلس الولاية" له سلطات تشريعية واسعة.

- النظام الجماهيري (ليبيا):

يرتكز النظام الجماهيري على فكرة كسر إحتكار ممارسة السلطة في جميع مظاهرها من قبل فرد أو طبقة أو حزب وتسليمها بالكامل إلى الجماهير، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه يمارسها بنفسه في جانبها التشريعي من خلال مؤتمراته الشعبية الأساسية، وفي جانبها التنفيذي عن طريق لجان فنية يختارها بنفسه وتخضع لرقابته وإشرافه، وفي جانبها القضائي عن طريق محاكم شعبية متخصصة.

2 - الديمقراطية شبه المباشرة:

تقوم على أساس وجود برلمان منتخب يمارس السلطة نيابة عن الشعب، لكن مع وجوب الرجوع إلى الشعب نفسه بإعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات في كثير من الأمور الهامة، و يتفق الفقهاء على أن الديمقراطية شبه المباشرة تتخذ مظاهر معينة تتجلى فيما يلي:

- الإستفتاء الشعبي،
- الإقتراح الشعبي،
- الإعتراض الشعبي،
- إقالة الناخبين لنائبهم،
- الحل الشعبي،
- عزل رئيس الجمهورية.

وقد تم تطبيق الديمقراطية شبه المباشرة في القرن التاسع عشر في كل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه إنتشر في القرن الحالي وبصفة خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث يرجع الفقهاء ذلك إلى تضاعف الوعي السياسي لدى المواطنين، و وضع حد لإستبداد الهيئات النيابية و تجاهلها لرغبات الناخبين.

3- الديمقراطية النيابية:

يكون فيها الشعب صاحب السلطة، لكنه لا يمارسها بنفسه وإنما يختار عددا من الأفراد يفوضهم ممارستها نيابة عنه لمدة معينة يحددها الدستور.

فهذا النظام ديمقراطي، لأنه يقر بسيادة السلطة للشعب وهو نيابي لأن الشعب صاحب السلطة لكنه لا يمارسها بنفسه وإنما ينيب أفرادا من الشعب يمارسون السلطة نيابة عنه.

ويتميز النظام النيابي بأربع خصائص رئيسية و هي:

- برلمان منتخب من الشعب له سلطات،
- عضو البرلمان يمثل الأمة بأسرها،
- إستقلال عضو البرلمان عن جمهور ناخبيه،
- البرلمان يمثل الأمة لفترة محدودة.

ويقوم النظام النيابي على أساس توزيع السلطات بين هيئات مختلفة، فيختار الشعب ممثلين عنه يتولون القيام بمهمة التشريع، وآخرين للقيام بمهمة التنفيذ وفريقا ثالثا للقيام بمهمة القضاء.

وعليه، فإن مظاهر السلطة في النظام النيابي تتجلى في ثلاث وظائف هي:

- الوظيفة التشريعية،
- الوظيفة التنفيذية،
- الوظيفة القضائية.

ثالثا: أسس و مبادئ الديمقراطية:

تقوم الديمقراطية كفلسفة ونظام وممارسة على جملة من الأسس والمبادئ تساهم في تشكيل هويتها، طبيعتها، نظامها، طرق، أساليب وإجراءات ممارستها في واقع حياة الشعوب والمجتمعات.

ومن أهم هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها في عالمنا المعاصر:

- 1- مبدأ سيادة الشعب والأمة.
- 2- مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة الاقتصادية، الاجتماعية السياسية، القانونية و القضائية.

- 3- مبدأ الديمقراطية هي مثل أعلى يجب على كل الشعوب والأمم المختلفة أن تسعى لبلوغه في جميع الأحوال.
 - 4- مبدأ المنافسة في ظل التعددية السياسية و النظام الإنتخابي الحر والنزاهة على ممارسة السلطة و التداول عليها.
 - 5- مبدأ وجود الدولة القوية و العادلة بنظام مؤسساتي ديمقراطي.
 - 6- مبدأ الفصل بين السلطات أو مبدأ وحدة السلطة و تعدد الوظائف السياسية، التشريعية التنفيذية، القضائية و الرقابية في الدولة.
- هذه أهم أسس ومبادئ الديمقراطية التي تتقاطع وتتواصل مع أسس ومبادئ ومقومات نظام الحكم الراشد.

رابعاً: عوامل و ضمانات نجاح الممارسة الديمقراطية:

للتغلب على كافة مشاكل ومعوقات و تحديات الممارسة الديمقراطية الحقيقية والسليمة، وتوفير فرص وظروف إزدهار ممارستها، لابد من توفر مجموعة من العوامل والضمانات السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، القانونية، والقضائية يمكن سرد بعضها على النحو التالي:

- توافر العوامل والضمانات الفعلية والوظيفية، المتمثلة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية من أجل العدالة الإجتماعية و المساواة الحقيقية الإقتصادية، الإجتماعية السياسية و القانونية لخلق المناخ الديمقراطي الفعلي و الأساسي.
- وجود دولة المؤسسات والقانون و العدل لضمان ممارسة الديمقراطية بكل رشادة و حكمة و فاعلية.
- وجود و إزدهار ثقافة الديمقراطية بفعل نظام تربوي، تعليمي و تثقيفي سليم و رشيد.
- وجود إعلام وطني حر، مسؤول ونزيه، يؤدي الرسالة الإعلامية بكل إحترافية وموضوعية في ظل قيم أخلاقيات هذه الرسالة في بلورة و تنوير الرأي العام الوطني الحر والقوي من أجل الممارسة الديمقراطية السليمة و المسؤولة.
- وجود و إزدهار نظام سياسي تعددي و مسؤول.
- وجود نظام إنتخابي حر و نزيه و شفاف في الممارسة الإنتخابية الديمقراطية التعددية.

- إقامة نظام قضائي قوي وفعال في عمليات إحترام حق الإنسان والمواطن في الحكم القضائي العادل وفي حماية قيم وأهداف الممارسة الديمقراطية في المجتمع.
- تكريس روح وأخلاقيات وقيم المواطنة الصالحة.
- هذه أهم عوامل وضمانات تجسيد و نجاح الممارسة الديمقراطية في الدولة المعاصرة.

الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية

مقدمة:

عرف الإنسان أشكالاً مختلفة من الديمقراطية جاءت نتيجة ظروف ومتطلبات فرضت إختيارها، فبعد أن طبقت الديمقراطية المباشرة في العهد اليوناني، حيث كان الشعب يشارك في تسيير شؤون دولته بصورة مباشرة، ثم الديمقراطية شبه المباشرة ساهمت في ظهورها عوامل عديدة من أهمها تزايد عدد السكان في تبني الديمقراطية النيابية التي تكفل للشعب إختيار نواب عنه يتمتعون بالصلاحيات والكفاءة، يمارسون السلطة باسمه وبالنيابة عنه خلال فترة زمنية محددة.

رغم مزايا التمثيل النيابي، إلا أن التجربة الميدانية أثبتت عجزه عن بناء نظام حكم تتاح فيه الفرصة لكل الفاعلين للمشاركة في إتخاذ القرارات المتعلقة بهم، مما دفع أغلب الدول إلى تبني نموذج ديمقراطي يساهم في إشراك مختلف الفاعلين من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إدارة وتسيير شؤونهم، خاصة على المستوى المحلي. و من بين تلك الدول، الجزائر التي قامت بإصلاح سياسي كان من أهم ركائزها تبني مقاربة تراهن على مساهمة تنظيمات المجتمع المدني، من خلال القيام بدوره في تمثيل شرائح واسعة من المواطنين و طرح إنشغالاتها و المساهمة في سن القوانين المؤطرة لحياتها ورسم السياسات العامة والعمل على إرساء الشفافية، المساءلة والرقابة وفقاً لمقتضيات الديمقراطية التشاركية.

أولاً: تعريف الديمقراطية التشاركية:

حاول العديد من الباحثين تعريف الديمقراطية التشاركية وفقاً لرؤيتهم للموضوع، إلا أنهم يجمعون على أنها أهم آليات إشراك المواطنين بصورة مباشرة في إتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤونهم العامة و مراقبة و تقويم مدى تنفيذ هذه القرارات وهي شكل أو صورة جديدة للديمقراطية، تتمثل في مشاركة المواطنين مباشرة في مناقشة الشؤون العمومية و اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

ثانيا: دور الإصلاحات السياسية في تكريس الديمقراطية التشاركية في الجزائر:

لقد كان هدف تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال إعطاء دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني من أهم محاور الإصلاحات السياسية في إطار المبادرة التي أعلن عنها، وتجسدت في مجموعة قوانين مثل القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 يتعلق بالجمعيات، فإن هذا القانون بدلا من أن يعطي مزيدا من الحرية والإستقلالية كرس تدخل الحكومة في العمل الجمعي بالتشديد في شروط وإجراءات التأسيس أو تعديل النظام الداخلي والتعامل مع الجهات الأجنبية، بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة التي تمكن الحكومة من حل الجمعيات وتجميد نشاطها خصوصا بإستعمال القانون لمصطلحات مبهمة مثل المساس بالهوية الوطنية، و الوحدة الوطنية.

ولتدارك هذه النقائص، حاول دستور 2016 إعادة الإعتبار لمنظمات المجتمع المدني، عندما نص على ترقية القانون المتعلق بالجمعيات إلى قانون عضوي حيث جاء في المادة (3/54) منه: " يحدد القانون العضوي شروط و كفاءات إنشاء الجمعيات. "

ثالثا: آليات تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المجتمع المدني في الجزائر: تستطيع تنظيمات المجتمع المدني المشاركة في تسيير الشؤون العامة على المستوى المحلي بإستعمال العديد من الآليات التي تتيح لها إمكانية التأثير في عملية إتخاذ القرار وضمان الشفافية في رسم وتنفيذ السياسات العامة وممارسة دور هام في الرقابة والتقييم. يبدأ دور هذه التنظيمات من عملية إختيار المسؤولين المنتخبين، من خلال مشاركتها في لجان مراقبة الإنتخابات، مما يجعلها شريكا للسلطة في ضمان نزاهة الإنتخابات وما ينتج عنها من مجالس تتولى تسيير الشأن المحلي.

كما أننا نميز هنا بين الآليات المتعلقة بإشراك هذه التنظيمات في التشريع من خلال تحديد علاقتها بالمؤسسة التشريعية وكفاءات تبليغها لمطالبها لتضمينها في مختلف النصوص القانونية وتتوير النواب بأهم الإختلالات التي تسجلها أثناء تنفيذ الحكومة لسياساتها، و بين آليات مساهمة مختلف الجمعيات في تسيير الشؤون العامة على المستوى المحلي.

1- مشاركة المجتمع المدني في التشريع والرقابة:

لا يمكن الحديث عن مساهمة المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي، إذا لم يكن له دور في رسم السياسات العامة و إبداء رأيه وطرح إنشغالاته على المؤسسة التشريعية، حتى تكون النصوص القانونية معبرة عن آرائه وحاملة للحلول المناسبة لإنشغالاته وطموحاته وحتى آليات وطرق مشاركته و ممارسته في ضمان الشفافية والرقابة على المستوى المحلي. بالعودة إلى الدستور الجزائري و القوانين الداخلية لغرفتي البرلمان والقانون المنظم لعملهما قبل التعديل الدستوري لسنة 2016، نلاحظ أنها لا تحتوي على أي مادة تتيح لمنظمات المجتمع المدني إمكانية المشاركة في أعمال البرلمان من خلال طرح إنشغالاتها لتجسيدها في مشاريع قوانين أو المساهمة في مراقبة ومساءلة الحكومة بأي شكل من الأشكال، و رغم إنعدام الإطار القانوني الملزم و المؤطر لعملية إشراك فعاليات المجتمع المدني، إلا أن المؤسسة التشريعية في الجزائر إستغلت صلاحياتها القانونية للإستعانة ببعض الجمعيات والإستفادة من خبرتها وممارستها الميدانية متخذة في ذلك عدة طرق أهمها:

أ- إن النواب في غرفتي البرلمان يمكنهم الإستعانة بممثلي منظمات المجتمع المدني بإعتبارهم خبراء يستشيرونهم في القضايا التي تدخل في صلب إهتماماتهم، وإن التجربة الميدانية للجمعيات بحكم ممارستها يمكن أن تفيد اللجان الدائمة في أداء مهامها، فالمادة (43) من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنص على أنه " يمكن للجان الدائمة في إطار ممارسة أشغالها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للإستعانة بهم في أداء مهامها. "، كما تنص المادة (38) من القانون الداخلي لمجلس الأمة على ما يلي: " يمكن للجان الدائمة، في إطار ممارسة أعمالها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للإستعانة بهم في أداء مهامها. " مما يعني أن الإستعانة بالخبراء تكون بصفتهم الشخصية لا بإعتبارهم ممثلين لتنظيمات المجتمع المدني، إن إستعانة بعض اللجان البرلمانية الدائمة بالجمعيات المتخصصة ممثلة في رئيسها، لا تسمح لهذه الإستشارة بتحقيق الأهداف المرجوة لعدة إعتبارات أهمها:

- دعوة رئيس الجمعية بإعتباره خبيرا، يجعل الجمعية مختزلة في شخص رئيسها.

- خضوع هذه الدعاوات للانتقائية ووفقا لتقدير اللجنة، الذي قد لا يبنى على معايير موضوعية وتستند إلى معايير أخرى تفقد الإستشارة قيمتها.

- إن إختزال إستشارة الجمعية في الإستماع إليها من طرف اللجان الدائمة بصفة خبير لا بإعتبارها تنظيما يمثل شريحة من المواطنين، يقلل من أهمية مشاركتها خصوصا في ظل التشديد القانوني على سرية أعمال اللجان الدائمة وعدم نشر مداولاتها ليطلع عليها الجمهور، إذ تنص المادة (47) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ما يلي: " يحزر ملخص قرارات إجتماعات اللجان الدائمة، تحفظ الأشرطة المسموعة في أرشيف اللجنة، ولا يمكن الإطلاع عليها إلا بموافقة رئيس اللجنة. "، كما نصت المادة (42) من النظام الداخلي لمجلس الأمة على أن "جلسات لجان مجلس الأمة سرية، ولا يمكن للجان المجلس نشر أو إعلان محاضرها، ويتحمل مسؤولية ذلك مكتب اللجنة، وتتحمل المصالح الإدارية مسؤولية المحافظة على سرية تسجيلات أشغال اللجان، ولا يسمح الإستماع لها إلا بإذن من مكتب اللجنة المختصة."

ب- مساهمة بعض الجمعيات في العمل التشريعي من خلال المشاركة في الندوات والملتقيات التي نظمها البرلمان بغرفتيه، لإثراء بعض المواضيع المتعلقة بالنصوص القانونية المرتبطة بمجال إختصاصها.

ج- وجود أعضاء في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة كانوا من نشطاء النقابات ومختلف الجمعيات، يتبنون إنشغالاتها، إن هذه الآليات تعتبر محدودة جدا ولا تلبي مطالب هذه التنظيمات، مما يدفعها لتجاوز المؤسسة البرلمانية واللجوء للهيئة التنفيذية مستعملة كل الوسائل المتاحة للضغط عليها، من بينها الإضرابات والإحتجاجات خصوصا في ظل وجود صحافة مستقلة تمكنها من طرح إنشغالاتها، مما يكسبها قوة إضافية تضطر الحكومة لتلبية مطالبها والتكفل بها.

ولعل ما قامت به الجمعيات النسوية في الجزائر خير مثال على ذلك، عندما طالبت بضرورة تخصيص "كوتا" خاصة بالنساء في القوائم الإنتخابية تتوافق ونسبة تمثيلها في المجتمع، وعززت طلبها بنسبة تواجد المرأة في قوائم الترشيح للإنتخابات التي تبين تخلف المرأة الجزائرية عن نظيراتها في كل من تونس و المغرب، مما يبرر مطالبها التي جسدتها

في مذكرة تتضمن مجموعة من الإقتراحات التي من شأنها أن تضمن التمثيل المناسب للمرأة في المؤسسات السياسية والعمومية .

2- مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي:

تلعب منظمات المجتمع المدني دورا هاما في إتخاذ القرار وضمان الشفافية والمراقبة بإعتبارها فاعلا هاما في إرساء مبادئ الحكم الراشد على المستوى المحلي، الذي لا يتحقق إلا بتطبيق الديمقراطية التشاركية التي تسمح لها بلعب هذا الدور .

ففي الجزائر، كان تجسيد هذا الدور من أهم سمات عمليات الإصلاح المتعلقة بالجماعات المحلية، فقد جاء في عرض وزير الداخلية لمشروع قانون البلدية عند توضيحه لأهداف هذا التعديل: "على مستوى المبادئ الأساسية كان من الضروري تجسيد الأسس التي كرسها الدستور ضمن هذه المنظومة القانونية في مجال الديمقراطية المحلية والتسيير الجوّاري و السيادة الشعبية".

هذه المتطلبات تقتضي، إدراج ضمن مشروع هذا القانون الأحكام التي تمكن المجلس الشعبي البلدي من التكفل به وترجمته بالأفعال الديمقراطية في شكلها التشاركي وبالتالي المساهمة في ترقية الشفافية في تسيير شؤون البلدية، يتعلق الأمر هنا بإرساء إتصال دائم بين المنتخبين ومنتخبهم خلال كل عهدة وليس فقط أثناء الإنتخابات، كما جاء في توصيات التقرير التمهيدي لمشروع قانون البلدية ومناقشات النواب التأكيد على ضرورة إشراك المواطنين لاسيما من خلال منظمات المجتمع المدني في تسيير شؤونه المحلية والمساهمة الفعالة في التنمية المحلية، فتغيب المواطن عن المشاركة في إتخاذ القرارات، وبغياب أو فشل من يلبي إحتياجاته صار يلجا في التعبير عن إستيائه بالفوضى ولا سيما إغلاق الطريق العام والقيام بأعمال تخريبية .

وقد جاء هذا القانون ليجسد تلك المبادئ، حيث نصت المادة (02) منه صراحة على "أن البلدية هي القاعدة الإقليمية اللامركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل اطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية" وعلى عكس القوانين السابقة خصص قانون البلدية بابا كاملا و هو الباب الثالث لمساهمة المواطنين سماه: مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية، مما يؤكد التوجه الجديد للجزائر نحو تبني مقاربة الديمقراطية التشاركية لتجسيد مبدأ المشاركة في التسيير الذي يعتبر من أهم مؤشرات الحكم الراشد على المستوى

المحلي، حيث نص في أربعة مواد وهي (11، 12، 13 و 14)، فالمادة (1/11) تنص على أن " تشكل البلدية الإطار المؤسسي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجوّاري."، أما المادة (1/12) فجاء فيها: " قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجوّاري المذكور في المادة (11) أعلاه، يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم." وأعطت المادة (13) لرئيس المجلس الشعبي البلدي الحق في إستشارة أي مواطن بإستطاعته أن يفيد المجلس بمعطيات وإضافات تساهم في إتخاذ القرارات المناسبة حيث نصّت على ما يلي: " يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما إقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة إستشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانوناً، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطهم".

كما أعطت المادة (2/36) للجان المختصة المشكلة للمجلس الشعبي البلدي نفس الصلاحيات إذ نصت على أن: "تجتمع اللجان بناء على إستدعاء من رئيسها، بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويمكنها اللجوء إلى الإستشارة طبقاً لأحكام المادة 13 أعلاه."، أما على مستوى المجلس الشعبي الولائي فقد جاء في المادة (36) من قانون الولاية: "يمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته."، ولضمان الشفافية و المراقبة نصت المادة (14) من قانون البلدية على أنه: "يمكن لكل شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية. و يمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته مع مراعاة أحكام المادة 56 أدناه." و لإعطاء شفافية أكثر لأعمال المجالس، عمل المشرع على ضمان علنية الجلسات حيث جاء في المادة (1/26) من قانون البلدية: "جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية. وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة." كما أكد على ضرورة إعلام المواطنين بتاريخ الجلسات فالمادة (1/22) من قانون البلدية تنص على أن: "يلصق مشروع جدول أعمال الإجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام

الجمهور، بمجرد إستدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي. "، أما المادة (2/11) من قانون البلدية فتتص على أنه " يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم و إستشارتهم حول خيارات و أولويات التهيئة والتنمية الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون".

ويمكن في هذا المجال، إستعمال على وجه الخصوص الوسائل والوسائط المتاحة، كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين ولتحقيق نفس الغاية، نصت المادة (18) من قانون الولاية على أن " يلصق جدول أعمال الدورة فور إستدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور، ولا سيما الإلكترونية منها، وفي مقر الولاية و البلديات التابعة لها. "، أما المادة (26) فتؤكد على أنه "تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية. ويمكن أن يقرر المجلس الشعبي الولائي التداول في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين : الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين." الواضح من خلال دراسة هذه النصوص أنها لم تبين دور منظمات المجتمع المدني، إلا عبر مشاركة أعضائها كأفراد، كما أنها بقيت مبهمة بشكل لا يسمح بتجسيد الديمقراطية التشاركية أو " الديمقراطية المحلية " التي تسمح بإشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي، خصوصا في ظل عدم إستكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالموضوع، مما جعل المسؤولين يبحثون في آليات أكثر واقعية تسمح بتكريس مبدأ التشارك، وتجسيده في التعديل القادم لقانوني البلدية والولاية، وكل النصوص التنظيمية المتعلقة بالمجالات التي تتطلب تحقيق الديمقراطية التشاركية.

رابعا: آليات تفعيل مشاركة المجتمع المدني:

إنّ تفعيل مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام تتطلب سلسلة من الإجراءات ، يمكن إيجازها فيما يلي:

- رفع القيود المتعلقة بتأسيس وتسيير الجمعيات، وضمان إستقلالياتها.
- وضع آليات قانونية واضحة تتيح لهذه التنظيمات المساهمة في إقتراح القوانين وتحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومتابعة تنفيذها.

- إلزام المسؤولين بالتكفل بإقتراحات منظمات المجتمع المدني والتكفل بإنشغالاتها وإستحداث أطر واضحة لمناقشة هذه المطالب والإقتراحات تضمن إنسجامها مع الأهداف العامة والإمكانات المادية والبشرية المتاحة وإستراتيجيات التنمية المحلية.
- ضرورة ممارسة هذه التنظيمات للديمقراطية والشفافية في تسييرها و إتخاذ القرارات وآليات وشروط تحمل المسؤولية، واحترام قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية.
- إلزام تنظيمات المجتمع المدني بأن تكون مطالبها وإقتراحاتها واقعية ومبنية على معطيات حقيقية، تخدم المصلحة العامة وتحمل تصورات لأولويات التنمية المحلية بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية.
- بالإضافة إلى ذلك يتطلب إنجاز عملية إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي ضمان إتصال دائم مع البرلمان والمسؤولين المحليين يكون وفق مجموعة من الإجراءات يمكن إيجازها في ما يلي:

1- على مستوى العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني:

- يمكن إجمال الإجراءات والصيغ التي تضمن التواصل بين البرلمان والمجتمع المدني في ما يلي:
- وجود سجل عام متاح للجمهور والمنظمات غير الحكومية، منظم حسب الموضوع ومرتب أبجديا تسجل فيه إهتمامات هذه المنظمات.
- وجود سجل خاص بالخبراء.
- القيام بدعاية فعالة بإستخدام وسائل الإعلام لتبليغ المواطنين بمشاريع القوانين و جلسات الإستماع البرلمانية.
- توجيه دعوات إلى المنظمات والخبراء المعنيين لطرح إنشغالاتهم وتقديم ملاحظاتهم.
- إتخاذ الإجراءات التي من شأنها إتاحة الفرصة للمواطنين كأفراد للتعبير عن مشاكلهم وإنشغالاتهم.
- وجود سجل عام على شبكة الأنترنت، تسجل فيه كل الملاحظات المقدمة.
- تنظيم جلسات إستماع في المراكز المحلية، وإعداد ملخصات مكتوبة لإقتراحاتهم الشفوية.

2- على المستوى المحلي:

- أما على المستوى المحلي، فينبغي تدعيم الديمقراطية التشاركية بإدخال إصلاحات عميقة تمكن تنظيمات المجتمع المدني من أن تقوم بدور أكبر أهمها:
- تدعيم آليات التواصل بين منظمات المجتمع المدني والإدارة المحلية بشكل يضمن مشاركتها الفعالة في القرارات المتعلقة بمجالات اختصاصاتها.
 - إعطاء دور أكبر للجمعيات في عملية تشكيل المجالس المنتخبة.
 - تعزيز دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
 - التقليل من وصاية الإدارة على الجمعيات.
 - ضمان إستقلالية الجمعيات بإعتماد معايير شفافة في ما يتعلق بالدعم المالي.
 - إلزام الإدارة المحلية بضرورة إعلام تنظيمات المجتمع المدني بكل ما يتعلق بتسيير الشأن العام.
 - إعطاء دور أكبر للجمعيات في إعداد برامج التنمية المحلية.
- و في الأخير، جاءت الديمقراطية التشاركية لمعالجة إختلالات الديمقراطية النيابية، حيث سمحت بإشراك مختلف الفاعلين و خاصة منظمات المجتمع المدني في إدارة و تسيير الشأن العام، من خلال القيام بدورها في تمثيل شرائح واسعة من المواطنين وطرح إنشغالاتهم والمساهمة في سن القوانين المؤطرة لحياتهم ورسم السياسات العامة والعمل على إرساء الشفافية والمساءلة والرقابة.

الرقابة الإدارية

مقدمة:

تعتبر وظيفة الرقابة الجانب الأخير من العملية الإدارية، حيث تكتمل بوضع نظام رقابي فعال يضمن تحقيق مستوى مستمر و مرضي من الأداء، و تتمثل هذه الوظيفة في مقارنة ما تم تنفيذه حسب الخطط المسطرة، و إتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية عندما ينحرف عن الأداء الفعلي أو المخطط.

أولاً: تعريف الرقابة الإدارية:

تعتبر من الوظائف الإدارية، و تعني قياس و تصحيح أداء المرؤوسين للتأكد من أن الأهداف و الخطط المسطرة قد تم تنفيذها بشكل مرضي، كما تعني الإشراف و المراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير الأعمال و مراجعتها وفقاً للخطط الموضوعة.

ثانياً: مجالات الرقابة الإدارية:

01- الرقابة على الموارد المادية:

إن الرقابة على الموارد المادية تشمل بعض النواحي مثل الرقابة على المخزون بهدف المحافظة على توازنه حتى لا تكون كمية المخزون أقل من اللازم أو أكثر من اللازم وتشمل أيضاً الرقابة على الجودة لضمان تطابق السلع المنتجة.

02- الرقابة على الموارد البشرية:

تتضمن مراقبة النشاط بإختيار الموظفين و وضعهم في المناصب الملائمة لهم و تدريبهم، و وضع معايير لتقييم أدائهم.

03- الرقابة على الموارد الإعلامية:

إن الرقابة على المعلومة و خاصة عند الحصول عليها في الوقت المناسب، تساعد على إتخاذ القرار و عملية الإستشراف.

04- الرقابة على الموارد المالية:

تعتبر من أهم أشكال الرقابة حيث ينظر إليها من زاويتين، الأولى تكون على الموارد المالية نفسها من حيث تدبير القدر الكافي من الأموال اللازمة للإنفاق على نشاط المؤسسة، الثانية تكون على جميع الموارد الأخرى للمؤسسة و التي تحتاج إلى موارد مالية.

ثالثا: صور الرقابة الإدارية:**01- الرقابة الوصائية:****أ- تعريفها:**

الوصاية في القانون المدني هي وصاية على ناقص الأهلية فالصبي غير المميز يباشر مصالحه بوصي عليه، أما الوصاية في القانون الإداري تعني وجود جهة وصية تتابع أعمال الجهة الموصى عليها و هذا لتحقيق الشرعية، فالجماعات المحلية باعتبارها شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية إدارية تامة و كاملة، لكن تصرفاتها محدودة بالوصاية على الأعمال لا على الأشخاص بصفتها جهاز لامركزي، و عليه فالإدارة سواء كانت مركزية أو لا مركزية هدفها تحقيق المصلحة العامة و كل تصرف مغاير لهذا الهدف يعتبر باطلا يخضع للرقابة الإدارية.

ب- أركان الرقابة الوصائية :

ترتكز على ركنين أساسيين هما:

- الشرعية.

- المصلحة العامة.

ج- صور الرقابة الوصائية:

قد تكون الرقابة الوصائية مطلقة أو نسبية، فالوصاية المطلقة تعني خضوع كل الأشخاص الموجودين على مستوى الجهاز الإداري (مركزي أو لا مركزي) للوصاية، فكلما زاد عدد الأشخاص كلما تكون الرقابة أشد حتى تأخذ شكل من أشكال البيروقراطية، و منه كل هيئة إدارية تخضع لوصاية مطلقة معناه لا وجود لاستقلال مطلق.

د- التمييز بين الوصاية الإدارية و الوصاية المدنية :

رغم أن مصطلح الوصاية من أصل و منشأ مدني، إلا أنه في المجال الإداري له مفهوم خاص يختلف اختلافا كبيرا عن مفهومه السائد في القانون الخاص، و المتمثل فيما يلي:

- إن الوصاية المدنية تقرر في القانون الخاص لناقصي الأهلية و هم المشمولين بالوصاية أما الوصاية الإدارية فلا يرجع تقريرها إلى نقص في أهلية الشخص اللامركزي سواء كان في شكل إدارة محلية (ولاية أو بلدية) أو مرفق مستقل، لأن هذه الهيئات جميعا واستنادا

للمادة (49) من القانون المدني تتمتع بوجود قانوني مستقل عن الشخص المعنوي الأم ألا و هي الدولة، و هذا الاستقلال يمكنها من صلاحية تسيير شؤونها بيدها دون الرجوع إلى السلطة المركزية و قررت هذه الوصاية بغرض حماية المصالح العامة ومحاولة بعث نسق إداري موحد في العمل الإداري، و هذا المحور بدا واضحا في تعريف الفقه لنظام الوصاية الإدارية .

- طبقا لمفهوم الوصاية في المجال المدني يتولى الوصي صلاحية مباشرة أي عمل و ينتج آثاره القانونية إذا تم في الحدود التي رسمها القانون، و يسري هذا التصرف كما لو قام به المعني (القاصر) كأنه كامل الأهلية، فنحن أمام شخص واحد يملك سلطة التصرف و إن كنا من حيث الشكل نلاحظ شخصين قاصر و وصي عليه بينما في المجال الإداري فنحن أمام شخصين قانونيين مستقلين يملك كل واحد منهما سلطة التصرف باسمه و لحسابه بالكيفيات و في الإطار الذي حدده القانون ، فلا يتصرف شخص باسم شخص آخر .

- يواصل الوصي في المجال المدني أعماله باسم و لحساب القاصر طالما كان نائبا قانونيا عنه، بينما في الوصاية الإدارية يتولى النائب مباشرة جميع الأعمال باسم الشخص المعنوي المستقل.

- إن الوصاية في المجال المدني تهدف إلى حماية المال الخاص هو مال من كانت أهليته مفقودة، بينما الهدف من الوصاية في النظام الإداري هو حماية المال العام.

هـ - مظاهر الرقابة الوصائية التي تمارسها الإدارة المركزية على الإدارة المحلية:

سبق البيان أن اللامركزية لا تعني الإستقلال التام المطلق للهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية وإنفصالها عن السلطة المركزية، وهي لا تعني أيضا الخضوع والتبعية، بل تعني تمتع الجماعات المحلية بقدر من الاستقلال في ممارسة مهامها إزاء الإدارة المركزية مع خضوعها لنوع من الرقابة أطلق عليها اصطلاحا بالرقابة الوصائية، وتتجلى مظاهر هذه الرقابة في مجالات ثلاثة، رقابة على الأشخاص، رقابة على الهيئة ورقابة على الأعمال.

- **الرقابة على الأشخاص:** إن استقلالية الجماعات المحلية لا تمنع قانونا السلطة المركزية من ممارسة الرقابة على الأشخاص المشرفين على التسيير على المستوى المحلي فتملك السلطة المركزية صلاحية تعيينهم، نقلهم و تأديبهم كالولاة و المديرين التنفيذيين على

مستوى الولايات، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز وقفهم أو إقصائهم من المجالس المنتخبة وفق الكيفيات و الإجراءات المحددة قانونا.

- **الرقابة على الهيئة:** تملك السلطة المركزية صلاحية الحل على الهيئة ويقصد به الإعدام القانوني للمجلس وتجريد الأعضاء من صفتهم (كمنتخبين)، ونظرا لخطورة هذا الإجراء فقد تم ضبطه من حيث الجهة المختصة بممارسته، كما تم رسم وتبيان حالاته وإجراءاته، وتملك السلطة المركزية أيضا حق دعوة المجلس للإنعقاد في دورة إستثنائية وتساهم في دعمه ماليا في حالة العجز.

- **الرقابة على الأعمال:** تتجلى هي الأخرى في المصادقة، الإلغاء و الحلول.

• **المصادقة:** أوجبت مختلف قوانين الإدارة المحلية إخضاع بعض قراراتها لتزكية السلطة المركزية وقد أطلق على هذا الإجراء بالمصادقة، وقد تكون صريحة أو ضمنية وفق ما ينص عليه القانون.

نكون أمام مصادقة صريحة عندما تلجأ السلطة المركزية أو جهة الوصاية إلى إصدار قرار تفصح فيه صراحة عن تركيتها لقرار صادر عن الجهة التابعة لها وصائبا أما المصادقة الضمنية فتكون عندما تلتزم سلطة الإشراف الصمت إزاء العمل أو القرار المعروض عليها، وقد اعتبرت المحكمة العليا في الجزائر أن للقرار الضمني نفس آثار القرار الصريح.

• **الإلغاء:** إن مقتضيات النظام اللامركزي تفرض على سلطة الإشراف إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية، وحتى لا يحدث الإصطدام بين الجهاز المركزي و الجهاز المحلي عادة ما نجد القانون يتدخل لحصر حالات معينة يتمكن بموجبها الجهاز المركزي من إلغاء قرارات تم إتخاذها على المستوى المحلي و كانت مشوبة بعيب في المشروعية.

• **الحلول:** إن سلطة الوصاية لا تمارس رقابتها فقط على الأعمال الإيجابية التي تصدر عن الهيئة المستقلة المحلية و لكنها تراقب أيضا الأعمال السلبية لهذه الهيئات عندما تبادر إلى القيام ببعض واجباتها التي فرضت عليها قانونا، وقد اصطلح على تسمية هذا العمل القانوني بالحلول، حيث يقصد به حلول السلطة المركزية أو سلطة الوصاية محل السلطة اللامركزية في إتخاذ القرارات التي تؤمن و تضمن سير المصالح العامة.

يتضح من خلال هذا التعريف أن الحلول يعد إجراء خطير لذا وجب أن يقيد هو الآخر من حيث الإختصاص و الإجراءات و من حيث الموضوع، و الحكمة من إقرار هذا الإجراء تكمن في التوفيق بين المصالح المحلية التي فرضت الإعتراف بالشخصية المعنوية للسلطات اللامركزية وبين فكرة المصلحة العامة التي تبقى بمعزل عن الخلافات المحلية، كما يجب تأمين المصالح المحلية ضد كل تقاعس قد يحدث من جانب السلطات المحلية خاصة إذا تعلق الأمر بمسائل تمس النظام و الأمن العموميين، لذا وجب على السلطة الوصية أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن أداء عمل معين رعاية للمصلحة العامة وهذا تحت عنوان الحلول ضمن الأشكال التي حددها القانون.

ومن هنا فإن نظام الوصاية أداة قانونية بموجبها نضمن وحدة الدولة و ذلك بإقامة علاقة قانونية دائمة ومستمرة بين الأجهزة المستقلة والسلطة المركزية، كما أنه يكفل للهيئات المستقلة حقها في إتخاذ القرار بالكيفية و الحدود التي رسمها القانون.

02- الرقابة الرئاسية:

أ- تعريفها:

هي رقابة الرئيس على مرؤوسيه و يلتزم بموجبها المرؤوس بتنفيذ قرارات الرئيس، أو هي مجموعة من الإختصاصات يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطون به برابطة التبعية و الخضوع.

ب- مظاهر السلطة الرئاسية:

- سلطة الرئيس على شخص المرؤوس: تتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس، ترقيته، تحويله وتأديبه وهذه السلطة ليست إمتيازاً للرئيس وإنما نوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون، ما دام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائياً متى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءة إستعمال السلطة.

- سلطة الرئيس على أعمال المرؤوس: تتمثل في التوجيه، الرقابة و التعقيب.

ج- التمييز بين الوصاية الإدارية و السلطة الرئاسية:

تختلف الوصاية الإدارية عن السلطة الرئاسية من عدة نواحي أبرزها:

- من حيث أداة ممارسة الرقابة: إن رقابة الجهة الوصية (سلطة الوصاية) يجب أن تكون منصوفا عليها قانونيا، أي رقابة الإشراف لا تمارس ولا يكون لها وجودا إلا إذا نص عليها القانون الذي يتولى إثبات سلطة الإشراف ويبين عناصرها وأدواتها القانونية ذلك أنه لا وصاية دون نص، وهذا خلافا للرقابة الرئاسية التي لا تحتاج ممارستها إلى نص، فهي تمارس بصفة تلقائية لأنها من موجبات النظام المركزي الذي يقوم على فكرة السلطة الرئاسية ويحدث علاقة من التبعية والخضوع بين الرئيس الإداري والمروؤوس وهو ما أكدته نصوص الوظيفة العمومية.

- من حيث طبيعة الرقابة: إن الرقابة الرئاسية، رقابة معقدة تحكمها كثيرا من الآليات القانونية حيث تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله من إصدار الأوامر إلى مروؤوسيه سواء كانوا في الوزارة أو غيرها من الوحدات الإدارية و ذلك بغرض تنفيذها، كما أنه يراقب هذا التنفيذ، أما سلطة الوصاية فهي رقابة بسيطة من حيث الإجراءات و الممارسة لأنها من موجبات النظام اللامركزي الذي لا يمكن سلطة الوصاية من حيث الأصل من فرض أوامرها و توجيهاتها بحكم إستقلالية الهيئة المحلية أو المرفقية.

- من حيث الطعن: لا يستطيع المروؤوس في النظام المركزي أن يطعن في قرار رئيسه الإداري بسبب السلطة الرئاسية، وهذا ما أقره القضاء الفرنسي حيث لا يعقل أن نعترف من جهة للرئيس الإداري بسلطة إصدار الأوامر والتوجيهات للمروؤوسين بغرض تنفيذها، ثم نعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطعن في الأوامر القضائية ومساءلة رؤسائهم أمام السلطة القضائية، وخلاف ذلك يجوز للهيئة المحلية أن تطعن قضائيا في قرار الجهة المركزية.

- من حيث قواعد المسؤولية: من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس عن أعمال المروؤوس لأنه يفترض فيه أنه هو مصدر القرار وأن له حق الرقابة والإشراف والتوجيه، بينما لا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل.

المنازعات الإدارية

مقدمة:

النشاط الإداري هو أقدم نشاط في الدولة وهذا باتفاق فقهاء القانون العام الذين يرون بأنه لا يمكن تصور دولة بدون تشريع ولا قضاء، ولا يمكن تصور دولة بدون إدارة باعتبار أن النشاط الإداري أقدم من حيث الظهور من التشريع و القضاء.

كما أن هذا النشاط أو العمل الإداري يخضع لرقابة قضائية شبه تامة إثر سيادة مبدأ المشروعية الذي تقوم عليه الدولة الحديثة و الذي يعني أن تكون جميع أعمال و نشاطات وتصرفات الإدارة في حدود القانون.

إن عدم تكريس مبدأ تحديد الاختصاصات الإدارية للسلطات المركزية و اللامركزية دون تحديد قانوني لإختصاصاتها وحدودها يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وثمة تمييز للمسؤوليات، والذي من شأنه توليد فوضى فتكون الضحية الأولى هي المصلحة العامة، لذا نجد الدستور ثم التشريع والتنظيم، كل يحرص على مستواه، على تحديد الاختصاصات المقيدة للسلطات الإدارية و وسائل تجسيدها تحقيقا للمصلحة العامة من جهة، ويساعد ذلك كل من الأشخاص والقضاء على مراقبة الإدارة في أدائها لوظيفتها الإدارية دون المساس بحريات وحقوق المواطنين إتجاه نشاط الإدارة غير المشروع أو غير الملائم، من جهة أخرى.

وعليه يمكن القول بأن قانون المنازعات الإدارية يعني مجموعة القواعد القانونية المحددة للنزاع الإداري والهيئات القضائية المختصة للفصل فيه على ضوء قواعد شكلية وموضوعية خاصة، كما يحمي المواطن من تعسف الإدارة خاصة أنها تتمتع بإمتميازات السلطة العامة وصلاحيات إستعمالها للبند (أو الشرط) غير المألوف.

أولاً: تعريف النزاع الإداري:

المشرع الجزائري لم يعرف النزاع الإداري و إنما على حد تعبير أساتذة القانون العام، فإن القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، إعتد كأصل عام في تحديده على المعيار العضوي والذي على ضوئه يحدد مجال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية و مجلس الدولة على النحو الآتي:

أ- المحاكم الإدارية:

هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرف فيها، ما عدى مخالقات الطرق والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للهيئات المذكورة أعلاه، حيث يتولى الإختصاص في الفصل فيها للمحاكم العادية المواد (800 و 802) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

كما تختص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية و المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.

- وتختص كذلك بالفصل في دعاوى القضاء الكامل، وفي القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة حسب المادة (801) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

ب- مجلس الدولة:

يختص بالفصل في إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية حسب المادة (902) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

- ويختص كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.

- كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة كما جاء في المادة (901) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

من خلال المواد المذكورة أعلاه، نستنتج أن المشرع الجزائري حدد أو عرف النزاع الإداري معتمدا على المعيار العضوي والذي يتمثل في أن كل نزاع يكون أحد أطرافه من الأشخاص المذكورين في المادة (800) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أعلاه، يعد نزاعا إداريا، يعود الإختصاص للفصل فيه للهيئات القضائية الإدارية المتمثلة في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة حسب الحالة.

ثانيا - الدعوى :

هي إجراء لحماية المصلحة، يقوم بها صاحب الحق أمام القضاء العادي أو الإداري ويختلف الحق عن الدعوى من حيث:

أ- **السبب:** فالحق قد يكون سببه العقد أو واقعة معينة، أما الدعوى فسببها المنازعة حول الحق بين المدعي و المدعى عليه، ضف إلى ذلك أنه في الواقع الحق الواحد قد تتولد عنه جملة من الدعاوى عند الإعتداء عليه مثل دعوى الإستحقاق و دعوى التعويض.

ب- **الخصومة:** عند مباشرة أو ممارسة الدعوى تظهر مجموعة من الإجراءات من وقت تسجيل عريضة الدعوى إلى زمن صدور الحكم في موضوعها أو إنقضائها تسمى هذه الإجراءات في كلمة واحدة هي "الخصومة".

ثالثا - شروط قبول الدعوى :

حسب نص المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية جمعها الفقهاء و التشريع في شرطين:

أ- **المصلحة:** ما دامت غاية الدعوى هي حماية الحق فإن نقطة بدايتها هي وجود المصلحة التي هي الضابط المحرك لقبول الدعوى أي الفائدة الدافعة لرفع الدعوى، شريطة أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

ب- **الصفة:** معناه أن يكون رافع الدعوى صاحب الحق نفسه أي المطالبة الذاتية أو له سلطة قانونية للتقاضي عن غيره (التوكيل أو التفويض)، كما يثير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه، و إنعدام الإذن إذا ما إشتطره القانون.

رابعا -الدعوى الإدارية و مجالاتها :

بعد صدور دستور 28 نوفمبر 1996 المعدل بالقانون 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري الذي كرس مبدأ إزدواجية القضاء الجزائي مسائرا بذلك النظام القضائي الفرنسي من خلال الفصل ما بين القضاء العادي والقضاء الإداري حيث تم إنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية لتكريس هذا المبدأ ميدانيا وعمليا ضف إلى ذلك إستحداث القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي أصبح ساري المفعول منذ 24 أبريل 2009، الذي ينص

على أن تخضع جميع الإجراءات ذات الطابع القضائي الإداري أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

1- مجال اختصاص مجلس الدولة:

حددت المواد (901،902،903) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة على النحو الآتي:

أ- كدرجة أولى وأخيرة: بحيث يختص مجلس الدولة بالفصل بصفة ابتدائية ونهائية في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية التي تعمل باسم و لحساب الدولة (رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزراء.....)، والهيئات العمومية الوطنية (كالمجالس المتعلقة بالمرأة، التربية والشباب) والتي تتكفل بمجالات مختلفة، وكذا قرارات السلطات الإدارية المستقلة (المجلس الوطني الاجتماعي والإقتصادي، المجلس الوطني للشباب، المجلس الأعلى للإعلام، المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للغة الأمازيغية، المجلس الدستوري...) كون هذه الهيئات سلطات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.

ب- كجهة إستئناف: يفصل مجلس الدولة كدرجة ثانية بالفصل في إستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، وهنا يتمتع المجلس بجميع صلاحيات قضاء الإستئناف، أي إعادة دراسة الملف من حيث الوقائع و القانون معا، كمحكمة موضوع.

ج - الطعون بالنقض: يختص بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، وكذا في الطعون بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة، والذي نظمه الأمر 20/95 المعدل و المتمم بالأمر 02/10 المتعلق بمجلس المحاسبة.

2 - مجال اختصاص المحاكم الإدارية:

بناء على ما جاء في المادة (800) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة (01) من القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، تعد المحاكم الإدارية جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، فهي تختص بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، كما تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:

- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية، ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:

* الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،

* البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،

* المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.

- دعاوى القضاء الكامل.

- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

باستثناء مخالفات الطرق والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسب المادتين (801،802) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

ويتحدد الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية حسب المادتين (37، 38) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموطن المدعى عليه أو الجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، إن لم يكن له موطن معروف، وفي حالة إختيار موطن يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها لموطن أحدهم.

وحسب المادة (804) وخلافا لأحكام المادة (803)، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه:

1- في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم.

2- في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع دائرة إختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.

3- في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه.

4- في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان التعيين.

5- في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان تقديم الخدمات.

6- في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به.

7- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جنائية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان وقوع الفعل الضار.

8- في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.

و يمكن القول بأن الإختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام يجوز إثارة الدفع بعدم الإختصاص من قبل القاضي تلقائيا أو من أحد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. المادة (807) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

خامسا: أنواع الدعاوى الإدارية.

يجب أن تتضمن عريضة إفتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية:

- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
- اسم ولقب وموطن المدعي.
- اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فأخر موطن له،... إلى غير ذلك من البيانات (المذكورة أدناه). ويجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام.
- تحدد العريضة الجهة القضائية الإدارية المرفوعة أمامها الدعوى.
- يجب أن تتضمن هوية المدعي و هوية المدعى عليه كالاسم، اللقب و الموطن.

- يجب الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي.

- يجب أن تتضمن هذه العريضة عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى مع الإشارة، عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى طبقا لأحكام نصي المادتين (15 و 816) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

- ويحق للمتقاضي أن يلجأ مباشرة أمام مجلس الدولة بموجب عريضة إفتتاحية نزاعية في حالة الطعن بالإلغاء أو التفسير أو تقدير (فحص) مدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية (المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المجلس الدستوري، المجلس الإسلامي الأعلى.... إلخ) أو المنظمات المهنية الوطنية (الإتحاد العام للعمال الجزائريين، إتحاد التجار الجزائريين، نقابة القضاة، المنظمة الوطنية للمحاميين)، شريطة إيداعها وجوبا لدى أمانة ضبط مجلس الدولة في الآجال القانونية مع التنويه في هذا الصدد أن شرط التظلم المسبق (الاحتجاج) أصبح جوازي و لم يعد وجوبي.

فحسب نص المادة (905) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فإنه يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة إلخ)، أما المادة (907) من نفس القانون، فإنه عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من (829 إلى 832) من نفس القانون.

ومن بين أهم الدعاوى الإدارية التي تناولها النظام القانوني الجزائري ما يلي:

1 - دعوى الإلغاء:

نصّت عليها المادة (801) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالنسبة لإختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية..... الصادرة عن الولاية والبلدية والمصالح الإدارية التابعة لهما وعن المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.

بالإضافة إلى المادة (901) من القانون التي نصت على إختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية

المركزية، ضف إلى ذلك المادة (09) من القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة، حيث أنه بالرجوع إلى هذه النصوص القانونية نجد أن المشرع وظف عدة مصطلحات لمعنى واحد، فتارة يستعمل دعاوى الإلغاء وتارة الطعون بالإلغاء، فالمقصود من هذه المواد هي دعاوى تجاوز السلطة الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية في الدولة سواء الوزارات أو الجماعات المحلية من أجل إلغائها من قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعيتها كونها مشوبة بأحد عيوب حالات تجاوز السلطة، لحماية المركز القانوني للمدعي الذي مسه هذا القرار بصفة سلبية وبالتالي حماية مبدأ المشروعية.

ودعوى الإلغاء متشعبة المجال والإجراءات إذ تشمل كثيرا من المجالات مثل المجال الانتخابي، المجال المهني، المجال العمراني و المجال المالي..... إلخ. ودور القاضي يقتصر على إلغاء العمل الإداري أصلا كما يمكنه فضلا عن الإلغاء، التعويض عن الأضرار الناجمة عنه بناء على طلب المدعي وفي حالة ما إذا كانت دعوى الإلغاء من إختصاص مجلس الدولة.

2 - دعوى التفسير و دعوى فحص (تقدير) مشروعية القرار الإداري:

نصت عليها المواد (801،901،965) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة (09) من القانون العضوي رقم 98/03 المتعلق بمحكمة التنازع :

أ- دعوى تفسير القرار الإداري: تتحرك هذه الدعوى في حالة صدور قرار إداري مهما كان نوعه أو مصدره يكتنفه الغموض وعدم الوضوح، يحتمل أكثر من تأويل، فهنا لمن له مصلحة أن يرفع دعوى تفسير القرار الإداري أمام القاضي الإداري المختص نوعيا وإقليميا طالبا إفادته بالمعنى الحقيقي أي بالمعنى القانوني السليم الذي قصده المشرع، فدور القاضي في هذه الدعوى هو النطق بالمعنى الحقيقي والأصلي للقرار الإداري المطلوب تفسيره فقط.

ب- دعوى فحص مشروعية القرار الإداري: هذه الدعوى مفادها أن صاحب المصلحة يطلب من خلال رفعه لهذه الدعوى من القاضي الإداري المختص نوعيا وإقليميا فحص أو تقدير مدى مشروعية القرار، أي هل هذا القرار الإداري مطابق ومتفق مع أحكام القانون أم لا، فدور القاضي في هذه الدعوى يقتصر على الإعلان عن مشروعية القرار من عدم مشروعيته ولا يتعدى في الحالة الثانية حالة عدم مشروعيته إلى إلغائه أو تعديله.

ويعود الاختصاص للمحاكم الإدارية بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للإستئناف في دعاوى تفسير وتقدير (فحص) المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن الولاية والبلدية والمصالح الإدارية التابعة لهما وعن المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، بينما يعود الاختصاص لمجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير (فحص) المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية المادة (901) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

3 - دعوى القضاء الكامل:

سميت بدعوى القضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الإدارية، ومن ثمة فهي تشمل مجموعة دعاوى إدارية يرفعها ذوي الصفة و المصلحة أمام القاضي الإداري المختص نوعيا وإقليميا بهدف المطالبة بالإعتراف لهم بحكم قضائي بوجود حقوق (مراكز) قانونية شخصية مكتسبة، والتقرير بأن الإدارة من خلال نشاطاتها أو أعمالها القانونية أو المادية قد مست بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية، ثم تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تلك التجاوزات ثم التقرير بإصلاحها وجبرها وذلك إما بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل على أساس القانون أو بدفع مبلغ مالي مستحق كتعويض عن ذلك والحكم على السلطات الإدارية المدعى عليها بالتعويض أو تثبيت حق مؤسس قانونا.

ومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل دعوى التعويض أو المسؤولية ودعاوى العقود الإدارية التي يكون أحد الأشخاص المعنوية طرفا فيها إلا ما تعلق بالمنازعات المتعلقة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو إحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما جاء في المادة (802) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن الاختصاص يعود للمحاكم العادية.

إن المشرع الجزائري في دعوى القضاء الكامل نص فقط على دعوى التعويض أو المسؤولية عن الأعمال الإدارية الصادرة عن الأشخاص المعنوية العامة عندما تتصرف

باستعمال السلطة العامة أو عند استعمالها للشرط غير المألوف، ويعود الاختصاص فيها إلى المحاكم الإدارية طبقا لنص المادة (02/801) من نفس القانون.

4- الدعوى الإستعجالية في المواد الإدارية:

تهدف لوقف تنفيذ قرار إداري من أجل حماية المراكز القانونية من عواقب التنفيذ التي يصعب تداركها فيما بعد، مع التتويه بأن دعوى وقف التنفيذ ذات طابع خاص متميز لذا فالمرشح قرر لها إجراءات خاصة على أن يتم التحقيق فيها والفصل فيها والتبليغ بصفة عاجلة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب وبكافة الوسائل لحماية حقوق المتقاضين مما قد يصيبها من هلاك أو ضياع حسب المادة (920) وما يليها من نفس القانون.

يستفاد من مضمون هذه النصوص أن الدعوى الإستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإستعجالي الأمر بإتخاذ أحد التدابير التحفظية المؤقتة والعاجلة (الفورية) حماية لمصالحه قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تقاديتها مستقبلا أو معاينة وقائع يخشى إندثارها مع مرور الزمن، كما تجدر الإشارة إلى أن تدابير الإستعجال لم يحددها المشرع على سبيل الحصر وإنما تركها للسلطة التقديرية للقاضي الإستعجالي في الأمر متى تثبت له لزوميتها وذلك في حدود ضوابط اختصاصه النوعي، ومن بين التدابير على سبيل المثال لا الحصر التي يقررها القاضي الإستعجالي ما يلي:

- الأمر بإثبات حالة (عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الإستعجالي للقضية) تطبيقا لنص المادة (925) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كتدبير تحفظي موضوعه معاينة أو وصف وقائع أو حالات مادية وقعت أو على وشك الوقوع يخشى ضياع معالمها بفوات الزمن بإثبات وجود أشغال أو توقيفها أو تقدير القيمة المنجزة منها في مشروع معين أو تعيين خبير لتقدير قيمة العتاد الموجود بالمشروع وطبيعته، أو إثبات حالة تسرب مياه، أو إثبات حالة بضائع على وشك الفساد بسبب صدور قرار إداري بغلق المحل أو منع باخرة من الرسو في ميناء وتفرغ هذه البضائع ... إلخ، و يتم ذلك عن طريق أمر كاتب الضبط (حاليا محضر قضائي) أو خبير مختص و معتمد لتحرير محضر عن ذلك، و قد يتم ذلك عن طريق دعوى إستعجالية إدارية مستوفية لجميع شروط قبولها يطلب المدعي من

خلالها بتعيين خبير مختص من أجل الانتقال إلى مكان وجود الأشغال التي تقوم بها هيئة أو سلطة إدارية ومعاينة الأضرار الناتجة عنها بتحديد مثلا عدد الأشجار المتضررة من هذه الأشغال، نوعها و هل كانت مثمرة أم لا.

- الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل حالة إعتداء مادي أو إستيلاء غير شرعي (غصب) أو حالة الغلق الإداري التي أضافها المشرع، كل ذلك ضمن توفر شروط أو ضوابط الإختصاص النوعي للقاضي الإداري الاستعجالي و المتمثلة في:

أ- وجوب توفر حالة الإستعجال بمعنى أن عنصر الإستعجال قائم، في الحال وأكد، ويكاد يجمع الفقه الإداري على مفهوم الإستعجال يتمثل في الحالة التي يكون فيها الحق مهدد بخطر حال الوقوع أو على وشك الوقوع ومن آثاره إحداث أضرار يصعب تفاديها أو إصلاحها مستقبلا ويبقى تقدير قيام هذه الحالة الإستعجالية للسلطة التقديرية للقاضي الإداري الإستعجالي.

ب- أن التدبير الإستعجالي المطلوب من قبل المدعي لا يمس بأصل الحق، أي لا يمس موضوع النزاع الذي يعود الإختصاص بالفصل فيه لقاضي الموضوع عن طريق مثلا رفع دعوى تجاوز السلطة (إلغاء) أو دعوى التعويض وذلك حفاظا على حقوق أطراف النزاع.

أما الضوابط أو الشروط الخاصة فهي:

- أن لا يتعلق التدبير الإستعجالي المطلوب بالنظام العام و بالخصوص بعنصر الأمن العام.

- أن لا يؤدي التدبير الإستعجالي المطلوب إلى وقف تنفيذ قرارات إدارية بإستثناء المتعلقة منها بالإعتداء المادي أو الإستيلاء غير الشرعي (الغصب) أو الغلق الإداري.

- التسبيق المالي.

- إبرام العقود و الصفقات.

- المادة الجبائية.

القرارات الإدارية

مقدمة:

تملك الإدارة إمتيازات السلطة العامة، ومن أهم مظاهر هذه الإمتيازات إقدام الإدارة على إستخدام سلطاتها في أن تفرض بإرادتها المنفردة قرارات تترتب عنها حقوق والتزامات في مواجهة الغير، دون الحاجة إلى الحصول على رضاهم أو موافقتهم، فهذه السلطة في التصرف الإداري من جانب واحد، تعتبر من أهم مظاهر السلطة العامة للإدارة.

في مجال القانون العام فإن المظهر الجلي و الواضح من مظاهر إمتيازات السلطة العامة هو منح الإدارة سلطة إصدار القرارات الإدارية التي لها قوة ملزمة قانونا، بإرادتها المنفردة لدرجة أن مجلس الدولة الفرنسي إعتبرها القاعدة الرئيسية للقانون العام.

وعليه فإن دراسة القرار الإداري لها أهمية مميزة من جهة، حيث أن القرارات الإدارية تشكل أحد أركان و دعائم القانون الإداري، ومن جهة أخرى تشكل القرارات الإدارية مجالا رحبا لممارسة الرقابة القضائية على عمل الإدارة، بل كانت و ما تزال القرارات الإدارية تشكل محورا لمعظم المنازعات والقضايا المعروضة على القضاء الإداري.

أولاً: مفهوم القرارات الإدارية:

1- تعريف القرارات الإدارية:

أ- التعريف الفقهي:

إختلف الفقه الإداري في إعطاء تعريف للقرار الإداري فعرفه "العميد هوريو" على أن القرار الإداري: تصريح وحيد عن الإرادة صادر عن سلطة إدارية مختصة بصيغة النفاذ بقصد إحداث أثر قانوني،

أما الفقه العربي فيعرفه الدكتور "سليمان الطماوي" بأنه كل عمل صادر عن فرد أو هيئة تابعة للإدارة أثناء أداء وظيفتها.

ب- التعريف القضائي:

استقر القضاء الإداري لفترة طويلة على اعتماد تعريف القرار الإداري، بأنه إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى

القوانين واللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكنا و جائزا قانونا، بهدف تحقيق مصلحة عامة في المجتمع.

ثانيا: خصائص القرار الإداري:

أ- أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية: يشترط في القرار الإداري أن يصدر عن سلطة إدارية وطنية سواء كانت داخل حدود الدولة أو خارجها من دون النظر إلى مركزية السلطة أو عدم مركزيتها.

ب- صدور القرار بالإرادة المنفردة للإدارة: يجب أن يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها، و هو ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يصدر باتفاق إرادتين، سواء كانت هاتين الإرادتين لشخصين من أشخاص القانون العام أو كان أحدها لشخص من أشخاص القانون الخاص.

ج- ترتيب القرار لآثار قانونية: لكي يكون القرار إداريا يجب أن يترتب آثارا قانونية و ذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين، فإذا لم يترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا يعد قرارا إداريا.

ثالثا: تصنيف القرارات الإدارية:

تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة حسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار أو حسب الأساس الذي يقوم عليه التقسيم:

1- القرارات الإدارية من حيث التكوين (قرارات بسيطة و قرارات مركبة):

تنقسم القرارات الإدارية من حيث التكوين إلى قسمين هما، القرارات البسيطة أو المستقلة و هي تلك القرارات التي تتميز بكيان مستقل و تستند على عملية قانونية واحدة غير مرتبطة بعمل قانوني آخر كالقرار الصادر بتعيين موظف أو ترفيقته أو نقله، و هي الصورة الأكثر شيوعا في القرارات الإدارية، أما القسم الثاني فهو القرارات المركبة و هي تلك القرارات التي تدخل في عملية قانونية مركبة تتم في عدة مراحل، و من هذه القرارات قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار إرساء المزداد أو إجراء المناقصة في العقود الإدارية.

2- القرارات الإدارية من حيث آثارها (قرارات منشئة و قرارات كاشفة):

تنقسم القرارات الإدارية من حيث طبيعة آثارها إلى قسمين: قرارات منشئة و هي القرارات التي يترتب عليها إنشاء مراكز جديدة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة تعديلا أو إلغاء، كالقرار الصادر بتعيين موظف عام أو فصله أو معاقبته.

أما القرارات الكاشفة و يقصد بها القرارات التي لا تحدث مركزا قانونيا جديدا، و إنما تقرر حالة موجودة أو تكشف عن مركز قانوني قائم مسبقا، مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو القرار الذي يتضمن تأكيد أو تفسير قرار سابق دون أن يضيف إليه، و يتبين من ذلك أن أثر القرارات الكاشفة تنحصر في إثبات و تقرير حالة موجودة من قبل و لا يتعدى ذلك إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة.

3- القرارات الإدارية من حيث رقابة القضاء (قرارات تخضع للرقابة و قرارات لا تخضع للرقابة):

تنقسم القرارات الإدارية من زاوية خضوعها لرقابة القضاء إلى قرارات تخضع لرقابة القضاء وهذا هو الأصل، وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء وهي القرارات المتعلقة بأعمال السيادة أو تلك التي منعت التشريعات الطعن فيها أمام القضاء.

أ- القرارات الخاضعة لرقابة القضاء.

الأصل أن تخضع جميع القرارات الإدارية النهائية لرقابة القضاء إعمالا بمبدأ المشروعية، و من المستقر وجود نوعين من نظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، الأول يسمى القضاء الموحد، والثاني يسمى نظام القضاء المزدوج.

- نظام القضاء الموحد: يسود هذا النظام في "إنجلترا" والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، ومقتضاه أن تختص جهة قضائية واحدة بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة أو بين الهيئات الإدارية نفسها، وهذا النظام يتميز بأنه أكثر إتفاقا مع مبدأ المشروعية، إذ يخضع الأفراد والإدارة إلى قضاء واحد وقانون واحد، مما لا يسمح بمنح الإدارة أي امتيازات في مواجهة الأفراد بالإضافة إلى اليسر

في إجراءات التقاضي إذا ما قورنت بأسلوب توزيع الاختصاصات القضائية بين القضاء العادي و الإداري في نظام القضاء المزدوج.

- نظام القضاء المزدوج: يقوم هذا النظام على أساس وجود جهتين قضائيتين مستقلتين، جهة القضاء العادي وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم و بين الإدارة عندما تتصرف كشخص من أشخاص القانون الخاص، ويطبق القضاء على هذا النزاع أحكام القانون الخاص، وجهة القضاء الإداري تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة عندما تظهر الأخيرة بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات لا يتمتع بها الأفراد، ويطبق القضاء الإداري على المنازعة قواعد القانون العام، ووفقا لهذا النظام تخضع جميع القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإداري إلغاء و تعويضاً إلا في إستثناءات معينة تتعلق بأعمال السيادة والقرارات التي حصنها المشرع من رقابة القضاء.

ب- القرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء:

القرارات الإدارية التي لاتخضع لرقابة القضاء تتمثل في صنفين، الأول يتعلق بأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية، أما الثاني فيشمل القرارات الإدارية التي يحصنها المشرع من رقابة القضاء لإعتبارات خاصة.

4- القرارات الإدارية من حيث نفاذها في مواجهة الأفراد (قرارات نافذة و قرارات غير نافذة).

تنقسم القرارات الإدارية من حيث أثرها بالنسبة للأفراد إلى قرارات ملزمة للأفراد و نافذة بحقهم، وعليهم إحترامها وإذا قصرُوا في ذلك أجبرُوا على التنفيذ، وهذا الأصل في القرارات الإدارية، وقرارات إدارية يقتصر أثرها على الإدارة وتسمى الإجراءات الداخلية ومنها المنشورات والتعليمات على إختلاف أنواعها، وتعليمات شارحة، أو أمرة أو ناصحة أو مقررّة ومؤكدة، وهذا النوع من القرارات غير نافذ في حق الأفراد وغير ملزم لهم، ولا يحتج بها عليهم، بل إن من القضاء من أنكر على التعليمات صفتها القانونية وإعتبرها من قبيل الأعمال المادية معللين ذلك بأنها موجهة من الرؤساء الإداريين على الموظفين وليس من الواجب على هؤلاء طاعتها ولا يمكن إلزامهم بها إلا بطريق غير مباشر عن طريق العقوبات التأديبية، بيد أن هذا القول لا يمكن الإعتماد به لأن مخالفة التعليمات ينتج عنها بطبيعة

الحال التهديد بالمساس بالمركز الشخصي للموظف، ونعتقد أن هذا كاف لإضفاء طابع العمل القانوني على التعليمات.

5- القرارات الإدارية من حيث مداها أو عموميتها (قرارات تنظيمية، قرارات فردية)

تنقسم القرارات الإدارية من حيث مداها إلى قرارات تنظيمية أو لوائح، وقرارات فردية، ويعد هذا التقسيم من أهم تقسيمات القرارات الإدارية لما يترتب عليه من نتائج تتعلق بالنظام القانوني الذي يخضع له كل من القرارات التنظيمية و القرارات الفردية.

أ- **القرارات التنظيمية:** القرارات التنظيمية هي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجردة تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة، وعمومية المراكز القانونية التي يتضمنها القرار التنظيمي لا تعني أنها تنطبق على كافة الأشخاص في المجتمع، فهي تخاطب فرد أو فئة معينة في المجتمع معينين بصفاتهم لا بذواتهم و هي تتنوع إلى عدة أنواع أهمها:

• **اللوائح التنفيذية:** هي التي تصدرها الإدارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، وهي تخضع تماما للقانون وتتقيد به وتتبعه، فلا تملك أن تعدل فيه أو تضيف إليه أو تعطل تنفيذه.

• **لوائح الضبط:** هي تلك اللوائح التي تصدرها الإدارة بقصد المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة، وهي بالغة الأهمية لتعلقها مباشرة بحياة الأفراد وتقييد حرياتهم لأنها تتضمن أوامر ونواهي وتوقع العقوبات على مخالفيها، مثل لوائح المرور وحماية الأغذية والمشروبات والمحلات العامة.

• **اللوائح التنظيمية:** تسمى أيضا اللوائح المستقلة وهي اللوائح التي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي لم يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع.

• **لوائح الضرورة:** هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان أو السلطة التشريعية لمواجهة ظروف إستثنائية عاجلة تهدد أمن الدولة وسلامتها، فتمتلك السلطة التنفيذية من خلالها أن تنظم أمور ينظمها القانون أصلا ويجب أن تعرض هذه القرارات على السلطة التشريعية في أقرب فرصة لإقرارها.

- **اللوائح التفويضية:** هي القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة أصلا في نطاق التشريع ويكون لهذه القرارات قوة القانون سواء أصدرت في غيبة السلطة التشريعية أو في حالة إنعقادها.
- ب- **القرارات الفردية:** هي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معين بالذات أو أفرادا معينين بذواتهم وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة، مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين.
- التمييز بين القرارات التنظيمية أو اللوائح والقرارات الفردية:**
 - تسري القرارات الفردية على فرد معين بالذات أو أفراد أو حالات معينة بالذات.
 - يسري القرار الفردي من تاريخ إعلان صاحب الشأن به كقاعدة عامة.
 - تخضع الإدارة في سحبها و إلغائها أو تعديلها للقرارات الإدارية الفردية لشروط معينة حددها القانون.

- يختص القضاء الإداري بتفسير القرارات الإدارية الفردية.

رابعاً: عناصر القرار الإداري:

يقوم القرار الإداري على عناصر أساسية إذا لم يستوفها يكون معيباً أو غير مشروع، وقد درج الفقه و القضاء على أنه يجب أن يتوفر في القرار الإداري باعتباره عملاً قانونياً، خمسة عناصر لينتج آثاره ويكون صحيح وهي: الاختصاص، الشكل، السبب، المحل و الغاية.

1- الأركان الشكلية:

أ- **الاختصاص:** إن توزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها نظام القانون العام ويراعى فيها مصلحة الإدارة التي تستدعي أن يتم تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف لأداء المهام المناطة به على أفضل وجه، كما أن قواعد الاختصاص تحقق مصلحة الأفراد من حيث أنه يسهل توجه الأفراد إلى أقسام الإدارة المختلفة ويساهم في تحديد المسؤولية الناتجة عن ممارسة الإدارة لوظيفتها، يقصد بالاختصاص القدرة على مباشرة عمل إداري معين أو تحديد مجموعة الأعمال والتصرفات التي يمكن للإدارة أن تمارسها قانوناً وعلى وجه يعتد به، والقاعدة أن يتم تحديد اختصاصات كل عضو إداري

بموجب القوانين والأنظمة ولا يجوز تجاوز هذه الاختصاصات وإلا أعتبر القرار الصادر من هذا العضو باطلاً.

وقواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام، لذلك لا يجوز لصاحب الاختصاص أن يتفق مع الأفراد على تعديل تلك القواعد، وإلا فإن القرار الصادر مخالفاً لهذه القواعد يكون معيباً بعبء عدم الاختصاص، ويمكن لصاحب الشأن أن يطعن بهذا العيب أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء.

ب: الشكل: الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد، والأصل أن الإدارة غير ملزمة بأن تعبر عن إرادتها بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يتخذ القرار الشكلي المقررة لصدوره، كأن يشترط القانون ضرورة أن يكون القرار مكتوباً، أو استشارة جهة متخصصة قبل إصداره أو تسببيه إلى غير ذلك من أشكال أخرى.

الأركان الموضوعية:

أ: السبب: سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره، فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إستناداً على قرينة المشروعية التي تفترض أن قرارات الإدارة تصدر بناءً على سبب مشروع وعلى صاحب الشأن إثبات العكس، أما إذا أفصحت الإدارة عن هذا السبب من تلقاء ذاتها فإنه يجب أن يكون صحيحاً وحقيقياً، وقد إستقر القضاء على ضرورة توفر شرطين في سبب القرار الإداري:

- أن يكون سبب القرار قائماً و موجوداً حتى تاريخ إتخاذ القرار، ويتفرع من هذا الشرط ضرورتان، الأولى أن تكون الحالة الواقعية أو القانونية موجودة فعلاً وإلا كان القرار الإداري معيباً في سببه، والثاني يجب أن يستمر وجودها حتى صدور القرار فإذا وجدت الظروف الموضوعية لإصدار القرار إلا أنها زالت قبل إصداره فإن القرار يكون معيباً في سببه وصدر في هذه الحالة، كذلك لا يعتد بالسبب الذي لم يكن موجوداً قبل إصدار القرار إلا أنه تحقق بعد ذلك، و إن جاز يكون مبرراً لصدور قرار جديد.

- أن يكون السبب مشروعاً، وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة السلطة المقيدة للإدارة عندما يحدد المشرع أسباباً معينة يجب أن تستند إليها الإدارة لإصدار بعض

قراراتها، فإذا إستندت الإدارة في إصدار قرارها إلى أسباب غير تلك التي حددها المشرع فإن قرارها يكون مستحقا للإلغاء لعدم مشروعية سببه لها.

ب: المحل: يقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة، سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه، ويجب أن يكون محل القرار ممكنا وجائزا من الناحية القانونية، فإذا كان القرار معيبا في فحواه أو مضمونه بأن كان الأثر القانوني المترتب على القرار غير جائز أو مخالف للقانون أيا كان مصدره دستوريا أو تشريعا أو لائحيا أو عرفيا أو مبادئ عامة للقانون، ففي هذه الحالات يكون غير مشروع ويكون القرار بالتالي باطلا.

ج: الغاية: يقصد بالغاية من القرار الإداري، الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه، والغاية عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القرار، فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو تحقيق إستمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه به، والهدف من إصدار قرارات الضبط الإداري هو حماية النظام العام بعناصره الأربعة، السكينة العامة والصحة العامة والأمن العام والآداب العامة، ويمكن تحديد الغاية من القرار الإداري وفقا لثلاثة إعتبارات:

- إستهداف المصلحة العامة.
 - إحترام قاعدة تخصيص الأهداف.
 - إحترام الإجراءات المقررة.
- خامسا - طرق تنفيذ القرارات الإدارية:**

هناك ثلاثة طرق لتنفيذ القرارات الإدارية، هي طريق التنفيذ الإختياري، التنفيذ الإداري والتنفيذ القضائي.

*** التنفيذ الإختياري عن طريق الأفراد:** إن القرارات الإدارية الصادرة من الجهة الإدارية المختصة يلتزم أصحاب الشأن من الأفراد المخاطبين بتنفيذها متى علموا بها، وكلما طلب منهم ذلك مثل تنفيذ قرار منع السير في طريق معين، قرار تسليم شيء أو قرار تقديم خدمات لازمة لتسيير مرفق عام.

*** التنفيذ عن طريق الإدارة تنفيذا مباشرا:** تستطيع السلطة الإدارية عكس الأفراد أن تنفذ قراراتها تنفيذا إداريا (ذاتيا) مباشرا، دون اللجوء أولا إلى القضاء، والتنفيذ الإداري المباشر للقرارات الإدارية هو إمتياز من إمتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة العامة، فهي تستطيع تنفيذ قراراتها النهائية تنفيذا مباشرا دون الإلتجاء سلفا إلى القضاء، كما تستطيع الإدارة تنفيذ قراراتها تنفيذا جبريا ونظرا لخطورة أسلوب التنفيذ الجبري للقرارات الإدارية و الذي يعتبر أسلوبا إستثنائيا فقد إجتهد القضاء الإداري لتحديد حالات إستخدامهمثل الحالات الآتية:

حالة وجود نص صريح في القوانين واللوائح يجبر السلطة الإدارية إستعمال إمتياز التنفيذ الجبري مثل نصوص المتعلقة بكيفية تحصيل الضرائب والرسوم، والنصوص التي تبيح حجز المصبيين بالأمراض العقلية.

حالة رفض الافراد تنفيذ القرارات الإدارية تنفيذا إختياريا مع عدم وجود جزاء مقرر في النصوص لهذا الرفض.

حالة الضرورة والظروف الإستثنائية والإستعجال.

*** التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية:** التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية هو التنفيذ الأصيل المقرر للإدارة العامة لتنفيذ قراراتها في غير حالات التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري، فلإدارة الصفة القانونية في أن تلتجئ للقضاء لإجبار الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية إذا ما إمتنع الأفراد على تنفيذها تنفيذا إختياريا.

فتملك الإدارة حق الدعوى القضائية لإجبار الأفراد على إحترام وتنفيذ القرارات الإدارية وذلك متى وجد نص قانوني يقرر عقوبة لمخالفة القرارات الإدارية وعدم تنفيذها من قبل الأفراد مثال ذلك نص المادة (459) من قانون العقوبات " يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر، كل من من يخالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقب عليها بنصوص خاصة."

سادسا - العيوب التي تشوب القرار الإداري:

يقصد بصحة القرارات الإدارية وسلامتها هنا مشروعيتها وعدم خروجها عن أحكام ومبادئ مبدأ المشروعية الذي يسود الدولة الحديثة.

- **عيب عدم المشروعية:** يقصد بمبدأ المشروعية في معناه العام خضوع الجميع لحكام ومحكومين لسيادة القانون، وأن جميع الأجهزة والسلطات العامة في الدولة يجب أن تلتزم وتخضع في جميع تصرفاتها وأعمالها لحكم القانون في مفهومها العام وكل عمل أو تصرف يخرج عن أحكام ومقتضيات مبدأ المشروعية يكون عملا غير مشروع، ومحلا للطعن فيه بعدم الشرعية، وتقدير النتائج والجزاءات القانونية المترتبة على عدم مشروعيته.

يحقق مبدأ المشروعية حماية خاصة لحقوق الأفراد وحياتهم في مواجهة السلطة العامة، إذ يرتكز على قاعدة جوهرية وأساسية وهي عزل السيادة والسلطة العامة عن رغبات وأهواء الحكام وتقييدهم في ممارستها.

- **عيب مخالفة القانون:** القرارات الإدارية بإعتبارها عملا قانونيا صادرا عن السلطة الإدارية لا بد أن يكون خاضعا لسيادة القانون وذلك تطبيقا لمبدأ حتمية خضوع الإدارة لسيادة القانون، ومشروعية أو سلامة القرارات الإدارية تقوم إذا ما سلمت القرارات في جميع أركانها الخمس من العيوب التالية:

* **عيب السبب:** هو إنعدام الحالة أو الواقعة المادية أو القانونية التي إستندت عليها الإدارة في إصدار قرار معين، وإنعدام السبب (عيب السبب) قد يكون من الناحية العادية أو الواقعية حين تدعي أو تتوهم الإدارة ظروفًا ووقائع مادية خاصة هي التي دفعتها إلى إصدار القرار الإداري، ثم يثبت عدم وجودها في الواقع المادي.

* **عيب عدم الإختصاص:** هو إنعدام القدرة القانونية أو الصفة القانونية على ممارسة وإصدار قرار إداري معين بإسم ولحساب السلطة الإدارية، وتتنوع صور عدم الإختصاص بتنوع صور وعناصر ركن الإختصاص ذاته فقد يكون عيب عدم الإختصاص شخصا إقليميا، موضوعيا أو زمنيا ويتدرج عيب عدم الإختصاص من عيب عدم الإختصاص البسيط إلى عيب عدم الإختصاص الجسيم الذي يتحقق في حالة إغتصاب السلطة والإعتداء الصارخ على الحقوق والحريات العامة للأفراد.

* **عيب الشكل:** يصيب القرار الإداري عيب الشكل إذا لم تتخذ الإجراءات و الشكليات والقوالب التي تطلبها القانون لإصدار مثل هذا القرار مثل إجراء الإخطار وإجراء التحقيق أو أخذ الرأي الإستشاري أو شكلية تحديد الميعاد.

* عيب المحل (مخالفة القانون): يقصد بمخالفة القانون الخروج على القواعد والأحكام والمبادئ الموضوعية للقانون، فيصبح القرار الإداري تبعا لذلك معيبا من حيث مله وفحواه، ويتخذ عيب المحل عدة صور مثل المخالفة الصريحة لحكم القانونين الخطأ في تفسير القانون، الخطأ في تطبيق القانون.

* عيب الغاية أو عيب الإنحراف في استعمال السلطة: يصيب القرار الإداري عيب الغاية أو عيب الإنحراف في استعمال السلطة إذا كان هذا القرار يستهدف غرضا غير الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة إصدار القرار.

فإذا ما شاب القرار الإداري عيبا من هذه العيوب فإنه يفقد مشروعيته ويصبح محلا للطعن فيه أمام الإدارة عن طريق الطعن الإداري أو أمام القضاء الإداري بواسطة الطعون القضائية كالطعن لتجاوز السلطة، الطعن بالتعويض والطعن بطلب فحص الشرعية.

سابعا: نهاية القرارات الإدارية:

يقصد بنهاية القرارات الإدارية إنتهاء كل أثر قانوني لها، وقد تنتهي القرارات الإدارية نهاية طبيعية عندما ينفذ مضمونها، أو تنتهي المدة المحددة لسريانها، أو إستنفاد الغرض الذي صدر لأجله أو يستحيل تنفيذه لإنعدام محله أو وفاة المستفيد منه، إلى غير ذلك من أسباب لا دخل لأي سلطة في تقريرها، و قد تكون نهاية القرارات الإدارية نهاية غير طبيعية بأن تتدخل إحدى السلطات الثلاث لإنهائها كأن يتدخل المشرع أو القضاء لإلغاء القرار، كما قد يصدر قرار الإنهاء من الإدارة وذلك بسحب القرار أو إلغائه.

العقود الإدارية

مقدمة:

يعد العقد الإداري من بين الوسائل القانونية الهامة في ممارسة الإدارة لنشاطها فإذا كان القرار الإداري يعبر عن الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية، فإن العقد الإداري يستوجب توفر إرادتين، إرادة الإدارة و إرادة أحد الأشخاص من الخاصة.

تلجأ الإدارة إلى هذه الوسيلة لتأمين أهدافها المتصلة بالمرفق العام، سواء كان الأمر يتعلق بمشاريع أشغال تريد إنجازها أو ما تحتاجه هذه المرافق من توريدات أو خدمات أو دراسات، و يخضع العقد الإداري لنظام قانوني خاص يختلف عما هو مطبق في مجال العقود الخاصة التي ينطبق عليها القانون المدني أو التجاري.

أولاً: تعريف العقد الإداري:

يمكن تعريف العقد الإداري، على أنه عمل قانوني إتفاقي، تكون الإدارة أحد طرفيه، يكون موضوعه إما إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات لها صلة بالمرافق العامة ويضيف البعض على هذا التعريف شرط أن يتضمن العقد بنود (شروط) غير مألوفة بالنظام القانوني الخاص.

ثانياً: معيار تحديد العقد الإداري:

يمكن تحديد هذه المعايير كالآتي:

1- وجود الإدارة كطرف في العقد: يشترط لوجود العقد الإداري أن تكون الإدارة أحد طرفيه، وعندما نتكلم عن الإدارة كطرف نعني بذلك المعيار العضوي، كالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والثقافي والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والتي تكون الدولة والولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها، ولذلك يجب إستخراج أو إخراج العقود التي تبرمها المؤسسات حتى لو كانت المؤسسة العمومية تابعة للدولة، ولذلك فالمشرع يعتمد على المعيار العضوي بغض النظر عن النشاط، وكذلك يجب إستبعاد المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي كديوان الترقية العقارية. وهذا يستوجب تطبيق المعيار المعتمد لتحديد الإدارة عند دراسة القرار الإداري.

2- أن يتعلق العقد بنشاط مرفق عام: لقد تبنى القضاء الإداري معيار المرفق العام في تحديد العقد الإداري، حيث أنه إذا كان الهدف من العقد هو خدمة عمومية أي منفعة عامة فهذا يمنح للعقد الصفة الإدارية وبالتالي خضوعه للنظام القانوني الخاص بالعقد الإداري وكذا الإختصاص أمام القضاء الإداري في حالته إذا أثير النزاع حوله.

إذن فكل العقود التي تتعلق بالمرفق العام سواء في المجال التنظيمي أو المساهمة في التسيير والإستغلال أو في مجال التوريدات والخدمات وغيرها تعد عقودا إدارية.

3- لجوء الإدارة إلى إستعمال أساليب القانون العام (إمتياز السلطة العامة) البند غير المألوف: المقصود بالبند غير المألوف، أن يتجاوز امتيازات السلطة العامة مثال : وجود دفتر الشروط، فعند لجوء الإدارة إلى إبرام العقد وفق دفتر الشروط فالقضاء يميزها بإستعمال السلطة، إذن كل عقد يتضمن إمتيازات السلطة العامة أو قواعد و شروط غير مألوفة في مجال القانون الخاص يؤدي حتما إلى إعتبار العقد عقدا إداريا، فمثلا إذا قام ديوان التسيير العقاري بإبرام العقد ويكون التمويل من الخزينة العامة، فحسب المعيار العضوي، العقد تجاري وليس إداري، أما حسب المعيار المادي فيعتبر العقد إداري.

- الإختصاص القضائي:

لقد بينت التجارب أن القاضي الجزائري إعتد في كثير من القضايا على المعيار المادي رغم أن المشرع أخذ بالمعيار العضوي، مثال قضية "سمباك"، وعليه فإنه قد إعتد في الجزائر على المعيار العضوي كأساس و المعيار المادي كإستثناء.

ثالثا: أنواع العقود الإدارية:

إنه لا يمكن حصر العقود الإدارية، لكن نأتي بأهمها:

1- عقد الأشغال العامة: هو العقد المبرم بين شخص من أشخاص القانون العام و أحد الأشخاص الخاصة يتبعهم هذا الأخير بموجبه القيام بالأعمال التي لها صلة بالعقار سواء كان الأمر يتعلق بالبناء أو الترميم أو الصيانة لحساب أشخاص القانون العام مقابل ثمن متفق عليه، وبالتالي يجب أن تتوفر بعض الشروط لكي نكون أمام أشغال عامة:

- أن يتعلق العقد بعقار لا بمنقول و أيضا أن يتعلق بعقار بالتخصيص.

- لحساب شخص من أشخاص القانون العام.

- أن يهدف لتحقيق منفعة عامة و ليس مصلحة خاصة.

- لا يهم موضوع الأشغال سواء تعلق بالهدم الحفر أو البناء أو بالهدم.

ويعد عقد الأشغال العامة من أهم العقود الإدارية على الإطلاق نظرا لما لها من أهمية في انجاز المشاريع التي لها علاقة بالمرفق العام وكذلك المبالغ المالية المخصصة والمرصدة لها، لذا أعطيت لهذه العقود أهمية كبرى.

2- عقد التوريد: هو إتفاق بين الإدارة و أحد الأشخاص الخاصة، يتعهد بموجبه هذا الأخير بتوريد سلعة أو منقولات محددة ومرتبطة بنشاط المرفق مقابل الثمن المتفق عليه، ويعد عقد التوريد من العقود الهامة كذلك، و إذا كان الأول متعلق بعقار فعقد التوريد يتعلق دائما بمنقول.

3- عقد الخدمات: هو ذلك العقد الذي تلجأ إليه الإدارة في حالة إحتياجها لبعض الخدمات من قبل الأشخاص الخاصة، و تتمحور هذه الخدمات أساسا في الخدمات ذات الطابع الفني أو الجمالي، كما يمكن للإدارة أن تلجأ إلى عقد الدراسات أو سلطة الدراسات، و سلطة الدراسات أستخدمت بموجب المرسوم الرئاسي 250/02 في 24 جويلية سنة 2002 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، حيث في السابق كانت مدرجة ضمن عقود في المرسوم التنفيذي رقم 434/91 المؤرخ في 09 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

4- عقد البرمجة: عندما يتطلب إنجاز مشروع طويل المدى، ومن أجل إنجازه يتطلب سنوات وإمكانيات مالية ضخمة تعجز الميزانية السنوية للدولة تغطية ذلك الإنجاز بأقساط كل سنة تلجأ الدولة إلى عقد البرمجة.

5- عقد الإمتياز: هو عقد إلترام بحيث أن الإدارة تبرم عقد الإمتياز مع أشخاص خاصة خدمة للمرفق العام ونيابة عن السلطة الإدارية مقابل الرسوم المتفق عليها في إطار ذلك، أي تسيير المرفق العام بطريقة غير مباشرة، حتى وصل الأمر إلى تسيير الجنائز والمقابر من طرف شخص خاص، وقد نص القانون الجزائري على هذا النوع من العقود الإدارية ولكن هذا لا يعني أبدا تتصل السلطة الإدارية من إلتراماتها من تحقق المرفق العام، فهذا التسيير عن طريق عقد الإمتياز خاضع لرقابة السلطة الإدارية في إطار ديمومة المرفق العام وخدمة الصالح العام، وعلى هذا الأساس تملك السلطة الإدارية السلطة التنظيمية ومن خلال ذلك يمكن أن تراقب الملترزم ويمكن حتى أن تحدد في تقديرها الرسوم.

كما تعد الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به.

رابعاً: تنفيذ العقد الإداري:

لقد تبين لنا فيما سبق شرحه أن العقد الإداري يختلف عن العقد المدني من حيث طبيعة أطرافه، فهناك طرف خاص يفتقد إلى هذه السلطة وقد أثر ذلك على تنفيذ العقد خلافاً لما هو معمول به في العقود الخاصة حيث تطبق قاعدة المساواة بين الطرفين وكذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

ففي العقد الإداري نجد أن الإدارة تملك من الوسائل القانونية ما يكفل لها تنفيذ العقد بوسائل إدارية، وهذا لا يعني أبداً التضحية بحقوق المتعاقد معها حيث يملك هذا الأخير بعض الوسائل والضمانات القانونية التي تكفل له حماية حقوقه.

سلطات الإدارة في التنفيذ:

تملك الإدارة عدة وسائل قانونية في مجال تنفيذ العقد ولا نجد لها مثيل في نطاق القانون الخاص، ويمكن جمعها في الوسائل التالية: سلطة الرقابة، سلطة التعديل، سلطة فرض إجراءات (عقوبات)، وسلطة فسخ العقد.

أ- سلطة الرقابة: تتمتع الإدارة بسلطة الرقابة على تنفيذ العقود التي تبرمها إلى حين الإنهاء من تنفيذها، وهذه السلطة يتحدد أساسها في فكرة المرفق العام والصالح العام بإعتبار أن العقد الإداري هو أداة قانونية أساسية لتحقيق المرفق العام، وعلى هذا الأساس تكون الرقابة لإتمام وتحقيق المرفق العام في إطار قاعدة السير المنتظم والمضطر والدائم للمرفق العام، ولذلك يلاحظ أن الرقابة على العقد تتسم بالطابع التنظيمي أكثر مما هو تعاقدية وتملك الإدارة حق الرقابة ولو لم ينص عليها في العقد، ومن أجل ذلك وفي إطار الرقابة تملك الإدارة سلطة إصدار الأوامر إتجاه المتعاقد معها، وتأخذ الأوامر مفهوم القرارات الإدارية و تتمتع هذه الأوامر بالقوة التنفيذية.

كما تملك وسائل مادية وذلك للتحقق من مدى سلامة المواد المستعملة وكذلك إجراء الخبرة في مدى إحترام المتعاقد معها للمعايير والمقاييس المعتمدة في ذلك.

ب- سلطة التعديل للإدارة: إمكانية تعديل عقودها في حدود ما يسمح به القانون أو العقد خلافاً لما هو مبرر في قواعد القانون الخاص، ويجب أن يكون هذا التعديل في إطار

مضمون العقد أو محل العقد حيث لا يجوز للسلطة الإدارية أن تعدل محل العقد كأن تطلب الإدارة توريد البنزين بدل الخضر والفواكه، وأن يكون هذا التعديل مرتبطاً أساساً بمصلحة المرفق العام ومقتضياته مثلاً، يمكن أن تلجأ الإدارة إلى تعديل العقد المرتبط بمحل العقد كأن تطالب المتعاقد إنجاز 15 قسماً بدل من 20 قسماً بشرط أن تقدم الإدارة التعويضات اللازمة للمتعاقد معها، وإذا كان هناك فارق في السعر فالتعديل يجب أن لا يمس موضوع العقد.

ج- فرض عقوبات على المتعاقد معها: لقد إستقر القضاء على أن للإدارة إمكانية فرض عقوبات قد تكون عقوبات إدارية أو مالية، وقد يصل الأمر إلى فسخ العقد في حالة عدم إلتزام المتعاقد بالتزاماته التعاقدية، وقد أكدت على هذه العقوبة المادة (147) من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام عندما نصت "يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الإلتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به".

كما يمكن للإدارة في هذا الإطار أن تلجأ إلى متعهد أو متعاقد آخر لإستكمال تنفيذ العقد و على المتعاقد الأول أن يدفع الفارق في السعر.

إن الهدف من تقرير هذه العقوبة هو تأمين سير المرفق العام بانتظام و إضطراب. و نجد أن تدخل الإدارة في هذا المجال (تطبيق العقوبات) خاضع دائماً لرقابة القاضي في مدى سلامة تلك الإجراءات و تطابقها مع القانون.

د- سلطة الفسخ: يمكن إدراج الفسخ بإرادة الإدارة في البيانات الواجب توافرها في العقد كما قد يؤدي إلى عدم إدراجه حسب المادة (149) من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، يتضمن الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، ومن بين البنود المحددة في العقد شروط فسخ الصفقة المادة (95) من نفس القانون، والفسخ بإرادة الإدارة هو إنهاء الرابطة التعاقدية من طرف الإدارة دون اللجوء إلى إتفاق أو رفع دعوى قضائية.

غير أننا نجد أن المادة (149) من ذات القانون قد منحت للإدارة سلطة الفسخ كقاعدة متى توفرت شروطها حيث نصت على أنه "إذا لم ينفذ المتعاقد إلتزاماته توجه له

المصلحة المتعاقدة معه إعدار ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد. و إن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعدار المنصوص عليه، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد. ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة". بحيث لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة معه بفسخ الصفقة لإصلاح الضرر التي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها.

و لذلك يمكن القول أن تقرير فسخ العقد الإداري من جانب واحد هو مقرر في جميع العقود حتى و لو لم ينص عليه بنود العقد و يجب أن تمارس هذه السلطة في حدود ما ينص عليه القانون بحيث:

أولاً: يجب أن يكون هناك إخلال خطير من جانب المتعاقد معها.

ثانياً: الإعدار، يجب أن تقدم الإدارة أعداراً للمتعاقد من أجل الالتزام بما جاء به العقد في مصلحة تراها ضرورية أو تحددها الإدارة قبل لجوئها إلى فسخ العقد.

2- حقوق المتعاقد مع الإدارة، (التزامات الإدارة): و من أهم التزامات الإدارة في تنفيذ العقود الإدارية، ما يلي:

الالتزام الأول: دفع المبلغ المتفق عليه (حق المتعاقد):

من أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة إلتزام الإدارة بدفع السعر المتفق عليه في العقد و يتحقق ذلك بعد تنفيذ المتعاقد الإلتزامات التعاقدية، أي بعد إنجاز الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدراسات و قد يتم هذا الدفع، إما دفعة واحدة أو عن طريق الأقساط أو الدفع جزئياً عن طريق التسبيق.

و قد تناولت المادة (108) من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، يتضمن الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، هذه المجالات تحت عنوان كفيات الدفع أنه " تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/أو الدفع على الحساب، و بالتسويات على رصيد الحساب. لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و/أو دفع على الحساب أي أثر من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل و المطابق و الوفي للخدمات المتعاقد عليها. و بهذه الصفة، فإن هذه الدفعات لا تمثل تسديدا نهائياً."

أ- **التسبيق:** هو مبلغ مالي يدفع من طرف السلطة الإدارية المتعاقدة قبل تنفيذ العقد و بدون مقابل للتنفيذ المادي للأشغال أو الخدمات أو الدراسات و تطبق هذه الحالة عندما يتطلب تنفيذ العقد مبالغ ضخمة قد تتجاوز الإمكانيات المالية للمتعاقد.

ب- **الدفع على الحساب:** هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة و يكون مرتبطا إرتباطا مباشرا بالخدمة المنجزة (تقديم مبلغ مالي جزئي مقابل الخدمة المنجزة).

ج- **التسوية على الحساب:** و هو الدفع المؤقت أو النهائي للمبلغ المتفق عليه في العقد، و عادة ما يتحقق ذلك بعد التنفيذ الكامل لموضوع العقد.

- الإلتزام الثاني: تحقيق التوازن المالي للعرض من جراء تنفيذ الإلتزام:

إن الهدف الأساسي الذي يريد أن يصل إليه المتعاقد مع الإدارة هو الحصول على مال من جراء تنفيذ العقد أو الخدمة والذي يتحدد أساسا بما أئفق عليه و هو غير قابل للتعديل بالزيادة أو النقصان، غير أنه في بعض الظروف تواكب و تسير مرحلة تنفيذ العقد، و هذه الظروف قد تجعل المتعاقد مع الإدارة في وضعية صعبة بحيث تؤثر على إتمام تنفيذ العقد تنفيذا سليما بسبب زيادة في الأعباء المالية المترتبة عن هذا الظرف، و قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إستحالة تنفيذ العقد .

و نظرا لإرتباط العقد بالمرفق العام و تحقيق النفع العام و الصالح العام فقد إستقر على أنه من الضروري تحقيق التوازن المالي للعقد ليستمر المتعاقد في تنفيذ العقد و تحقيق أهدافه مما يتطلب من الإدارة أن تتحمل الزيادة في الأعباء و قد إعتد القضاء أساسا على نظريتين في هذا المجال و هي نظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة.

أ- نظرية فعل الأمير (نظرية قضائية محضة):

يطلق على هذه النظرية أيضا نظرية المخاطر الإدارية، بمعنى أن يصدر من الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر قرار من شأنه أن يؤدي إلى تعديل شروط العقد أو ظروف تنفيذه كإصدار قانون أو لائحة أو قيام الإدارة بأشغال عامة من شأنها أن تعرقل تنفيذ العقد أو أن تلحق أضرارا مادية بالمتعاقد مع الإدارة أثناء تنفيذ العقد و إستنادا إلى نظرية فعل الأمير فإن المتعاقد المتضرر يستحق تعويضا عن تلك الأضرار، مثل المتعاقد مع الإدارة كالتموين بالكهرباء بطريق الأعمدة التي تمر من طريق الأشغال و بعدها غيرت مسار الأعمدة و لكن وضعت الإدارة مولد كهربائي.

و يشترط لتطبيق نظرية فعل الأمير (المخاطر الإدارية) ما يلي:

- أن نكون بصدد تنفيذ عقد إداري و بالتالي لا مجال لتطبيق هذه النظرية في مجال العقود الخاصة التي تبرمها الإدارة.

- أن يكون هذا الإجراء أو العمل صادر عن السلطة الإدارية أي الإدارة المتعاقدة.

- أن يكون هذا الإجراء غير متوقع وقت إبرام العقد و لو كان متوقعا لاستدرك المتعاقد و طلب تعويضات بالسعر الذي يقترحه، أما إذا كان التعديل محدود و لا يؤثر تأثيرا كبيرا فهو أمر متوقع .

- أن يؤدي هذا الإجراء إلى أضرار مالية يخل بالتوازن المالي للعقد، و هذا الضرر قد مس فقط المتعاقد و ليس ضررا عاما، و لو كان يمس الجميع يمكن أن نؤسس تحقيق التوازن المالي للعقد على أساس سبب آخر الذي هو الظروف الطارئة، و أن لا يشكل هذا الإجراء خطأ إداريا و إلا إعتمد تدخل الإدارة و تأثيرها على العقد بسبب خطأ إرتكبته فلا يمكن الإعتماد على نظرية المخاطر الإدارية بل يتطلب تحميل التعويضات على أساس الخطأ.

أمثلة: تعديل العقد بكيفية يؤثر على تنفيذ العقد و تتحمل الإدارة المسؤولية الإدارية ليس على أساس الخطأ كأن تطلب من المتعاقد انجاز 21 قسما مدرسي بدلا من 20 قسم 20,000 طنا بدلا من 10,000 طنا، و يمكن أن تتدخل في الإجراءات المادية، وقد يصدر هذا العمل من إدارة غير متعاقدة "ظروف طارئة". لقد أثار ذلك جدلا فيما يتعلق بتدخل الإدارة غير المتعاقدة، هل يمكن اعتبار تطبيق نظرية الأمير إذا أصرت إدارة غير متعاقدة على تنفيذ العقد كتدخل وزارة المالية مثلا في زيادة الأجر أو أسعار المواد.....الخ، هذه الظروف يمكن إدراجها في الظروف الطارئة أكثر من نظرية فعل الأمير لأنها مرتبطة بالإدارة المتعاقدة و هي من ابتكار القضاء الفرنسي.

ب- نظرية الظروف الطارئة: (قضية غاز بورديو بفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية):

إذا كانت نظرية فعل الأمير (المخاطر الإدارية) تطبق نتيجة لتدخل السلطة الإدارية المتعاقدة، فإن نظرية الظروف الطارئة تطبق بسبب ظرف لا علاقة له بالإدارة المتعاقدة ويؤدي إلى الزيادة في أعباء المتعاقد بحيث تؤثر على تنفيذ العقد، و يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة:

- أن يكون الظرف مستقلا عن إرادة المتعاقدين.
 - أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع و خارج عن إرادة المتعاقدين، بحيث يؤثر على تنفيذ العقد فعلا و يمس بمبدأ التوازن المالي للعقد.
- وتطبق نظرية الظروف الطارئة على سبيل المثال لا الحصر في حالات نذكر منها الأزمات الاقتصادية، الأزمة السياسية، إعلان حرب، أوضاع أمنية غير مستقرة....الخ. قد نجد لهذه النظرية مكانة في التشريع المعمول به في الجزائر وقد نجد تطبيقات في قانون الصفقات العمومية، و من أهمها.
- **تحيين الأسعار:** جعل الأسعار تتماشى مع الحين و الوقت الحالي، فالمادة (96) من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، يتضمن الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، و ما بعدها تتكلم عن مراجعة الأسعار وفق الأسعار الجديدة.
- مثلا:** عند إنجاز سد كان سعر الإسمنت وقت إبرام الصفقة 2000 دج و بسبب انخفاض قيمة الدينار أثر سلبا على تنفيذ العقود الإدارية و قد أدى ذلك إلى تحيين الأسعار وتعويض الفارق عن السعر والغاية منها أنه لو لم يرتبط العقد بالمرفق العام لما تم اللجوء لهذه النظريات أصلا تطبيقا لقاعدة السير المضطر المنتظم للمرفق العام، إذ يجب أن تستمر الخدمة العمومية.

السلطة الإدارية

مقدمة:

تمارس السلطة الإدارية وظائفها من خلال عدة وسائل قانونية كالقرار الإداري و العقد الإداري، و هما وسيلتان تعبر من خلالهما السلطة الإدارية عن إرادتها و تقتزن هذه الوسائل من الإمتيازات غير المألوفة في القانون الخاص، و هذه الإمتيازات تشمل كافة وسائل النشاط الإداري.

أولاً: أعمال السلطة الإدارية:

تصدر أعمال السلطة الإدارية إما بشكل إنفرادي أو عن طريق الإشتراك مع إدارة أخرى، ويتمثل النوع الأول في القرارات الإدارية، في حين يتجسد النوع الثاني في العقود الإدارية.

1- القرارات الإدارية:

يعد القرار الإداري وسيلة الإدارة المفضلة للقيام بوظيفتها لما يحققه من سرعة وفعالية العمل الإداري، فالقرار الإداري يتيح للسلطة الإدارية إمكانية البث من جانب واحد في أي أمر من الأمور دون حاجة إلى الحصول على رضا الأفراد و حتى على الرغم من معارضتهم، و يعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني يصدر عن الإرادة المنفردة للإدارة و لا يتوقف نفاذه على موافقة من ينطبق عليهم، غير أنه يظل قابلاً للطعن فيه باللجوء إلى القضاء الإداري على سبيل المثال قرار الهدم.

2- العقود الإدارية:

تكون العقود الإدارية محددة بالقانون وتعتبر عقوداً إدارية بقوة القانون كون موضوعها يتعلق بمرفق عمومي، والقانون هو الذي يحدد طابعها الإداري كعقود الصفقات العمومية، صفقات الأشغال... وهذا طبقاً للمعيار التشريعي.

أما بالنسبة للمعيار القضائي، فإنه يشترط في قيام العقد الإداري أن يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً كالدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وأن يتعلق بتنظيم أو إستغلال أو تسيير مرفق عمومي، وأن يتضمن شروطاً إستثنائية غير مألوفة في التعاقد العادي، والعقود الإدارية أنواع نذكر منها على سبيل المثال عقود الأشغال العامة،

عقود التوريد، عقود الخدمات، عقود البرمجة وعقود الامتياز والمنظمة بالمرسوم رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

ثانيا: إمتيازات السلطة الإدارية :

تتمتع السلطة الإدارية بعدد من الإمتيازات التي منحها لها المشرع، وذلك لتمكينها من تحقيق هدفها و هو المصلحة العامة .

وستقوم بالتطرق لهذه الإمتيازات المتعلقة بالقرار الإداري و العقد الإداري.

1- إمتيازات السلطة الإدارية في مجال القرار الإداري:

تتمتع السلطة الإدارية حين تصدر قرارات إدارية بإمتياز الأولوية المتمثل في إفتراض الشرعية أي إحترامها ومطابقتها للقانون، بالتالي تنفيذها بشكل مباشر بعد إصدارها من طرف السلطات الإدارية، كما أن المعنيون بهذه القرارات بصفة عامة ملزمون بإحترام شرعيتها و بالتالي تنفيذها، إضافة إلى أن الطعن القضائي لا يوافق سريان القرار الإداري على الأقل إلى غاية صدور الحكم القضائي، لكن في حالات معينة تكون السلطة الإدارية مضطرة إلى التطبيق الفوري والإستعجالي لقراراتها، وبالتالي قد تستعمل القوة العمومية لأجل ذلك وهذا ما يسمى بالتنفيذ القهري، إلا أن هذا الأخير يجب أن يلجأ إليه مع مراعاة التوفيق بين مطلبين متناقضين، الأول ضرورة تنفيذ القرارات الإدارية التي تفترض شرعيتها، الثاني ضرورة إحترام الحريات الفردية.

2- إمتيازات السلطة الإدارية في مجال العقود الإدارية:

تستفيد السلطة الإدارية من هذه الإمتيازات سواء نصّ العقد على ذلك أو لم ينص ويمكن تقسيم هذه الإمتيازات إلى أربعة.

أ- إمتياز السلطة الإدارية في مراقبة تنفيذ العقد وقد تكتسي هذه المراقبة طابع أعمال مادية أو طابع أوامر إدارية، و ذلك طبقا لمستلزمات المصلحة العامة.

ب- امتياز السلطة الإدارية في تعديل مقتضيات العقد بصفة إنفرادية شريطة أن يكون هذا التعديل مستند إلى ضرورة مسايرة تكييف المرفق العمومي مع ظروف جديدة واقعية أو قانونية من جهة و لا يتعدى حدا أقصى و لا يمس التوازن المالي للعقد من جهة أخرى.

ج- إمتياز توقيع الجزاءات، للإدارة أن توقع جزاءات ضد المتعاقد معها في حالة إرتكابه لأخطاء خلال تنفيذه للعقد، شريطة إشهاره من قبل وتبقى سلطة توقيع الجزاءات سلطة تلقائية تستفيد منها الإدارة سواء نص عليها العقد أو لم ينص، وتنقسم الجزاءات إلى جزاءات مالية و إلى وسائل للضغط و الإكراه كالوضع تحت الرقابة القضائية.

د- إمتيازات السلطة الإدارية في فسخ العقد بصفة انفرادية، تعد هذه السلطة أخطر وسيلة في يد الإدارة تتمتع بها في حل العقود الإدارية، ما عدا عقد الإمتياز الذي من الممكن أن ينص على أن الفسخ لن يتم إلا بمقتضى حكم قضائي.

ويبقى للمتعاقد مع الإدارة الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي إذا ما أقدمت الإدارة على تعديل العقد بصفة إنفرادية وذلك تطبيقاً لنظرية فعل الأمر و نظرية الظروف الطارئة.

ثالثاً: أنواع السلطات الإدارية :

لقد تولى الدستور تحديد الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا المعطيات التي على أساسها يمكن تحديد ما هي السلطات التي تعتبر إدارية وتشكل الإدارة الفاعلة من الإدارة الوطنية (المركزية)، والإدارة المحلية (اللامركزية)، وكذا الإدارة الاستشارية الممثلة في المجالس العليا بالإضافة إلى الهيئات المهنية .

وعليه، سيتم التطرق إلى الإدارة الفاعلة في العنصر الأول على أن يتم التطرق إلى الإدارة الإستشارية في العنصر الثاني، ويخصص العنصر الثالث للهيئات المهنية.

1- الإدارة الفاعلة:

الإدارة الفاعلة، هناك نوعين، سلطات إدارية وطنية (مركزية)، وسلطات إدارية ذات طابع محلي (لامركزية).

أ- السلطة الإدارية:

تتمثل السلطة الإدارية على الصعيد الوطني (المركزي) في الإختصاصات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول وكذا أعضاء الحكومة وقد ورد ذلك في الدستور، حيث ورد فيه على أن الحكومة تعمل على تنفيذ القوانين وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفاتها، إذن فتنفيذ القوانين عن طريق التدابير التنظيمية وغيرها هو عمل إداري والسلطة التي تضطلع لهذه المهمة لا يمكن أن تكون إلا إدارية.

فرئيس الجمهورية هو السلطة الإدارية الأولى في البلاد، واحتل مكانة مرموقة داخل جهاز الدولة سيما إزاء السلطة التنفيذية التي تتكون من الوزير الأول و باقي الوزراء.

يحفظ الرئيس لنفسه بسلطة الرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تكون في الدولة، وهي تمارس في شكل مراسيم تنظيمية، وقرارات فردية في شكل مراسيم رئاسية، كما يشرف على رئاسة مجلس الوزراء ويقوم بتعيين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم ويعين في الوظائف والمهام الهامة.

إنّ الوزير الأول يضطلع باختصاصات ذات طبيعة إدارية ترتبط بتنسيق النشاطات الوزارية، إذ بواسطته يستطيع ضمان وحدة العمل الحكومي وملاءمته بالسياسات المتبعة من قبل مختلف الوزارات، فضلا على إتخاذ التدابير الضرورية لضمان سير المرافق العمومية.

أما بالنسبة للوزراء، فإنهم يعتبرون بمثابة سلطة إدارية، وهذا يعني أنهم يستمدون من النصوص القانونية مختلف الاختصاصات الضرورية اللازمة لسير المصالح الإدارية التي تتكون منها وزاراتهم ويعتبرون الرؤساء الإداريون للمصالح التي يسيرونها، فالوزير مختص بصفة عامة بإصدار القرارات واللوائح الخاصة بتنظيم المرافق والمصالح الوزارية وممارسة جميع المهام والوظائف التي يترتب عنها في هذا المجال كحق تعيين الموظفين، نقلهم، تأديبهم، عزلهم، وتحديد إختصاصات كل منهم وتوزيعهم على الفروع والمصالح والإدارات و الوزارات و الأقاليم.

ب- السلطات الإدارية المحلية:

لقد تطرق الدستور إلى الجماعات المحلية، في الفصل الثالث من الباب الأول حسب المواد (15، 16 و 17)، وتتجسد السلطة الإدارية للجماعات المحلية في الاختصاصات الممنوحة لرؤساء المجالس المحلية، حيث كونهم رؤساء مباشرين لموظفي الجماعات المحلية ، فيعتبر الرئيس التسلسلي لموظفيه ويتولى التعيين في جميع المناصب بحكم القانون، كما أنهم مسؤولون وبشكل مباشر عن ترقيتهم وتنقيطهم وكذا توقيع العقوبة عليهم أثناء إخلالهم بمهامهم من جهة، ومن جهة أخرى فهم مسؤولون على إعداد الميزانية الجماعية (أي لها استقلال مالي) وكذا الإعداد الإداري، وهذا في مجمله يعد عمل إداري ويوفر للسلطة المحلية قدر من الإستقلالية في ممارسة إختصاصاتها.

2- الإدارة الإستشارية :

يحيط بالإدارة الفاعلة التي تتخذ القرارات مجموعة من المجالس التي تكلف بإعداد الرأي و المشورة و هو ما يترجم جانبا من جوانب الدولة الديمقراطية التي تسعى إلى إشراك المواطنين في كافة مستويات إتخاذ القرارات، وقد أشار الدستور الجزائري إلى هذه المجالس التي أراد أن يسبغ عليها أهمية خاصة ويتعلق الأمر بالمجلس الإسلامي الأعلى، يتولى على الخصوص الحث على الإجتهد وترقيته وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه وكذا المجلس الأعلى للأمن، يرأسه رئيس الجمهورية مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني حسب المواد من (195 إلى 207) من القانون رقم 01-16 مؤرخ في 06 مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري وأيضا هناك مجلس وطني لحقوق الإنسان، يتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال إحترام حقوق الإنسان، وكذا مجلس أعلى للشباب، يقدم آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وإزدهاره في المجال الإقتصادي، الإجتماعي، الثقافي والرياضي وهيئة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، تتولى مهمة إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، كذا المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، يتولى توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يتولى ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي.

3- الهيئات المهنية:

هي مرافق تنشأ من أجل بعض المهن والدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها وتتمثل هذه المرافق في الفرق المهنية مثل هيئة (منظمة) المحامين ولكي تقوم هذه الهيئات بمهامها، فقد منحها المشرع قدرا من السلطة العامة يتمثل في حق إصدار أوامر لجميع المنتميين إليها أو من خلال الإشراف على تسجيل الأعضاء الجدد في جدول أو من خلال إصدار القرارات التأديبية ضد الأعضاء الذين يرتكبون أخطاء تستوجب التأديب وفيما عدا هذه الأعمال التي تعتبر من الوظائف الإدارية فإن جميع الأعمال الأخرى الصادرة عن هذه الهيئات تخضع لقانون خاص، وتعتبر من الأعمال المدنية، مثل الطريقة التي تتبعها في استغلال أموالها.

نظرية المرفق العام

مقدمة:

تتخذ صور و مظاهر النشاط الإداري صورتين أساسيتين هما صورة الضبط الإداري وصورة المرفق العام الذي بواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف إشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع بانتظام وعلى أفضل وجه .

تعد فكرة المرافق العامة من أهم موضوعات القانون الإداري وترد إليها معظم النظريات والمبادئ التي إبتدعها القضاء الإداري كال عقود الإدارية والأموال العامة والوظيفة العامة، وبالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري. لهذا، تقتضي دراسة نظرية المرفق العام إستعراض مفهومه وإبراز عناصره، كما تقتضي التطرق لأنواع المرافق ونظامها القانوني وطرق إدارتها.

أولاً: مفهوم المرفق العام:

يعتبر المرفق العام أكثر المفاهيم القانونية غموضاً وإثارة للجدل، فمن الفقهاء من إرتكز على المعيار الوظيفي، ومنهم من إستند في تعريف المرفق العام إلى المعيار العضوي ومنهم من مزج بين الأول والثاني.

أ - المعيار العضوي:

يقصد بالمرفق العام تبعاً لهذا المعنى كل منظمة عامة تنشئها الدولة وتخضع لإدارتها بقصد تحقيق حاجات الجمهور، ومن هنا جاز إعتبار كل من مرفق القضاء والأمن والدفاع وغيرها مرافق عامة لأنها منظمات أنشأتها الدولة بغرض أداء خدمة للجمهور، ويتصف هذا المعنى بالشمولية والإطلاق أي يقصد بالمرفق العام تبعاً لهذا المفهوم الإدارة بشكل عام.

ب - المعيار الوظيفي (الموضوعي):

يقصد بالمرفق العام بالنظر للمعيار الموضوعي كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة، ومن تم تخرج عن نطاق هذا التعريف سائر النشاطات الخاصة كالمؤسسة الخاصة، كما يخرج عنه المشروعات التي تستهدف فقط تحقيق الربح.

ثانيا: عناصر المرفق العام:

1- المرفق العام تنشأه الدولة:

كل مرفق عام تحدته الدولة، ويقصد بذلك أن الدولة هي التي تقدر إعتبار نشاط ما مرفقا عاما و تقرر إخضاعه للمرافق العامة بناءا على قانون معين، وليس من اللازم أن يكون كل مشروع تحدته الدولة أن تتولى هي مباشرة إدارته، فكثيرا ما تعهد الإدارة إلى الأفراد أو شركة خاصة بأداء خدمة عامة تحت إشرافها وهو الوضع الذي يجسده نظام الإمتياز أو الشركات المختلطة.

2- هدف المرفق تحقيق مصلحة عامة :

عرفنا سابقا أن المرفق العام مشروع يستهدف تحقيق مصلحة عامة، وهذا العنصر هو أكثر العناصر إثارة للجدل من جانب الفقهاء، ذلك أن المصلحة العامة هي هدف كل وظيفة إدارية، بل وحتى المؤسسات التي تسيورها الدولة والتي تكون غايتها تجارية بحتة كالمؤسسات الإقتصادية، إنما تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة.

كما أن المصلحة العامة ليست حكرا على الإدارة، فمن الوظائف التي يمارسها الأشخاص العاديون ما تتصل كذلك بالمصلحة العامة كخدمات البناء و النقل.

ولقد إقترح الفقه معيارا للخروج من هذه الإشكالية، فإذا كانت المصلحة العامة تمثل الغاية الأولى من النشاط الذي يقوم به الشخص القانوني وتوفرت الأركان الأخرى يكون المرفق عام، أما إذا كانت المصلحة العامة تمثل غاية ثانوية لهذا النشاط فان الوظيفة لا ترقى إلى منزلة مرفق العام.

يترتب على تميز المرفق بهذا الوصف أن كل مرفق عام ينبغي أن يخضع إلى مبدأ المجانية، ولا يقصد بذلك عدم وجود مقابل بل القصد أن فرض مقابل ما ليس هو الغاية المقصودة من خلال القيام بالنشاط، أي أن المجانية لا تفيد هنا إنعدام المقابل إنعداماً تاماً، بل تفيد فقط أنه ليس من الضروري أن يكون المقابل مساويا للتكلفة المالية للمرفق العام، فعندما يلزم الطالب في الجامعة مثلاً بدفع رسوم رمزية كل سنة جامعية، فإن ما قدمه لا يغطي أبدا الخدمات التي ينتفع بها من مرفق التعليم العالي.

3- خضوع المرفق لسلطة الدولة:

سبقت الإشارة أنه ليس كل مشروع يهدف إلى تحقيق النفع العام يعد مرفقا عاما لأن هناك من المشروعات الخاصة ما يعمل على تحقيق النفع العام كالمدارس والجامعات الخاصة والجمعيات.

من هنا تعين أن يتصف المرفق العام بصفة أخرى تميزه عن غيره وهي خضوعه للدولة، وهو ما يترتب عليه أن لهذه الأخيرة وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق سواء من حيث تنظيمه وهيكلته أو من حيث نشاطه، فالدولة هي من تنشئ المرفق وهي من تحدد نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بجمهور المنتفعين، ومن حيث بيان سبل الإنتفاع ورسومه (السلطة على نشاط المرفق).

الدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعين موظفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص (السلطة على المرفق كهيكل).

4- خضوع المرفق لنظام قانوني متميز:

المشروع الذي رصد لتحقيق مصلحة عامة وأنشأته الدولة وتولت هي إدارته مباشرة أو عهدت به إلى أحد الأفراد أو الشركات إنما يحكمه نظام قانوني خاص، وما أجمع عليه الفقهاء أن هذا النظام يختلف من مرفق إلى آخر حسب طبيعته غير أن هناك قواعد مشتركة تحكم المرافق جميعا، ويجدر التنبيه أن بعض الفقهاء إعتبر خضوع المرفق لنظام قانوني متميز بمثابة الأثر المترتب على كونه مرفقا عاما، فهو إذن نتيجة ولا يمكن إعتبره عنصرا من عناصر المرفق العام.

ثالثا: أنواع المرافق العامة:

يمكن تقسيم المرافق العامة من زوايا متعددة سواء من حيث طبيعة نشاطها أو السلطة التي تنشئها أو لإختلاف دائرة نشاطها، نستعرض هذه الأنواع فيما يلي:

1- تقسيم المرفق من حيث طبيعة أو نوعية النشاط:

من حيث هذه الزاوية يمكن تقسيم المرافق إلى مرافق إدارية وأخرى إقتصادية ومرافق ثقافية وأخرى مهنية.

أ- المرافق الإدارية:

هي المرافق التي تؤدي الخدمات المرفقية التقليدية وقد لازمت الدولة منذ زمن طويل وعلى رأسها مرفق الدفاع، الأمن، القضاء ثم مرفق الصحة والتعليم، وهذه المرافق عادة ما تتسم بإرتباطها بالجانب السيادي للدولة، الأمر الذي يفرض قيامها بهذه النشاطات وأن لا تعهد بها للأفراد لما في ذلك من خطورة كبيرة، وتخضع في تنظيمها وفي مباشرة نشاطها للقانون الإداري و تستخدم وسائل القانون العام.

ب- المرافق الاقتصادية:

هي مرافق حديثة النشأة نسبيا تسبب فيها التطور الإقتصادي وظهور الفكر الإشتراكي مما دفع بالدولة إلى ممارسة نشاطات كانت في أصلها معهودة للأفراد، ومثال هذا النوع من المرافق المؤسسات الصناعية والمؤسسات التجارية، وإذا كان الفقه قد أجمع كما رأينا على إخضاع المرافق الإدارية لقواعد القانون العام، فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمرافق الاقتصادية، وقد ثبت ميدانيا أن المرافق الإدارية يتسم عملها بالبطئ و إجراءاتها معقدة و تكاليفها باهظة، وهذه الآليات لا تساعد المرافق الاقتصادية التي تحتاج إلى أن تتحرر أكثر وتخضع لإجراءات سهلة يفرضها مبدأ المنافسة.

ج- المرافق المهنية:

ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية، وهو يرمي إلى تنظيم بعض المهن في الدولة عن طريق أبناء المهنة أنفسهم، والسمة البارزة في المرافق المهنية أن انضمام أفراد المهنة إليها ليس أمرا إختياريا، وإنما هو أمر إجباري مما يجعلها نوعا من الجماعات الجبرية، وتدار هذه المرافق من قبل مجموعة من المنخرطين فيها حيث تتخذ شكل التنظيم النقابي يشرف على إدارته مجلس منتخب.

مثال هذه النقابات في الجزائر منظمة المحامين التي يحكمها القانون رقم 07-13 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 ورجوعا للمادة (32) من هذا القانون، نجدها قد فرضت التسجيل بالنسبة للمحامين في جدول المنظمة بقولها: "لا يمكن أي شخص أن يتخذ صفة محام، ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة إنتحال صفة المنصوص عليها في قانون العقوبات".

د - المرافق الإجتماعية:

هي المرافق التي تستهدف تحقيق خدمات إجتماعية للجمهور، مثل المرافق المخصصة لتقديم إعانات للجمهور ومراكز الضمان الإجتماعي، التقاعد ومراكز الراحة، يحكم هذا النوع من المرافق مزيج من قواعد القانون العام والخاص، كما تمثل منازعتها أمام القضاء الإداري وأحيانا أخرى أمام القضاء العادي.

رابعاً: النظام القانوني للمرافق العامة:

ينبغي الإشارة أنه من الصعب سن قانون واحد يحكم المرافق، وأن ما صلح من القواعد والآليات لمرفق قد لا يصلح لمرفق آخر، فمرفق القضاء مثلاً طبيعة نشاطه تفرض عليه أن يكون محايداً وعادلاً، لذا يجب أن يؤدي المرفق عمله في كنف الإستقلال التام دون خضوع لأي جهة أيا كان موقعها و قوة نفوذها.

هذا خلافاً لمرافق أخرى تقتضي طبيعة نشاطها أن لا تستقل في أداء عملها بذات الصورة التي ألفناها في عمل مرفق القضاء، بما ينجم عن ذلك خطورة تعود نتائجها على المجتمع بأكمله، فمرفق الدفاع مثلاً طبيعة عمله تفرض توحيد مصدر قيادته وأوامره وربطه أكثر بجهات قيادية معينة، وما قيل عن مرفق القضاء والأمن يقال عن سائر المرافق الأخرى كمرفق البريد، التعليم والصحة.

لذلك، عمدت غالبية الأنظمة المعاصرة إلى تخصيص قواعد تحكم كل نشاط لوحده، و هو ما عمل به المشرع الجزائري حيث خص كل قطاع بقانونه الأساسي، فللجامعة قانونها الخاص وللقضاء قانونه أيضاً و للبريد، الجمارك، الصحة والدفاع و هكذا.. حتى أنه نجم عن صدور قانون الوظيفة العامة الجديد صدور أكثر من 80 مرسوماً منظماً لقطاعات مختلفة، وإذا كان الأصل هو عدم إمكانية وضع قانون واحد جامع مانع يحكم سائر المرافق وكل النشاطات والقطاعات، إلا أن ذلك لا يمنع أن تتحد المرافق جميعها في قواعد أساسية وأحكام عامة تجد تطبيقها في شتى ميادين النشاط.

خامساً - المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة:

سبق القول أن سن قانون واحد يحكم المرافق جميعاً بات أمر من المحال تجسيده في الواقع العملي بسبب إختلاف طبيعة نشاط كل مرفق، غير أن ذلك لا يمنع من إخضاع

كل المرافق إلى مبادئ معينة إتفق الفقه والقضاء بشأنها وأضحت اليوم من المسلمات في نظرية المرافق، وتتمثل هذه المبادئ في:

أ- مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق:

إنّ مبدأ المساواة أمام المرافق العامة هو إمتداد للمبدأ العام ألا و هو مساواة الأفراد أمام القانون، والذي بات يمثل اليوم حقا من حقوق الإنسان وحقا دستوريا أعلنت عنه مختلف الدساتير، ويترتب على هذا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية هي مساواة المنتفعين من خدمات المرفق و المساواة في الإلتحاق في الوظائف العامة.

ب- مبدأ سير المرفق العام بانتظام و إطراد:

تؤدي المرافق العامة دورا كبيرا داخل المجتمع أيا كان موضوع نشاطها، وهذا يفرض أن تقدم خدماتها للجمهور بشكل مستمر و متواصل، فلا يمكن أن نتصور مثلا توقف جهاز القضاء عن الفصل في الخصومات، أو توقيف جهاز الأمن عن أداء مهامه أو مرفق الدفاع، إن توقف أحد هذه الأجهزة وغيرها سينجم عنه لا شك إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وبحقوق الأفراد، لذا تعين على المشرع و بغرض تحقيق المقصد العام وهو إستمرارية نشاط المرفق و قيامه بالخدمات المنوطة به، وضع الآليات القانونية لضمان أداء الخدمة وتواترها وانتظامها وعدم إنقطاعها.

فمن حق المنتفع الإستفادة من خدمات المرفق في المكان والزمان المخصص لذلك، وإذا تعرض المرفق لعوائق تقنية تحول دون تحقيق عنصر الإنتفاع وجب أن يعلم الجمهور بذلك، فإذا أرادت مثلا مؤسسة سونلغاز القيام بأشغال معينة وقطع التيار الكهربائي لمدة معينة وجب أن تعلن الجمهور بذلك و كذا الحال بالنسبة لمؤسسة توزيع المياه.

ويعتبر مبدأ الإستمرارية أكثر المبادئ وزنا لأن معظم أحكام ومبادئ القانون الإداري تنفرد منه و تخصه، كما أن القضاء الإداري يعتمد عليه.

ويقتضي مبدأ الاستمرارية توافر جملة من الضمانات تعمل جميعا على تجسيده في أرض الواقع، ومن هذه الضمانات ما وضعه المشرع ومنها ما رسخه القضاء الإداري وتتجلى هذه الضمانات في تنظيم ممارسة حق الإضراب، وتنظيم ممارسة حق الإستقالة وسن قواعد خاصة لحماية أموال المرفق، وهي جميعا تمثل ضمانات تشريعية أي من صنع

المشرع، وهناك ضمانات أخرى كنظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة وهي من صنع القضاء.

ج- مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير و التبديل:

سبق القول أن المرافق العامة تخضع لقوانين وتنظيمات تحكمه من حيث تنظيمه وهيكلته، ولا يقتصر التغيير على القواعد المنظمة للمرفق، بل يمتد أيضا لأسلوب إدارته فيجوز تغيير أسلوب الإدارة، من الإدارة المباشرة إلى المؤسسة العامة، أو من المؤسسة العامة إلى الشركة المختلطة، وللمرفق أيضا أن يفرض رسوما لقاء الخدمات التي يقدمها أو أن يخفض من هذه الرسوم إذا رأى في ذلك مصلحة، ولا يجوز لأي كان الإحتجاج على هذا التغيير، ولقد أكد القضاء الإداري في مصر هذا المبدأ بقوله: "من المسلم قانونا أن للجهة الإدارية سلطة وضع الأنظمة التي تتولاها سيرا منتظما ومنتجا وكذلك لها تعديل هذه الأنظمة بما تراه متفقا مع الصالح العام دون أن يكون لأحد من الناس الإدعاء بقيام حق مكتسب في إستمرار نظام معين".

وبناء على هذا المبدأ، إذا غيرت الإدارة في نظام المرفق من أسلوب إلى آخر فليس للموظفين التمسك بالنظام القديم الذي كان يحكمهم، كما أنه ليس من حق المنتفعين التمسك بمجانية الخدمة خاصة إذا غيرت الإدارة الأسلوب، من طريقة الإستغلال المباشر إلى أسلوب المؤسسة.

وترتبيا على ذات المبدأ، ليس من حق المتعاقد مع الإدارة في عقد الإلتزام أن يحول دون ممارسة حقها في تغيير بعض بنود العقد بما يتماشى ومصلحة المنتفعين، مع الإحتفاظ بحقه في التوازن المالي على نحو سبق شرحه، وهذا الحق الذي تتمتع به لها أن تمارسه وإن خلا العقد من الإشارة لذلك.

سادسا: إدارة المرافق العامة:

سبق القول أن المرافق العامة أنواع، ولهذا كان من الطبيعي أن تتباين طرق إدارتها فما صلح لمرفق لا يصلح بالضرورة لآخر، كما أن المرافق تختلف من حيث صلة نشاطها بالجانب السيادي للدولة، فطبيعة مرفق الأمن، الدفاع، القضاء والضرائب تفرض أن تسير من قبل الدولة مباشرة، فلا نتصور أن تعهد به إلى أشخاص القانون الخاص لإدارته لما في ذلك من خطورة كبيرة تهز كيان الدولة، وهذا خلافا لمرافق أخرى، فلا مضرة من أن تعهد

إدارتها للأفراد أو الشركات مثلما هو الحال بالنسبة لإستغلال آبار البترول أو إستغلال الكهرباء والغاز أو إستغلال الموانئ وغيرها، شريطة أن يتم ذلك بالكيفية والحدود التي يبينها القانون.

تأسيسا على ما تقدم، فإن المرافق تختلف من حيث وضع يد الدولة عليها، فأحيانا نجد الدولة هي من تحتكر النشاط وهي من تتفق الأموال وتعين الموظفين وتراقب سير المرافق ونشاطه وغيرها. وهو ما أصطلح عليه بطريقة الإستغلال المباشر، وأحيانا أخرى نجد الدولة تكلف وفي إطار القانون أحد أشخاص القانون الخاص للقيام بإدارة المرفق على نفقته وأن يتكفل بتوفير اليد العاملة وكل ما يلزم لقيام المرفق بالخدمة للجمهور على أن يتقاضى رسوما من هؤلاء، وهذا ما أطلق عليه بطريقة الإمتياز، فضلا عن وجود طرق أخرى.

سابعا- المسؤولية الإدارية للمرفق العام:

1- المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ:

تقوم المسؤولية بصفة عامة على ثلاثة أركان أساسية هي ركن الخطأ وركن الضرر وركن السببية، وإتفق الفقه على أن الخطأ الذي يعقد المسؤولية الإدارية ويقرها ليس أي خطأ بل خطأ من نوع خاص يختلف عن الخطأ المعهود الذي بموجبه تنقرر المسؤولية المدنية يعبر عنه بالخطأ المرفقي.

- **تعريفه:** إنه الخطأ الذي يشكل إخلالا بالتزامات وواجبات قانونية سابقة عن طريق التقصير والإهمال الذي ينسب ويسند إلى المرفق العام ذاته، ويقوم ويعقد المسؤولية الإدارية ويكون الإختصاص بالفصل والنظر فيه لجهة القضاء الإداري.

- صور الخطأ الموجب للمسؤولية الإدارية:

إن التطرق لصور الخطأ الموجب للمسؤولية الإدارية يعني التطرق لصور الخطأ المرفقي، فإذا كان الأخير يتجسد في إخلال الإدارة بالتزاماتها، فإن أمثلة هذا الإخلال تتعدد وتتنوع بتنوع الأنشطة الإدارية خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار الهدف الذي تسعى له والمتمثل دائما في تحقيق المصلحة العامة ولذلك فإن صور إخلال الإدارة بالتزاماتها يتجلى في ثلاث صور أساسية:

- **التنظيم السيء للمرفق العام:** تتحقق هذه الصورة في الحالة التي تكون فيها الأضرار اللاحقة بالضحية ناتجة عن التنظيم السيء للمرفق العام، فعندما تتوفر له كل الإمكانيات المادية والبشرية لكنه لا يحسن إستغلال هذه الوسائل ليضمن السير الحسن للمرفق العام ينسب لهذا الأخير ويتحمل عبئ التعويض.

- **سوء سير المرفق العام:** يتمثل الخطأ هنا في الأعمال الإيجابية التي تؤدي الإدارة بها خدماتها، ولكن على وجه سيء مما يسبب الإضرار بالغير سواء تجسد الخطأ هنا في صورة عمل مادي أو في صورة قرار لإداري مخالف للقانون.

- **عدم سير المرفق العام:** سلطات الإدارة لم تعد إمتيازاً لها تباشره كيفما شاءت ومتى أرادت، ولكنها واجب على الموظف يؤديه بكل أمانة ومع حرصه التام على المصلحة العامة ويتمثل الخطأ هنا في إمتناع أحد أدواته (الموظف) عن أداء خدماته أو الأعمال التي يكون ملزماً بها قانوناً، وعليه يمكن القول أن كل إمتناع من شأنه أن يعطل السير المطرد للمرفق العام ويؤدي بذلك إلى تعطيل المصلحة العامة للأفراد يعني بالضرورة عدم سير المرفق وهو ما يقر المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي.

2- المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر:

تعريفها: تعني أن الإدارة مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالمضرور بسبب نشاطها بدون صدور خطأ منها بل مجرد فكرة المخاطر الإستثنائية وغير العادية.

عناصرها: لقيام المسؤولية الإدارية يجب توفر عدة عناصر:

- يجب أن يكون هناك ضرر مباشر، أكيد، إستثنائي وجسيم وقد بلغ حد الخطورة غير العادية بحيث لا يستطيع المضرور تحملها وحده.

- يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين نشاط الإدارة والضرر ليقوم التعويض، فلا يثبت إذا كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ الضحية، والتعويض يكون على أساس نظري المخاطر التي يقدرها القاضي ويقدر نسبة جسامتها.

- **صور المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر:** هناك عدة صور للمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر:

- المسؤولية بسبب الأشغال العمومية.

- المسؤولية الإدارية بسبب خطورة بعض النشاطات العمومية.

طرق إكتساب الإدارة للأموال (نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، حق الشفعة)

مقدمة:

الأموال الوطنية هي كل الأموال العقارية و المنقولة و الحقوق المتعلقة بها والتي تحوزها الدولة و الجماعات المحلية لتديرها بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع كما تساعد على أداء المهام المنوطة بها. ويتم إكتساب المال من طرف الإدارة بطريقتين، الطريقة الأولى هي عادية كالشراء، المبادلة أو التقادم، أما الطريقة الثانية وهي غير عادية (إستثنائية)، تكون بطرق جبرية كنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، إثبات الشغور أو ممارسة حق الشفعة لفائدة الإدارة ويتم إدماج المال ضمن الأملاك الوطنية العمومية إذا توفرت الشروط المذكورة قانونا بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة كما يمكن إخراجه منها بنفس الوسيلة.

أولا: نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية:

1-تعريف:

عرفتها المادة (02) من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، " يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة إستثنائية لإكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا أدى إنتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية.

وزيادة على ذلك، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية، والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية. "

أي بمعنى هي إجراء من شأنه حرمان شخص من ملكه العقاري جبرا عنه لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ويمثل الإجراء إعتداء خطيرا على الملكية الفردية لا يبرره إلا إيثار المصلحة العامة على المصالح الفردية الخاصة مع ضرورة مراعاة هذه المصالح الخاصة، لذلك يعتبر إجراء إستثنائيا لا يجوز اللجوء إليه إلا وفقا لنصوص قانونية تجيزه صراحة و في الحدود التي تعينها.

2- الخصائص العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة:

أ- نزع الملكية إمتياز من إمتيازات السلطة العامة:

تتمتع السلطات الإدارية بإمتيازات تنفرد بها في معاملتها مع الأفراد وهذا تحقيقا للغرض الذي أنشئت من أجله وهو المنفعة العامة وسلطة الإدارة في تحديد المنفعة العامة سلطة تقديرية تستعمل في إختيار العقار المناسب والمساحة المناسبة والمكان المناسب لتحقيق المنفعة العامة المرجوة من نزع الملكية، ذلك دون تدخل القضاء في تقدير مدى ملائمة الإختيار، لأن الإدارة هي الأعلم بالموقع والعقار الذي يناسب المشروع الذي تهدف إلى إنجازه، علما بأن المشرع الجزائري رغم عدم تعريفه للمنفعة العامة إلا أنه وضع ضابطا تلتزم الإدارة بإحترامه أثناء تقديرها للمنفعة العامة، وهو أن يكون نزع الملكية تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية و التخطيط.

ب- نزع الملكية يجب أن يكون للمنفعة العامة:

الهدف من نزع الملكية للمنفعة العامة هو تحقيق المنفعة العامة، و بالتالي لا يجوز نزع الملكية للمنفعة الخاصة، مثل نزع ملكية منزل من شخص معين لأجل شخص خاص، و من جهة أخرى لا يجوز نزع الملكية للمنفعة العامة إلا بمرسوم تنفيذي يتضمن تحديد أهداف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

لايجوز نزع ملكية الأفراد جبرا و حرمانهم من عقاراتهم لغاية أخرى غير المنفعة العامة، فقد نصّت المادة (02) من المرسوم التنفيذي رقم 05-248 المؤرخ في 27 جويلية 2005، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 جويلية 1993 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أفريل 1991، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية على أن تتم أحكام المادة (10) من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 جويلية 1993 بفقرة تحرر كما يلي: " أما بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والإستراتيجي، يصرح بالمنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي. يجب أن يبين المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي:

- أهداف نزع الملكية المزمع القيام بها.

- مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية محل نزاع الملكية و موقعها.

- قوام الأشغال المراد الشروع فيها.

- توفر الإعتمادات التي تغطي عملية نزاع الملكية المزمع القيام بها و إيداعها لدى الخزينة العمومية ."

ج- نزاع الملكية لا يرد إلا على العقارات:

العقارات وحدها هي التي يمكن أن تكون موضوعا أو محلا لنزع الملكية للمنفعة العمومية، أما المنقولات فلا يجوز نزاع ملكيتها، كذلك العقارات الحكومية، حيث لا يشترط صفة خاصة في العقارات محل نزاع الملكية للمنفعة العمومية، سواء كانت عقارا مبنيا أو أرضا غير مبنية، وقد يكون مشغولا (بساكن ، تجارة أو صناعة) أو خاليا، وإذا كان أرضا قد تكون بورا أو مزروعة، بالنسبة للعقار المبنى يجب أن يرد نزاع الملكية على الأرض والمبنى معا، فلا يجوز أن يقتصر نزاع الملكية على المباني دون الأرض أو على الأرض دون البناء أو على بعض أدوار هذا البناء، كما يجب التوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد الذين وقع عليهم عبئ نزاع ملكيتهم العقارية من خلال التعويض العادل الممنوح لهم من قبل السلطات العامة.

3- إجراءات نزاع الملكية من أجل المنفعة العمومية:

لقد حددت المادة (03) من القانون 91-11 إجراءات نزاع الملكية من أجل المنفعة العمومية و ذلك بنصها على أنه " يخضع نزاع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يلي :

- التصريح بالمنفعة العمومية.

- تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزاعها، وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية.

- تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزاعها.

- قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزاعها.

يجب أن توفر الإعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزاعها.

."

من خلال هذه المادة نلاحظ أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية يعد إجراء جوهريا وضروريا لنزع الملكية، ويشترط فيه أن يصدر من الجهة المختصة قانونا وبمرسوم تنفيذي و وفقا للتشريعات والنصوص التنظيمية السارية المفعول، ويجب أن يتضمن هذا القرار أهداف نزع الملكية المزمع القيام بها، مساحة الأملاك العقارية أو الحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية وموقعها، قوام الأشغال المراد الشروع فيها، توفر الإعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدى الخزينة العمومية، وبمجرد نشر المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة الرسمية، يقوم الولاية المعنيون بإعداد تقرير الحيازة الفورية من الإدارة نازعة الملكية، للأملاك أو الحقوق العينية العقارية، مع مراعاة إيداع مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين منزوعي الملكية لدى خزينة الدولة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إحترام بعض القواعد الشكلية و المنصوص عليها في المادة (11) من القانون 91-11 كآآتي " يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان لما يلي:

- أن ينشر حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية.
- أن يبلغ كل واحد من المعنيين.
- أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها المادة 6 من هذا القانون، طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. "

علما أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة في الطعن حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك في أجل أقصاه شهرا إبتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره، وتفصل المحكمة المختصة بالنظر في الطعن، وأن تصدر حكمها في أجل شهرين على الأقصى، إبتداء من تاريخ الطعن، ويعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا.

4- الحقوق المترتبة عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية:

تتمثل في العناصر التالية:

أ- الحق في الرقابة القضائية على مدى فعالية المنفعة العمومية:

تطبيقاً لأحكام القانون رقم 91-11 لا يمكن اللجوء إلى نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إلا بعد إتباع الوسائل والطرق الودية الأخرى، وأن تستهدف نزع الملكية عمليات ناتجة عن تطبيق أداة من أدوات التعمير والتهيئة وإنجاز تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية، لذا فإن دور القاضي الإداري يتمثل في مراقبة مدى توفر شروط وأحكام المادة (02) من القانون 91-11 وخاصة ما يتعلق منها بالمنفعة العامة، وهل فعلاً نزع الملكية يعود بالمنفعة العمومية أم مجرد منفعة خاصة يستفيد منها شخص طبيعي لا أكثر، فإذا تعلق الأمر بالمنفعة الخاصة يستطيع القاضي الحكم بإلغاء القرار الإداري لعدم توفر الشرط الأساسي و الضروري لنزع الملكية.

كما يمكن إبطال القرار الذي صرح بالمنفعة العمومية إذا ثبت أن المشروع المراد إنجازه يخالف تشريع آخر كحماية البيئة أو فيه خطر على صحة وسلامة المواطنين، كما يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر بتقرير منفعة عامة بشأن مشروع معين تستهدف منه الإدارة مجرد الربح المادي أو الإستغلال كأن تنزع ملكية أرض أو مبنى بهدف إقامة ملهى ليلي مثلاً، على أساس أن إنشاء هذا الملهى لا يدخل معنى المنفعة العمومية.

ب- الحق في التعويض:

يتم اللجوء إلى المفاوضة مع الملاك المعنيين بغرض إقتناء الأملاك أو الحقوق العقارية بالتراضي ويكون ذلك بالتعويض النقدي أو العيني أي بشراء هذه الأملاك أو التبادل بأملك أخرى، ويجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلاً ومنصفاً بحيث يغطي كامل الضرر الناشئ عنها، ويتضمن قيمة العقار أو الحق العيني و ما لحقه من خسارة ما فاتته من كسب جراء حرمانه من إستعماله وإستغلاله والإنتفاع به، إلا أن تحديد مبلغ التعويض في الحكم الصادر بنقل الملكية يعد من الضمانات الحقيقية لحق الملكية إلا أن السلطة القضائية لمختصة بذلك لا تمتلك الحرية المطلقة في هذا الصدد بل يتعين عليها إحترام النصوص التي تحدد بعض القواعد المنظمة لتقديم التعويض، كما يمكن لها أن

تستعين برأي الخبراء المختصين إذا ظهرت لها صعوبة في التقدير، ويحدد التعويض عن نزع الملكية على أساس القواعد الآتية:

- يحدد مقدار التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأمالك المقرر نزع ملكيتها.
- يجب أن لا يتجاوز التعويض المقدّر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأمالك التي ستتزع ملكيتها، ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة، غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداءً من نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستتزع ملكيتها.

ج- الحق في إسترجاع الأملاك المنزوعة:

تطبيقاً لأحكام المادة (32) من القانون رقم 91-11، يستطيع المالك الحقيقي للملكية المنزوعة أن يسترجعها إن لم يتم الإنطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية، غير أن القانون لم يحدد المهلة التي يجب أن تتجز فيها الأشغال التي إنتزعت من أجلها الأملاك، علماً أن القانون القديم حددها بخمسة سنوات من تاريخ نزع الملكية، ويستطيع المنزوع منه الملكية الطعن إدارياً بإلغاء القرارات وإسترجاع الأملاك وذلك خلال خمسة عشر سنة من تاريخ نزع الملكية، كما يمكنه الطعن قضائياً في حالة عدم إستجابة الإدارة لتظلمه وفي نفس المهلة أي خمسة عشر سنة من نزع الملكية، و يلتزم بإثبات أن الأشغال لم تتطلق فعلاً في الآجال المحددة لها أو أن الإدارة لم تستعمل الأموال للغرض المحدد في التصريح بالمنفعة العمومية، و إذا إستجاب القاضي للطلب يتعين عليه تعيين خبير لتقييم الأملاك المطالب بإسترجاعها طبقاً للمعايير المستعملة عند نزع الملكية مع الأخذ بعين الإعتبار القيمة الحقيقية للأملاك وقت الإسترجاع.

د-الحق في أولوية الشراء أو الإيجار:

قد ترى الإدارة أن موقع العقار غير مناسب بسبب البعد أو القرب من المدينة أو أن الدراسة التقنية أثبتت عدم صلاحية الأرض للبناء وبالتالي يمكنها إيجار العقارات المنزوعة من أصحابها، أو بيعها بالمزاد العلني وفي جميع هذه الحالات تكون الأولوية في الشراء أو الإيجار للمالكين الحقيقيين وذوي الحقوق.

ثانيا: حق الشفعة:**1- تعريف:**

تنص المادة (794) من القانون المدني على ما يلي: "الشفعة رخصة تجيز الحل محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال و الشروط المنصوص عليها في المواد التالية".

ويستخلص من هذا التعريف أن الشفعة هي سبب من أسباب كسب الملكية فهي رخصة إذن يستعملها الشفيع لتملك عقارا باعه صاحبه لغيره، وحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع بشروط سيأتي بيانها، فهي لا تكون إلا في بيع عقار، ويسمى العقار المشفوع فيه. فالشفعة ليست بحق عيني ولا بحق شخصي، بل هي ليست بحق أصلا، إنما الشفعة هي سبب لكسب الحق، فالشفيع يكسب بالشفعة ملكية عقار أو حقا عينيا على هذا العقار كحق إنتفاع أو حق رقبة أو حق حكر.

والشفعة باعتبارها سببا لكسب الحقوق العينية فهي واقعة مادية مركبة إقترن فيها الشيوع أو الجوار أو الصلة المادية، فالشفعة متصلة بشخص الشفيع ولصيقة به ولا يمكن أن تنتقل إلى شريكه في الملك أو جاره الشريك أو جار جديد.

2- التكيف القانوني للشفعة:

تنص المادة (794) من القانون المدني بأن الشفعة رخصة تساعد على ترجيح الرأي القائل بأن الشفعة لا تنتقل بالميراث، لأن الرخص لا تورث على الإطلاق. وفي عدم إنتقال الشفعة بالميراث تضيق في الأخذ بها مادام ورثة الشفيع لا يجوز لهم الأخذ بالشفعة.

3- شروط الأخذ بالشفعة :

تتلخص هذه الشروط في أمرين هما:

* بيع العقار:

إذا بيع عقار إنفتح باب الشفعة، و الأصل جواز أن يؤخذ هذا العقار بالشفعة إذا وجد شفيع و توافرت سائر شروط الشفعة، و المفروض أن يكون هناك عقار و قد ورد عليه عقد البيع، فالشفعة لا تكون إلا في العقار، أما المنقول فيرد عليه حق الإسترداد دون حق الشفعة، ثم إن الشفعة غير قابلة للتجزئة، فلا يجوز تجزئة العقار أو العقارات محل البيع عند الأخذ بالشفعة و ذلك حتى لا تتجزأ الصفقة.

و منه نستخلص النتائج الآتية:

- لا شفعة في منقول،
 - الشفعة غير قابلة للتجزئة،
 - لا تجوز الشفعة إلا في عقد البيع،
 - جواز الأخذ بالشفعة في البيع غير المسجل،
 - الأخذ بالشفعة عند توالي البيوع.
- هذا من جهة، و من جهة أخرى أورد القانون المدني في المادة(798) ببيوعا لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة، حيث نصت على ما يلي:

" لا شفعة:

- إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون،
- وإذا وقع البيع بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة، و بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية،
- إذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل العبادة."
- وجود شفيع: هنا نتعرض لمسألتين في صدد وجود الشفيع هما، تحديد الشفعاء وتعدد الشفعاء و تزامهم.

* الشروط الواجب توافرها في الشفيع

حتى يستطيع الشفيع الأخذ بالشفعة، يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

- أن يكون مالكا للعقار المشفوع فيه من وقت بيع العقار المشفوع فيه إلى وقت ثبوت حقه في الشفعة،
- أن يكون متوافرا على الأهلية الواجبة أي (أهلية التصرف، إذ لا تكفي أهلية الإدارة بمعنى بالغ لسن الرشد و غير محجور عليه)،
- أن يكون غير ممنوع من شراء العقار المشفوع فيه،
- وأن لا يكون العقار المشفوع فيه عقارا واقفا.

4- كيفية الأخذ بالشفعة (أو إجراءات الشفعة) :

أ- إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة:

تنص المادة (799) من القانون المدني على ما يأتي: "على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشتري في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري و إلا سقط حقه، و يزداد على ذلك الأجل مدة المسافة إن إقتضى الأمر ذلك".

فهناك إجراءات تسبق إيداع الثمن و رفع دعوى الشفعة، و أول هذه الإجراءات هو الإجراء الذي يرمي إلى إخبار الشفيع بوقوع البيع، و يكون ذلك بإنذار رسمي يوجه إليه من المشتري أو من البائع، يلي ذلك علم الشفيع بوقوع البيع عن طريق الإنذار الرسمي أي أن يبدي الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة بإعلان رسمي لكل من المشتري و البائع في ميعاد معين، ثم يسجل الشفيع إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.

- إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة:

تنص المادة (801) من القانون المدني على ما يأتي: "يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبط، و إلا كان هذا التصريح باطلا. ولا يحتج بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا".

- ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة :

حسب نص المادة (802) من القانون المدني فإنه:

"يجب رفع دعوى الشفعة على البائع و المشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة (801) و إلا سقط الحق".

- تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة:

رأينا في المادة (801) على أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن يكون بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبط، وإلا كان هذا التصريح باطلا. فيستطيع بذلك الشفيع بعد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يسجل هذا الإعلان و يمضي في إجراءات الشفعة كما يلي ذكرها:

ب- إيداع الثمن، رفع دعوى الشفعة و صدور حكم بثبوت الحق فيها:

إن هذه المرحلة الثانية من إجراءات الشفعة تشمل خطوتين:

- إيداع الثمن بين يدي الموثق:

تنص المادة (2/801) من القانون المدني على ما يأتي: " يجب إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة. فإن لم يتم الإيداع في هذا الأجل على الوجه المتقدم، سقط الحق في الشفعة".

وعليه، فخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن يودع بين يدي الموثق الكائن في دائرته العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الأجل على الوجه المتقدم ، سقط الحق في الشفعة.

- رفع دعوى الشفعة و صدور حكم بثبوت الحق فيها:

تنص المادة (803) من القانون المدني على ما يأتي:

"يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري".

نشير إلى أن الخصوم في دعوى الشفعة هم كما يلي:

المدعي في دعوى الشفعة و هو الشفيع ، بينما المدعى عليه في دعوى الشفعة هو كل من البائع و المشتري، فرفع الدعوى على المشتري أو على البائع وحده لا يكفي، و هو

ما نصت عليه صراحة المادة (802) من القانون المدني، كما يلي: "يجب رفع دعوى الشفعة على البائع و المشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة (801) و إلا سقط الحق".

نستخلص من النصوص السابقة الذكر أنه إذا صدر حكم نهائي بثبوت حق الشفع في الشفعة، فإن هذا الحكم يعتبر سنداً لملكية الشفع للعقار المشفوع فيه، بمعنى السبب القانوني المنشئ لحق الملكية أو دليل الشفع على ملكية العين المشفوعة.

وفي الأخير يجب شهر هذا الحكم بطريق التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، وعليه فإنه لا تنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلا بعد تسجيل حكم الشفعة.

5- سقوط الحق في الشفعة :

حسب نص المادة (807) من القانون المدني، فإنه " لا يمارس حق الشفعة في

الأحوال الآتية:

- 1- إذا تنازل الشفع عن حقه في الشفعة و لو قبل البيع،
- 2- إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع،
- 3- في الأحوال التي نص عليها القانون..".

الإلتزامات

مقدمة:

القانون المدني هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة أو أحد فروعها بإعتبارها شخصا معنويا عاديا وليست صاحبة السيادة والسلطة، وغالبية هذه القواعد مكملة و مفسرة و ليست بقواعد ناهية.

إن النظرية العامة للإلتزام تهتم بصفة عامة بدراسة كل التصرفات القانونية والأعمال التي من شأنها التأثير في الذمة المالية للأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين زيادة أو نقصان، وبالأشياء المادية أو غير المادية التي تكون عادة موضوع الحق أو محل الإلتزام، و بالوسائل القانونية المتاحة التي تمكن الأفراد من كسب حقوقهم المالية إتجاه الغير.

أولاً: مفهوم الإلتزام:

لهذا المصطلح عدة معاني:

أ – الإلتزام بالمعنى العام:

يعني الواجب، كما يتعلق هذا الواجب بالأخلاق، الدين وكذا العلاقات الإجتماعية.

ب – الإلتزام بالمعنى التشريعي:

هو واجب يأمر به القانون، كإحترام قواعد المرور، السير على اليمين، إحترام إشارات المرور...الخ.

ج – الإلتزام بالمعنى المالي:

هو ما يسمى سند الإستحقاق والذي يثبت قرض يمنح من شخص لشركة مقابل فائدة مستحقة مهما كانت الحالة المالية للشركة، حيث تعرف المادة (715 مكرر 81) من القانون التجاري سندات الإستحقاق كما يلي "هي سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الإسمية".

د – الإلتزام بالمعنى القانوني:

هو عبارة عن علاقة قانونية ذات قيمة مالية قائمة بين شخصين، أولهما دائن والثاني مدين، مثلاً يلتزم البائع بتسليم المباع للمشتري، يعتبر البائع في هذه العلاقة دائناً أما

المشتري فهو مدين، حيث إذا نظرنا إلى هذه العلاقة من ناحية الدائن، تسمى الحق الشخصي لأن للدائن الحق في مطالبة المدين بما يقع من أداء، و إذا نظرنا إلى هذه الرابطة من ناحية المدين، تسمى إلزام.

ثانيا: خصائص الإلزام :

للإلزام القانوني ثلاث خصائص:

- الخاصية الأولى:

الإلزام القانوني إلزامي، أي يترتب أثرا تحميه الدولة، بحيث يمكن للدائن المطالبة أمام القضاء إجبار المدين على تنفيذه، و يقع إثبات الإلزام على عاتق الدائن.

- الخاصية الثانية:

للإلزام القانوني طابع شخصي، أي أنه تعهد شخصي، ويعرف الحق الشخصي بأنه حق لشخص يسمى الدائن في مطالبة شخص آخر هو المدين بالقيام بأداء معين ويختلف الحق الشخصي عن الحق العيني من حيث أن هذا الأخير يمنح لصاحبه سلطة مباشرة على شيء، كحق مالك العقار، إذن للإلزام القانوني ثلاثة عناصر، الدائن وهو العنصر الايجابي للحق، المدين وهو العنصر السلبي والأداء محل الإلزام.

- الخاصية الثالثة:

للإلزام القانوني قيمة مالية، بحيث يمكن تقدير أداء المدين بالنقود، لذا يدخل الإلزام في العناصر السلبية للذمة المالية للمدين، بينما يدخل ضمن العناصر الإيجابية للذمة المالية للدائن، ونشير إلى أن هذه الخاصية لا تعني بالضرورة أن تكون مصلحة الدائن مالية، فقد تكون أدبية كذلك، والمثال على ذلك أن يصاب الدائن بضرر معنوي سببه له المدين بخطئه، فأداء المدين الذي يتمثل في التعويض يقدر بالنقود، ويتميز الإلزام عن غيره من الواجبات القانونية التي لا يقدر فيها الأداء نقدا، كالعلاقات بين الزوجين أو بين الآباء والأولاد التي ينظمها قانون الأسرة وكذا الحقوق اللصيقة بالشخصية، كحق الإنسان في الإسم واللقب والحق في الأمن.

ثالثا: تقسيمات الإلزامات:

يصنف الإلزام على ثلاثة أسس حسب محله، قوته القانونية وعلى أساس مصدره:

1- تصنيف الإلتزام حسب المحل:

كما سلف ذكره، يعرف الإلتزام كحق شخصي و هو مطالبة الدائن لشخص آخر وهو المدين، بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، حسب المادة (54) من القانون المدني، فيعتبر الدائن كطرف إيجابي والمدين كطرف سلبي، تختلف القواعد القانونية الواجبة التطبيق على الرابطة القانونية القائمة بينهما حسب أداء محل الإلتزام، فتتص المادة (54) من القانون المدني على التصنيف الأول للإلتزام حسب المحل، أما التصنيف الثاني يتعلق بالإلتزام بتحقيق غاية و الإلتزام ببذل عناية.

أ- الإلتزام بمنح، أو بفعل، و الإمتناع عن فعل شيء ما:

كرس المشرع هذا التقسيم في المادة (54) من القانون المدني التي تنص على مايلي: "العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين، بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"، يعتبر هذا التقسيم التشريعي أساسي إذ يشمل كافة أنواع الإلتزامات.

- **الإلتزام بالمنح:** هو الإلتزام بنقل الملكية و ليس إلتزام بإعطاء شيء، ولا يعني كذلك الإلتزام بمنح شيء، يذهب بعض الفقهاء إلى القول أن الإلتزام بالمنح هو الإلتزام بالإعطاء.

- **الإلتزام بالفعل:** هو الإلتزام بقيام بفعل إيجابي، كالإلتزام المقاول بإنجاز أشغال أو إلتزام البائع بتسليم الشيء المباع.

- **الإلتزام بالإمتناع عن الفعل:** يلتزم بموجبه المدين بعدم قيام بفعل معين، كالإلتزام عامل بعدم منافسة رب عمله يوم مغادرة عمله، أو إلتزام التاجر بالجملة ببيع بضاعة معينة لتاجر التجزئة دون سواه.

- **الإلتزام بتحقيق نتيجة والإلتزام ببذل عناية:** كرس المشرع هذا التقسيم ولو بصفة غير مباشرة و ذلك في المادتين (172 و 176) من القانون المدني.

- **الإلتزام بتحقيق نتيجة:** هو الإلتزام الذي يتعهد فيه المدين بتحقيق نتيجة متفق عليها وقت إبرام العقد، وفي حالة عجز المدين، يفترض أنه مسؤولا إلا إذا استطاع أن يثبت أن عدم الوصول إلى النتيجة المتفق عليها يرجع لسبب أجنبي.

نستخلص هذه القاعدة من المادة (176) من القانون المدني التي تنص على ما يلي: " إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا، حكم عليه بتعويض الضرر الناجم

عن عدم تنفيذ إلتزامه، ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه"، ومثال على الإلتزام بتحقيق نتيجة، إلتزام الناقل الذي يتعهد بنقل شخص أو بضاعة من مكان إلى مكان معين و محدد.

- الإلتزام ببذل عناية: تنص المادة (172) من القانون المدني على أن: " في الإلتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيلة في تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية، كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على خلاف ذلك. وعلى كل حال، يبقى المدين مسؤولاً عن غشه أو خطئه الجسيم".

يلاحظ أنه في الإلتزام ببذل عناية، لا يسأل عن عدم تحقق النتيجة، بل يسأل عن سلوكه أثناء تنفيذ الإلتزام، فعلى الدائن أن يثبت خطأ المدين، أي أن هذا الأخير لم يبذل عناية الرجل العادي وأثناء تقييمه خطأ المدين يعتمد القاضي معيار الرجل العادي، أي المعيار الموضوعي حيث يقاس سلوك المدين بسلوك شخص يكون في نفس الوضعية، نفس السن وله نفس التكوين... ومثال على ذلك، إذا كان المدين طبيباً فيكون مقياس سلوكه سلوك طبيب في نفس الاختصاص ذو تجربة مماثلة ويمارس وظيفته في نفس الظروف نلاحظ إذن أن معيار الرجل العادي هو معيار نسبي، مثلاً إلتزام الطبيب هو إلتزام ببذل عناية إذ يلتزم بعلاج المريض وفق المعطيات العلمية و ليس بشفائه.

تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب هذا الإلتزام الرئيسي، وضع قانون أخلاقيات الطب إلتزامات بتحقيق نتيجة على عاتق الطبيب كإلتزام بالسر المهني، وكذلك لا يلتزم المحامي بكسب القضية، بل يتعهد بمعالجتها بجدية بإستعمال كل الطرق القانونية التي تساعد في مهمته.

من أمثلة الإلتزام ببذل عناية في القانون المدني، ما جاء في أحكامه المتعلقة ببعض العقود المسماة، عقد الوكالة حيث يتعهد فيه الوكيل ببذل عناية الرجل العادي في تنفيذ الوكالة حسب المادة (576) من القانون المدني، كذلك الحال فيما يخص عقد الوديعة بأجر إذ يلتزم المودع لديه ببذل في حفظ الشيء المودع عناية الرجل المعتاد حسب المادة (2/592) من القانون المدني.

تكمن أهمية التقسيم بين الإلتزام بتحقيق نتيجة و الإلتزام ببذل عناية في قواعد إثبات الإخلال بالإلتزام، فإذا كان الإلتزام بتحقيق نتيجة، على الدائن أن يثبت فقط عدم الوصول إلى الغاية المرجوة إذ أن عبئ الإثبات يقع في الحقيقة على المدين، بحيث عليه أن يثبت أنه لا يد له في حدوث الضرر وأن عدم تحقق النتيجة راجع لتدخل سبب أجنبي، أما إذا إلتزم المدين ببذل عناية فعلى الدائن أن يثبت عدم بذل العناية الكافية، أي عليه أن يثبت خطأ المدين.

يلاحظ بأنه للقاضي دورا جوهريا في تحديد طبيعة الإلتزام، و يمكن أن يتضمن العقد إلتزامات ببذل عناية و إلتزامات بتحقيق غاية، تجدر الإشارة إلى أن الإلتزام بالمنح هو إلتزام بتحقيق نتيجة إذ يتعلق الأمر بنقل ملكية شيء معين أو حق عيني آخر، كذلك يكون الإلتزام بالإمتناع عن الفعل، أما الإلتزام بالفعل قد يكون إلتزاما ببذل العناية أو إلتزاما بتحقيق نتيجة.

2- تصنيف الإلتزام حسب قوته القانونية:

كما أشرنا إليه سالفا، الإلتزام القانوني هو علاقة قانونية قائمة بين شخصين أو أكثر ترتب آثارا قانونية، حيث تختلف هذه الآثار حسب نوع الإلتزام القانوني الذي يتفرع إلى نوعين، الإلتزام المدني والإلتزام الطبيعي ولهما قوة قانونية مختلفة.

يتميز الإلتزام المدني بطابعه الإلزامي، فالإخلال به يؤدي إلى قيام مسؤولية المدين وعلى القاضي أن يضمن تنفيذه، و يتمتع الدائن بحق رفع الدعوى لمطالبة التنفيذ الجبري لأن عنصر المسؤولية متوفر في الإلتزام المدني.

أما الإلتزام الطبيعي فلا تتوفر فيه هذه الحماية بصفة كاملة، إذ لا يمكن المطالبة بتنفيذه أمام القضاء ولا إجبار المدين على الوفاء به، وبالتالي عنصر المسؤولية غائب في هذا الإلتزام خلافا للإلتزام المدني طبقا لأحكام المادة (160) من القانون المدني التي تنص على ما يلي: " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به، غير أنه لا يجبر على التنفيذ إذا كان الإلتزام طبيعيا". فعنصر المسؤولية منعدم في الإلتزام الطبيعي.

نظم المشرع الإلتزام الطبيعي في القانون المدني من المادة (2/160) إلى المادة (163)، تجدر بنا الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف تشريعي للإلتزام الطبيعي ولم يتم تحديده،

وذلك لأنه لا يمكن حصر الإلتزامات الطبيعية. وفي هذا الشأن تؤكد لنا المادة (161) من القانوني المدني أن للقاضي دورا رئيسيا في تكييف الإلتزام الطبيعي.

أ- خصائص الإلتزام الطبيعي:

- الخاصية الأولى:

إنه في حالة غياب نص قانوني يحدده، يتمتع القاضي بسلطة تقديرية تامة لتكييف الإلتزام الطبيعي.

- الخاصية الثانية:

يجب أن لا يخالف الإلتزام الطبيعي النظام العام، حيث لا يمكن مثلا لشخص أن ينفق على ابن غير شرعي أو على خليلته.

- الخاصية الثالثة:

لا يجبر المدين بتنفيذ الإلتزام الطبيعي، لكن إذا نفذه بمحض إرادته لا يمكن أن يسترد ما دفعه.

ب- آثار الإلتزام الطبيعي:

يرتب الإلتزام الطبيعي آثار قانونية، و هي:

- لا يستفيد الدائن بدعوى قضائية لمطالبة المدين بالتنفيذ الجبري للإلتزام الطبيعي.
- إذا قام المدين بتنفيذ الإلتزام الطبيعي بمحض إرادته، ليس له الحق في الإسترداد إذ لا يعتبر ما دفعه غير مستحق.

ج- إمكانية تغيير الإلتزام الطبيعي إلى إلتزام مدني:

تنص المادة (163) على ما يلي: " يمكن أن يكون الإلتزام الطبيعي سببا لإلتزام مدني".
إذا تعهد المدين كتابيا بتنفيذ إلتزام طبيعي، تتغير طبيعته من إلتزام طبيعي إلى إلتزام مدني، و بالتالي للدائن الحق في المطالبة القضائية بالتنفيذ الجبري، كما يمكن القول أن الإلتزام الطبيعي هو إلتزام وسطي بين الإلتزام المدني و الواجب الخلقي، يتمثل في وجود حق دون دعوى للمطالبة به و ذلك لا قبل الوفاء و لا بعده.

3- تصنيف الإلتزام حسب مصدره:

يصنف الإلتزام حسب مصدره وفقا لما نص عليه المشرع في القانون المدني و وفقا لتصنيف فقهي.

أ- التصنيف التشريعي:

نص المشرع على مصادر الإلتزام في القانون المدني في الباب الأول (مصادر الإلتزام) من الكتاب الثاني (الإلتزامات و العقود) وهي القانون حسب المادة (53)، العقد في المادة (54) و ما يليها، الإلتزام بالإرادة المنفردة حسب المادة (123) مكرر والمادة (123) مكرر 1، العمل المستحق للتعويض المادة (124) وما يليها، وشبه العقود المادة (141) وما يليها.

ب- التصنيف الفقهي: التصرف القانوني والواقعة القانونية.

- **التصرف القانوني:** هو عمل إرادي يصدر عن شخص ويرتب إلتزامات وآثار قانونية، إذا إقترن هذا التصرف بإرادة شخص آخر نكون بصدد عقد، أما في حالة عدم إقترانه بإرادة أخرى، يسمى هذا التصرف إلتزاما بإرادة منفردة كالوصية و الوعد بالجائزة.

- **الواقعة القانونية:** يمكن أن تكون هذه الواقعة مادية محضة، وهي حادثة تقع دون إرادة الشخص كالوفاة والولادة، كما يمكن أن تكون الواقعة المادية عبارة عن عمل إرادي لا يهدف إلى إحداث إلتزامات قانونية مثلا، الضرب العمدي الذي يشكل خطأ تقصيريا وهو مصدر لإلتزام بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه.

إن مصادر الإلتزام حسب الترتيب الوارد في القانون المدني هي القانون، العقد، الإلتزام بإرادة منفردة، الفعل المستحق للتعويض و شبه العقد.

* **القانون:** المادة (53) من القانون المدني " تسري على الإلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها من النصوص القانونية التي قررتها".

* **العقد:** المادة (54) من القانون المدني " العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخريين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما "، و تضيف المادة (55) من نفس القانون على أن " يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الإلتزام بعضهما بعضا. " و " يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخريين، دون التزام من هؤلاء الآخريين. " حسب المادة (56).

* **الإلتزام بالإرادة المنفردة:** أشارت إليه كل من المادة (123) مكرر والمادة (123) مكرر 1 كما يلي: " يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير.

ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام، بإستثناء أحكام القبول. "، حسب المادة (123) مكرر.

أما المادة (123) مكرر 1، فقد تطرقت إلى الوعد بجائزة، حيث نصت على أنه " من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين، يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل، و لو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم به. و إذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. يمارس حق المطالبة بالجائزة، تحت طائلة السقوط، في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور".

قانون الصفقات العمومية

مقدمة:

إنّ تحيين التشريعات المنظمة للصفقات العمومية من فترة لأخرى، هدفه يدور حول عنصرين بارزين، هما نجاعة الطلبات العمومية و حسن إستعمال المال العام، لتحقيق هذان الهدفان، حدد المشرع مبادئ يجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل إبرام الصفقات العمومية، وآليات وهيئات مستقلة لضمان سلامة عمليات إبرامها وفق القواعد التي وضعها المشرع.

أولاً- تعريف الصفقات ومجال (نطاق) تطبيقها في ظل قانون الصفقات العمومية الجزائري:

- إن المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، الذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010، يعرف الصفقات العمومية في مواده من (01،02 و03) على أنها عقود مكتوبة تبرم قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات بمقابل مع متعاملين إقتصاديين وفق شروط معينة في المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال، اللوازم، الخدمات والدراسات، ولا تصح إلا بموافقة السلطة المختصة حسب الحالة (الوزير، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، المدير العام أو مدير أو مسؤول الهيئة العمومية) أو بتفويض مسؤول عنها.

- فالصفقات العمومية هي عقود إدارية لها إمتياز السلطة العامة على أحكام وقواعد العقود الخاصة، فهي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عندما تلجأ الإدارة إلى إبرام عقود مع أطراف أخرى عامة أو خاصة تتعلق عادة بسير وتنظيم المرفق العام عن طريق عقود يمكن أن تكون عقود تفويض أو عقود إمتياز أو عقود أخرى، أهمها عقود الأشغال العامة أو عقود التوريد.

ثانياً- نطاق (مجال) تطبيق الصفقات العمومية:

تخضع لأحكام هذا المرسوم لاسيما المادة (06) منه، جميع الصفقات العمومية

محل نفقات:

- الدولة.
 - الجماعات الإقليمية.
 - المؤسسات العمومية ذات طابع إداري.
 - المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من الدولة أو الجماعات المحلية.
 - لا تخضع لأحكام الباب الأول من المرسوم أعلاه العقود الإدارية الآتية:
 - المبرمة من طرف الهيئات و الإدارات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينها.
 - المبرمة مع المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من الدولة أو من الجماعات المحلية عندما لا تزال هذه المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة.
 - المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاريع .
 - المتعلقة بإقتناء أو تأجير أراض أو عقارات.
 - المبرمة مع بنك الجزائر.
 - المبرمة بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الإتفاقيات الدولية، عندما يكون ذلك مطلوبا.
 - المتعلقة بخدمات الصلح و التحكيم.
 - المبرمة مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة و التمثيل.
 - المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام الباب الأول من المرسوم وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة.
- ملاحظة:** لا تخضع المؤسسات العمومية الإقتصادية لأحكام إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في الباب الأول من المرسوم، مع ذلك يتعين عليها وعلى كل هيئة مهما كان وضعها القانوني التي تستعمل أموالا عمومية، إعداد إجراءات إبرام الصفقات العمومية حسب خصوصيتها على أساس مبادئ حرية الإستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية الإجراءات والعمل على إعتمادها من طرف هيئاتها الإجتماعية، حسب المواد (07،09 و 11).

ثالثا - المعيار المالي للصفقات العمومية : la notion financière :

إن من أهداف تنظيم الصفقات العمومية هو حسن إستعمال المال العام نظرا لإرتباطها بالخزينة العامة، لذلك وجب ضبط حد مالي أدنى لإعتبار العقد صفقة عمومية وإلزامها عند إبرامها للخضوع لإجراءات قانون الصفقات العمومية من إشهار، رقابة و قيود أخرى.

فالمشرع هو الذي يحدد الحد الأدنى للصفقات العمومية مع إمكانية تغيير هذا الحد بين فترة و أخرى حسب الظروف الإقتصادية للبلاد.

فالحد الأدنى المشترك لعقود الأشغال واللوازم يختلف عن عقود الدراسات والخدمات فالأولى تتطلب أموالا كبيرة نظرا لطبيعتها، وكلما إرتفعت مبالغ الصفقة العمومية إشتدت وتغيرت نوع الرقابة و هيئاتها.

كل صفقة عمومية يساوي المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة إثني عشر مليون دينار (12 000 000 دج) أو يقل عنه للأشغال واللوازم، وستة ملايين دينار جزائري (6 000 000 دج) للدراسات أو الخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا الباب.

بهذه الصفقة تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام هذه الطلبات، و عندما تختار المصلحة المتعاقدة أحد الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، فإنه يجب عليها مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراء حسب المادة (13).

- يجب أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه، محل إشهار ملائم وإستشارة متعاملين إقتصاديين مؤهلين، كتابيا لإنتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية حسب المادة (14).

- لا تكون محل إستشارة وجوبا، الطلبات التي تقل مجموع مبالغها حسب طبيعتها أشغالا أو لوازم أو دراسات أو خدمات خلال نفس السنة المالية عن (1 000 000 دج) فيما يخص الأشغال أو اللوازم وعن (500 000 دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية على حدى حسب المادة (21).

رابعاً - صحة الصفقات العمومية:

لا تصح الصفقات العمومية ولا تكون نهائية، إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه حسب الحالة:

- مسؤول الهيئة العمومية.
 - الوزير.
 - الوالي.
 - رئيس المجلس الشعبي البلدي.
 - المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.
- ويمكن لكل سلطة من هذه السلطات أعلاه، تفويض صلاحياتها بإبرام وتنفيذ الصفقات إلى المسؤولين المكلفين حسب المادة (04).

خامساً - مبادئ الصفقات العمومية:

إن المادتين (05 و 11) من المرسوم المذكور سابقاً، تلزم عند إعداد إجراءات إبرام الصفقات إحترام المبادئ التالية:

- مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية.
 - مبدأ المساواة في معاملة المرشحين.
 - مبدأ الشفافية في الإجراءات.
- هذه المبادئ بالإضافة إلى اعتماد الصفقات من طرف هيئاتها المؤهلة لضمان نجاعة الطلبات العمومية من أجل الإستعمال الحسن للمال العام و المحافظة عليه.

سادساً - طرق إبرام الصفقات العمومية:

تبرم الصفقات العمومية وفقاً لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي حسب المادة (39).

1- طلب العروض: المواد من (40 إلى 48)

هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاهدين متنافسين، مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية، إستناداً إلى معايير إختيار موضوعية، تعد قبل إطلاق الإجراء.

ويعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لا يتم إستلام أي عرض أو عندما لا يتم الإعلان بعد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط، أو عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات.

- إجراء طلب العروض يمكن أن يكون وطنيا أو دوليا، و يمكن أن يتم حسب أحد الأشكال التالية:

أ- طلب العروض المفتوح:

هو إجراء يمكن من خلاله لأي مرشح مؤهل أن يقدم تعهدا.

ب- طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا:

هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء بتقديم تعهد، ولا يتم إنتقاء قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة.

تخص الشروط المؤهلة، القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة وتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع.

ج- طلب العروض المحدود: المادة (45)

هو إجراء لإستشارة إنتقائية، يكون المرشحون الذين تم إنتقائهم الأولي من قبل مدعويين وحدهم لتقديم تعهد.

يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحين الذين ستم دعوتهم لتقديم تعهد بعد إنتقاء أولي لخمس (05) منهم.

تنفذ المصلحة المتعاقدة الإنتقاء الأولي لإختيار المرشحين لإجراء المنافسة، عندما يتعلق الأمر بالدراسات أو بالعمليات المعقدة ذات الأهمية الخاصة.

يجرى طلب العروض المحدود عند تسلم العروض التقنية إما على مرحلتين أو على مرحلة واحدة.

في حالة طلب العروض المحدود على مرحلتين، تتم دعوة المرشحين الذين تم إنتقاؤهم الأولي في مرحلة أولى برسالة إستشارة إلى تقديم عرض تقني أولي دون عرض مالي.

يمكن للجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط، أن تطلب كتابيا بواسطة المصلحة المتعاقدة من المرشحين تقديم توضيحات أو تفاصيل بشأن عروضهم حسب المادة (46).

د- المسابقة:

هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة لإختيار بعد رأي لجنة التحكيم المذكورة في المادة (48)، مخطط أو مشروع مصمم إستجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب تقنية أو إقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة حسب المادة (47).

وتمنح الصفقة بعد المفاوضات للفائز بالمسابقة الذي قدم أحسن عرض من الناحية الإقتصادية.

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة لاسيما في مجال تهيئة الإقليم والتعمير والهندسة المعمارية أو معالجة المعلومات.

لا تبرم صفقة الإشراف على إنجاز أشغال وجوبا عن طريق المسابقة إذا لم يتجاوز مبلغها اثني عشر مليون دينار (12 000 000 دج) و إذا كان يتعلق موضوعها بالتدخل في مبنى قائم أو منشأة بنية تحتية أو التي لا تحتوي على مهام تصميم.

مهما يكن من أمر، فإنه يتعين تعيين لجنة التحكيم المذكورة في المادة (48)، لتبدي رأيها في إختيار المخطط أو المشروع.

ملاحظة: يمكن أن تكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع إشتراط قدرات دنيا حسب المادة (48).

2- التراضي:

حسب المادة (49)، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية:

- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل إقتصادي وحيد يحتل وضعية إحتكارية أو لحماية حقوق حصرية أو لإعتبرات ثقافية، فنية، وتوضح الخدمات المعنية بالإعتبرات الثقافية و الفنية بموجب قرار وزاري مشترك ما بين وزير الثقافة و وزير المالية.

- في حالة الإستعجال الملح بوجود خطر يهدد إستثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمارا قد يجسد في الميدان بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الإستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للماطلة من طرفها.
- في حالة تمويل مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي إستوجبت هذا الإستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للماطلة من طرفها.
- عندما يتعلق بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابع الإستعجال، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايين دينار (10.000.000.000) أو موافقة مسبقة من الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.
- عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج، بشرط موافقة مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايين دينار (10.000.000.000) دج وإلى موافقة مسبقة من الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.
- عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية أو عندما تنتجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- تستشير المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة إستشارة، وبنفس دفتر الشروط، بإستثناء الأحكام الخاصة، ويمكن للمصلحة المتعاقدة تقليص مدة تحضير العروض، ولا يخضع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية حسب المادة (52).
- يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة في الحالات المنصوص عليها في المادة (51) برسالة إستشارة على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الإجراء لتأشيرة لجنة الصفقات العمومية.

- عندما تلجأ المصلحة المتعاقدة مباشرة للتراضي بعد الإستشارة ولا تستلم أي عرض أو أنه لا يمكن بعد تقييم العروض المستلمة إختيار أي عرض، تعلن عدم جدوى الإجراء.

سابعا- الإجراءات الداخلية لإبرام الصفقات العمومية وفق الإجراءات المكيفة:

في إطار تطبيق أحكام المادة (2/13) من المرسوم أعلاه، فإن:

أ- الطلبات التي يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المسيرة إثني عشر مليون دج (12000.000 دج) أو يقل عنه بالنسبة للأشغال أو اللوازم.

ب- الطلبات التي يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المسيرة ستة ملايين دج (6000.000 دج) للدراسات و الخدمات.

- فإن هذه الطلبات لا تتطلب وجوبا إبرام صفقة عمومية حسب الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المرسوم أعلاه.

- تقوم المصلحة المسيرة بفتح سجل للمتعاملين الإقتصاديين، يقسم حسب طبيعة كل طلب (صفقة) سواء (أشغال، لوازم، خدمات و دراسات)، يكون مرقما و مؤشرا من طرف رئيس المصلحة، و يمكن تحيينه بإضافة عروض الخدمات الواردة إلى المصلحة المسيرة.

- تلجأ المصلحة المسيرة بمناسبة كل طلبية إلى إجراء الإستشارة، مع مراعاة أن تكون هذه الأخيرة محل إشهار ملائم، و موجهة كتابيا إلى المتعاملين الإقتصاديين المؤهلين لإقتناء أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية.

- تنظم هذه الإستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الإقتصاديين الذين بإمكانهم الإستجابة لها، مع مراعاة أحكام المادة (05) من نفس المرسوم و التي تتمحور أساسا في مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الإجراءات.

- يمكن للمصلحة المسيرة اللجوء إلى الإجراءات المكيفة عندما يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة بالنقل، الفندقية، الإطعام و الخدمات القانونية، مهما كانت مبالغها.

- تعفى الطلبات المبرمة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة (49) من نفس المرسوم من الإستشارة.

- في حالة طلبات الأشغال التي لا تستوجب تقديم شهادة التصنيف و التأهيل المهنيين، يمكن للمصلحة المسيرة أن تستشير الحرفيين المؤهلين في مجال الاختصاص.
- يمكن للمصلحة المسيرة، حسب الشروط المحددة في المواد (135) إلى (139) من نفس المرسوم، أن تبرم ملاحق للصفقة العمومية محل الطلب الأولي، المبرم حسب الإجراءات المكيفة.

ثامنا - رقابة الصفقات العمومية:

- تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده في شكل رقابة داخلية، رقابة خارجية ورقابة الوصاية، بحيث يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد في بداية كل سنة مالية، قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الحائزة عليها، والبرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الإنطلاق فيها خلال السنة المالية.

1- الرقابة الداخلية ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض: المواد (159 إلى 162)

- تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة واحدة أو أكثر تكلف بفتح الأظرفة وتحليل العروض والبدائل والأسعار الاختيارية، تتشكل من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءتهم، ويمكن لها إنشاء لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض لحاجات أو لفائدة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض.

- ترسل المصلحة المسيرة فور الشروع في الإجراءات نسخة من ملف الإستشارة إلى لجنة فتح الأظرفة وانتقاء العروض، لمباشرة فتح الأظرفة وتقييم العروض الواردة يوم إيداعها والمحدد سلفا في رسائل الإستشارة بآخر يوم من مدة تحضير العروض.

- تقوم لجنة فتح الأظرفة وانتقاء العروض في إطار الإستشارة المبرمة وفقا للإجراءات المكيفة، بفتح العروض الواردة وتقييمها وفقا للمعايير المحددة سابقا في رسائل الإستشارة أو دفاتر الشروط، وتعد في هذا الصدد محضر الفتح والتقييم الذي يمضى من طرف الأعضاء الحاضرين.

- تعد لجنة فتح وانتقاء العروض محضرا بعدم جدوى الإجراء في الحالات المنصوص عليها في المادة (7/52) من نفس المرسوم و المتعلقة بعدم إستلام أي عرض أو عدم مطابقة العروض المقدمة، كما يمكن لها أن تعد محضرا بعدم جدوى الإجراء في

حالة تجاوز مبلغ العملية سقف الصفقة العمومية ما عدى فيما يتعلق بصفقات الخدمات الخاصة المنصوص عليها في المادة (24).

تسجل لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة و تقييم العروض في سجلين خاصين يرقمهما الأمر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف الأولى.

2- الرقابة الخارجية:

تتمثل غاية الرقابة الخارجية في إطار العمل الحكومي في التحقق من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة على الهيئات الخارجية (اللجنة الجهوية، الولائية، البلدية ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الإدارية، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية، اللجان القطاعية للصفقات الخاصة بالوزارات) للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصفقات العمومية، وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من مطابقة إلتزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية حسب المادة (163).

3- هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية:

تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة (الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسة العمومية التجارية عند إنجاز مشروع ممول من الدولة)، لجنة الصفقات تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المادتين (173 و 174) من المرسوم أعلاه، يعين أعضاؤها بموجب مقرر من رئيس اللجنة (بالنسبة إلى اللجان الجهوية، الولائية و البلدية) أو بمقرر من السلطة الوصية على المؤسسة العمومية (بالنسبة إلى لجنتي الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، والمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الإداري والهيكل غير الممركزة التابعة لهما) حسب المادتين (165 و 166).

- يحدد مسؤول الهيئة العمومية (الوزير، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية) تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية، تكون إختصاصات هذه اللجنة و قواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات حسب المادة (167).

- تمارس الرقابة على الصفقات العمومية لمجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني وفق القواعد التي يسنها النظام الداخلي لكل منهما حسب المادة (2/167).
- تختص بالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، حصريا لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلاتها و صلاحيتها حسب المادة (168).

4- رقابة الوصاية:

تتمثل غاية الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في:

* التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية و الإقتصاد.

* التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع.

و تعد المصلحة المتعاقدة عند الإستلام النهائي للمشروع تقريراً تقييماً عن ظروف إنجازه و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلاً.

يرسل هذا التقرير حسب طبيعة النفقة الملزم بها إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، و كذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة.

ترسل نسخة من هذا التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام المنشأة بموجب المادة (213) من هذا المرسوم.

تاسعا- التسيير و التأشير:

1- التسيير : le fonctionnement

إن المرسوم الرئاسي قد وضع القواعد الأساسية المتعلقة بكيفية عمل اللجنة وتسييرها، كما يتضح مما يلي:

أ- **الاجتماعات:** تنص المادة (191) بأنه تجتمع اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة (الجهوية، الولائية، البلدية، المؤسسة العمومية الوطنية والمحلية وهياكلها المركزية ذات الطابع الإداري) على القواعد الأساسية الآتية:

- ينعقد الاجتماع بناء على مبادرة من رئيس كل منهما (الوزير المعني، الوزير المكلف بالمالية، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري).

- يشترط لصحة الاجتماع، حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد بعد ثمانية (08) أيام الموالية وتصح مداولتها حينئذ مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

- الأصل أن الحضور شخصي وفي حالة الغياب أو وجود مانع لهم لا يمكن أن يمثلهم إلا مستخلفوهم.

ب- كتابة اللجنة:

تزود لجنة الصفقات بكتابة دائمة، حيث تنص المادة (199) عن إختصاصاتها فيما يلي:

تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها، لا سيما ما يلي:

- التأكد من أن الملف المقدم كامل بالإستناد إلى أحكام هذا المرسوم وحسب ما هو مبين في النظام الداخلي.

- تسجيل ملفات مشاريع الصفقات ومشاريع الملاحق، وكذلك أية وثيقة تكميلية وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك.

- إعداد جدول الأعمال.

- إعداد إستدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارين المحتملين.

- إرسال الملفات إلى المقررين.

- إرسال المذكرة التحليلية لمشروع الصفقة أو الملحق و التقرير التقديمي إلى أعضاء اللجنة.

- إرسال ملفات مشاريع دفاتر الشروط و الطعون إلى أعضاء اللجنة.

- تحرير التأشيرات و المذكرات و محاضر الجلسات.
- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط.
- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها.
- متابعة رفع التحفظات المنصوص عليها في المادة (195) من هذا المرسوم بالإتصال مع المقرر.

ج- المداولات:

- تسري على مداولات اللجنة أحكام المادتين (191/3 و 192) كما يلي:
- تتخذ المداولات بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجتمع اللجنة من جديد في غضون ثمانية (08) أيام الموالية وتصح مداولتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
- في حالة التساوي للأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
- تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات بصوت تداولي والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات، كما يتحمل إلتزامات منها الحضور للإجتماع بانتظام والحفاظ على السر المهني.

2- التأشيرة: le visa:

- اللجنة مركز إتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات العمومية الداخلة في نطاق إختصاصها، وبهذه الصفة، يمكن لها منح التأشيرة أو رفضها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون هذا الرفض معللا.
- إذا كان إبرام الصفقة موافقا تماما للتشريع أو التنظيم المعمول بهما، تقوم اللجنة بمنح التأشيرة و العكس، إذا تم معاينة مخالفة لها تكون سببا لرفض التأشيرة.
- مع ذلك، فإن تشريع الصفقات العمومية أجاز للمصلحة المتعاقدة أن تواصل تقييم العروض في ظل إحترام المرسوم أعلاه عندما ترفض لجنة الصفقات المختصة منح التأشيرة أو تقر أن طعنا ما مؤسس.
- و يمكن أن تمنح التأشيرة مرفقة بتحفظات:
- إما تحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة، مثل دفتر الشروط الخاص بالصفقة أو الملحق.

- إما تحفظات غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة.
- وتعرض المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة أو الملحق بعد أن تكون قد رفعت التحفظات المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية المختصة، على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة عليها والبدء في تنفيذها بإستثناء مشروعا الصفقة وملحق البلديات التي تخضع لمداولة المجلس الشعبي البلدي قبل إرسالهما إلى لجنة الصفقات المختصة حسب المادة (195).
- التبليغ: في جميع الحالات يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المتخذة من اللجنة وذلك بعد ثمانية (08) أيام على الأكثر من إنعقاد الجلسة حسب المادة (195).

3- طلب التأشيرة:

- يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة من لجنة الصفقات العمومية وتكون ملزمة للمصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب المكلف، إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية تتعلق بالصفقات، وفي هذه الحالة يجب على المراقب المالي والمحاسب المكلف فقط أن يعلما كتابيا لجنة الصفقات العمومية المختصة التي بإمكانها بعد إخطارها سحب تأشيرتها قبل تبليغ الصفقة للمتعهد المختار.
- وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة، وجب عليها إعلام بذلك لجنة الصفقات العمومية المختصة.
- تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو الملحق وجوبا مقابل وصل إستلام في غضون خمسة عشر (15) يوما الموالية لإصدارها لدى المصالح المختصة إقليميا للضرائب والضمان الإجتماعي التي تتبعها المصلحة المتعاقدة، والتي ترسل بدورها هذه المقررات كل ثلاثة (03) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للضرائب) وإلى الوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي (المديرية العامة للضمان الاجتماعي) لجمعها وإستغلالها حسب المادة (196).

4- آثار رفض التأشيرة:

يترتب في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشيرة ما يأتي:

- يمكن الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مسؤول الهيئة العمومية المعني كل في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوزوا ذلك بمقرر معل على أن ترسل نسخة منه إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية (سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمفتشية العامة للمالية) وإلى لجنة الصفقات العمومية المعنية حسب المادة (200).

ملاحظة:

مقرر التجاوز لا يمكن إتخاذه في حالة رفض التأشيرة المعل لعدم مطابقته الأحكام التشريعية، بينما يمكن إتخاذه لعدم مطابقته الأحكام التنظيمية و يفرض على المراقب المالي والمحاسب العمومي المختص حسب المادة (202).

ويقتصر فقط على حالة رفض التأشيرة نظرا لعدم مطابقة إجراءات إبرام الصفقة للأحكام التنظيمية (مراسيم، قرارات.... إلخ) أي الأعمال الإدارية les Actes Administratifs حسب المادة (202).

- يشترط لصحة مقرر التجاوز أن يذكر في صلبه السبب الدافع إلى عدم الإعتداد بقرار رفض التأشيرة و ثم الانتقال إلى تنفيذ الصفقة، و مهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن إتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.

5- مبدأ حماية الاقتصاد الوطني:

أستحدث المرسوم السالف الذكر لعدة إجراءات ترمي إلى حماية الإقتصاد الوطني ومنح الأفضلية للمؤسسات و المنتجات الوطنية.

6- ترقية الإنتاج الوطني و الأداة الوطنية للإنتاج:

يمنح هامش الأفضلية بنسبة 25% للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة من المادة (29) من المرسوم أعلاه و تشمل (إنجاز الأشغال، إقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، تقديم الخدمات).

- عندما يكون الإنتاج أو أداة الإنتاج الوطني قادرين على الإستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فإن على هذه الأخيرة أن تصدر دعوة للمنافسة الوطنية

مع مراعاة حالات الإستثناء المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم حسب المادتين (83 و 87).

7- مكافحة الفساد:

إستحدث المشرع الجزائري جملة من الإجراءات تناولتها المواد من (88 إلى 94) و المادتين (213 و 214) لمكافحة الفساد على النحو الآتي:

أ- سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام: المواد (88، 89 و 213) حيث تم إنشاء لدى وزير المالية سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تتمتع باستقلالية التسيير، وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعات، تتولى هذه السلطة الصلاحيات الآتية:

- تعد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام و تنفيذ الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية.

- يطلع الأعوان العموميون المذكورون أعلاه على المدونة، و يتعهدون بإحترامها بموجب تصريح، كما يجب عليهم الإمضاء على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح ويرفق نموذجا هذين التصريحين بالمدونة.

- إعداد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ومتابعة تنفيذه وتصدر بهذه الصفة، رأيا موجهها للمصالح المتعاقدة وهيئات الرقابة ولجان الصفقات العمومية و لجان التسوية الودية للنزاعات و المتعاملين الإقتصاديين.

- إعلام ونشر وتعميم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

- المبادرة ببرامج التكوين وترقية التكوين في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

- التدقيق أو تكليف من يقوم بالتدقيق في إجراءات إبرام الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، و تنفيذها بناء على طلب من كل سلطة مختصة.

- البث في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الأجانب.

- تسيير و إستغلال نظام المعلوماتية للصفقات العمومية.
- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية المتدخلة في مجال الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- تمسك قائمة المتعاملين الإقتصاديين ممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وتحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المنع بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية حسب المادة (89).

ب- الإحصاء الإقتصادي للطلب العمومي: المادتين (213 و 214)

سابقا كانت المادة (175) من المرسوم الملغى 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 تنص على إستحداث مرصد إقتصادي للطلب العمومي يتولى سنويا إحصاء إقتصادي للطلب وتحليل المعطيات وتقديم توصيات للحكومة، فالمصلحة المتعاقدة تعد بطاقة إحصائية و ترسلها إلى المرصد المذكور.

في المرسوم الجديد، تنص المادة (214) على أنه لتمكين سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام من القيام بالإحصاء الإقتصادي، تعد المصلحة المتعاقدة بطاقات إحصائية و ترسلها إليها، وعلى هذا الأساس تقوم بإجراء إحصاء إقتصادي للطلب العمومي سنويا وكذا تحليل المعطيات المتعلقة بالجانبين الإقتصادي والتقني للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة، كما تقوم بتشكيل مكان للتشاور في إطار مرصد الطلب العمومي.

8- أحكام جزائية:

- دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو إمتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لإتخاذ أي تدبير ردعي، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني و تسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الإقتصاديين ممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية حسب المادة (89).

- عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في إبرام أو تنفيذ أو مراقبة صفقة عمومية مع المصلحة العامة و يكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته

لمهامه بشكل حاد، يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك ويتتحي عن هذه المهمة حسب المادة (90).

- تتنافى العضوية في لجنة التحكيم والعضوية أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، عندما يتعلق الأمر بنفس الملف حسب المادة (91).

- لا يمكن للمصلحة المتعاقدة و لمدة أربع (04) سنوات أن تمنح صفقة عمومية بأي شكل من الأشكال لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما حسب المادة (92).

- لا يمكن للمتعاقل الإقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية، و في حالة ظهور هذه الوضعية فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة بذلك حسب المادة (93).

- لا يمكن صاحب صفقة عمومية أطلع على بعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه إمتيازاً عند المشاركة في صفقة عمومية أخرى، المشاركة فيها إلا إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة، و في هذه الحالة يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بين المرشحين حسب المادة (94).

وفي الختام، فإن التعديلات الدورية التي أدخلت على قانون الصفقات العمومية فرضتها متطلبات الحركة التنموية النشيطة التي تعرفها البلاد على الساحة الإقتصادية والتي تتأثر بدورها بالمحيط الإقتصادي العالمي والإقليمي والجهوي، مما يستدعي حماية الإقتصاد الوطني في ظل إحترام الشفافية و المساواة و تطبيق مبدأ الأفضلية و ترقية الإنتاج الوطني بين كل المتعاملين الإقتصاديين، هذا ما كان ينقص في النصوص السابقة، غير أن النصوص لا تكفي و تبقى محدودة الفعالية إذا لم تتبعه في أقرب الآجال إصدار نصوص تطبيقية في المواضيع التي أشار إليها المرسوم هذا من جهة، و من جهة أخرى، على المؤسسات الوطنية أن ترفع من قدراتها التنافسية حتى تفرض وجودها أمام المؤسسات الأجنبية العملاقة التي لاتحد من فعاليتها حواجز الحدود الجغرافية في ظل التطورات التكنولوجية المتواصلة.

ميزانية الدولة

مقدمة:

إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة، فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه من أين و كيف يحصل، أين و كيف ينفق بمعنى آخر الإيرادات والنفقات والتي تقدر وتجاز بالميزانية، فتطور المجتمع إقتصاديا واجتماعيا مرتكز على مدى فعالية السياسات الإقتصادية ومنها السياسات المالية.

أولا: مفهوم الميزانية العامة

1- التعريف الميزانية Le budget :

هي تقدير وتوقع وإجازة للنفقات العامة والإيرادات العامة لمدة مقبلة غالبا ما تكون سنة.

ثانيا: عناصر الميزانية العامة :

تقوم الميزانية العامة على ثلاثة عناصر هي:

1- الميزانية العامة هي تقدير أرقام مبالغ كل من النفقات والإيرادات العامة للسنة المقبلة، بمعنى آخر هي بيان مفصل لجميع النفقات العامة وما يقابله من إيرادات لتغطيتها و هي تستند إلى عنصر التوقع «prévision».

2- الميزانية العامة هي وثيقة مالية تعدها السلطة التنفيذية (وزارة المالية) و تجيزها أو تصادق عليها السلطة التشريعية بموجب قانون.

2- الميزانية العامة تعد -عادة- لتنفيذها خلال السنة المقبلة، و هو ما يميزها عن الحساب الختامي «Compte final»، المتعلق بالسنة المنصرمة.

ثالثا: الطبيعة القانونية للميزانية العامة:

- الميزانية العامة هي وثيقة مالية رسمية، تضاربت بشأنها الآراء في تحديد طبيعتها القانونية هل هي عمل تشريعي، أو عمل إداري، نظرا للدور الذي تلعبه الإدارة العامة في إعداد و تنفيذ و تجسيد و تطبيق بنودها، إجابة على ذلك ظهرت ثلاثة آراء فقهية:

- الرأي الأول: الميزانية هي قانون أي عمل تشريعي، كباقي القوانين الصادرة عن البرلمان طبقا لأحكام الدستور و وفقا للنظام الداخلي للبرلمان بغرفتيه، فهي قانون من الناحية الشكلية و الموضوعية.

- **الرأي الثاني:** الميزانية العامة، هي عمل إداري لأنها مجرد تخمينات للنفقات والإيرادات المستقبلية إذ لا تحتوي على قواعد عامة و مجردة، و ما موافقة البرلمان إلا لإعطاء الموظف المالي صلاحية ممارسة عمله.

- **الرأي الثالث:** الميزانية العامة، عمل مختلط (قانوني و إداري)، حيث يرى الفقيه Duguitt بأن أحكام الإيرادات العامة (خاصة الضرائب) هي عمل قانوني تشريعي، أما ما تعلق منها بالنفقات فهو عمل إداري.

رابعاً: مبادئ و قواعد الميزانية العامة:

- تخضع الميزانية العامة إلى أربعة مبادئ أساسية من شأنها تدعيم الرقابة في تسيير الأموال العمومية، وهي:

1- مبدأ السنوية **principe de l'annualité budgétaire**:

- تعني الحياة المالية للدولة (أي مدة سنة)، وهي تمكن البرلمان من مراقبة الحكومة في إطار إحترام قاعدة السنوية، و يلاحظ أن فترة التنفيذ المالي للميزانية بفرنسا تبدأ مع بداية العام الميلادي (أول جانفي) ونفس الأمر في ألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج.....الخ، و في الجزائر، تنص المادة (03) من القانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المعدل و المتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984 و المتعلق بالقوانين المالية على ما يلي:

" يقر ويرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات بالرأسمال. "، وهو المبدأ الساري أيضا على ميزانيات الإدارة المحلية.

ومبدأ سنوية الميزانية ليس مطلقا، حيث ترد عليه بعض الإستثناءات، ففي حالة عدم التمكن من المصادقة على الميزانية قبل بداية السنة المالية، إذ يترخص للإدارة العامة بفتح إعتمادات شهرية مؤقتة على حساب الميزانية المقبلة.

كما يعتبر إستثناء من مبدأ السنوية الميزانيات المخصصة للبرامج والمخططات الإقتصادية و الإجتماعية التي يستغرق تنفيذها في الميدان عدة سنوات.

2- مبدأ الوحدة principe d'unité :

- نادى بهذا المبدأ الفقيه " ساي " (Say) حيث قال:
" أنه من الضروري حصر الميزانية ضمن بنود تسمح من خلالها التعرف على أهم ملامح الميزانية ".

و مبدأ وحدة الميزانية يعني وضع بنود الإيرادات و النفقات في خطة واحدة.
- و القاعدة العامة، أن يتم تسجيل النفقات في ميزانيات خاصة متوازنة و تمويلها بطرق خاصة، كفرض الضرائب الإضافية أو لإحداث تغييرات نقدية.
- من الاستثناءات الواردة على قاعدة وحدة الميزانية، يمكن الإشارة إلى وجود ميزانيات أخرى إلى جانب الميزانية العامة، و هي:

* الميزانيات غير العادية، الميزانيات الملحقه حسب المادة (44) من القانون 84-17
17، الميزانيات المستقلة، الحسابات الخاصة على الخزينة حسب المواد من (48 إلى 61)
من القانون 84-17.

* في الجزائر، فإن لهيئات الإدارة المحلية مثلا (البلديات، الولايات) ميزانياتها نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية، كما أن المادة (44) من القانون رقم 84-17 تسمح بإنشاء ميزانيات ملحقه حينما نصت على ما يلي:

" يجوز أن تكون موضوع ميزانيات ملحقه، العمليات المالية لمصالح الدولة التي لم يصف عليها القانون الشخصية الاعتبارية و التي يهدف نشاطها أساسا إلى إنتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدمات المدفوعة الثمن.

- يقرر إنشاء أو إلغاء ميزانيات ملحقه بموجب قوانين المالية".

3- مبدأ العمومية (الشمولية) principe d'universalité :

- ويعني أن تتضمن الميزانية قسمين: أولهما خاص بالإيرادات والثاني بالنفقات دون الربط، بحيث يظهر كل قسم مستقلا عن الآخر.

وهذه الطريقة توضح نتيجة نشاط الدولة، مما يسهل مهمة البرلمان في الرقابة على بنود الميزانية ورقابة داخلية في مرحلة تنفيذ الميزانية.

4- مبدأ التوازن : principe d'équilibre

- يقصد بمبدأ توازن الميزانية، أن تتساوى مجموع الإيرادات العامة مع مجموع النفقات العامة.

وتأسيسا على ذلك، فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة، فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية.

و في هذا الإتجاه، ذهبت المادة (139) من القانون 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، حينما نصت على ما يلي:

"لا يقبل إقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".

وهو ما تؤكدته المادة (161) من قانون الولاية بنصها على ما يلي:

"يصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا"، لكن العلماء والفقهاء المحدثون في المالية العامة يرون عدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية، ويرون أن الدولة تكيف الحالة الإقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في ميزانيتها، وفق ما يعرف بالعجز المنظم – **Déficit Systématique**

وفي هذا معالجة لهزات الدورة الإقتصادية بالنسبة للدول الرأسمالية، كما أن الدول التي هي في طريق التنمية لا سبيل لها في تنفيذ مشروعاتها إلا عن طريق زيادة نفقاتها الإستثمارية.

سادسا: تحضير الميزانية العامة:

يمر تحضير الميزانية العامة بمرحلتين هما، مرحلة الإعداد ومرحلة الإعتماد:

1- إعداد الميزانية:

- الإتجاه السائد في مختلف الأنظمة، أن إعداد الميزانية و التحضير الأولي لها يتم بمعرفة السلطة التنفيذية (الإدارة العامة)، نظرا لما تتمتع بها من إمكانيات ووسائل تسمح لها بذلك.

- في الجزائر تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحضير مشروع قانون المالية حيث يتمتع وزير المالية بصلاحيات واسعة، وهو يعتمد على جملة من المعطيات والتوجيهات تتمثل فيما يلي:

أ- توجيهات المخطط السنوي Plan annuel:

يستند هذا المخطط على الأهداف العامة المراد إنجازها في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية كما هي واردة في قانون كل مخطط سنوي.

ب- توقعات مختلف القطاعات:

تقوم مختلف الوزارات والقطاعات بإقتراح توقعات سواء بالنسبة للنفقات أو الإيرادات الخاصة بها المبنية على الممارسات خلال ميزانية السنة ما قبل الأخيرة.

2- اعتماد الميزانية :

بعد إعدادده من طرف السلطة التنفيذية (وزارة المالية)، يتم إيداع مشروع قانون المالية لدى السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني)، بغرض إعماله تطبيقا لقاعدة: "أسبقية الإعمال على التنفيذ"، و ذلك حسب المراحل الأساسية التالية:

أ- المناقشة Discussion:

- بعد إيداع مشروع قانون المالية مرفقا بجميع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يقوم هذا الأخير، طبقا للقانون، وللقوانين والأنظمة الداخلية للمجلس بإحالة إلى اللجنة البرلمانية المختصة بقطاع المالية والميزانية والتخطيط.

- تقوم لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بدراسة و مناقشة مشروع القانون مع ممثل الحكومة (وزير المالية)، وتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي تضمنه ملاحظاتها و إقتراحاتها مع مراعاة أحكام المادة (02/138) من القانون 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري.

يتم عرض التقرير التمهيدي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في جلسة عامة تكون مناسبة لجميع النواب لطرح القضايا و المشاكل المتعلقة بالسياسة المالية ومدى الإلتزام بتنفيذ قانون المالية الساري المفعول من طرف مختلف القطاعات والوزارات.

ب- التعديل Amendment:

- تختلف سلطة البرلمان في تعديل قانون الميزانية من بلد لآخر .
- يمكن للنواب والحكومة و أعضاء اللجنة التقدم بإقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة و مناقشتها مع الوزير المعني، شريطة التقيد بأحكام المادة (139) من القانون 01-16 المتضمن التعديل الدستوري التي تنص على ما يلي:
- " لا يقبل إقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقاً بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها. "

ويمكن للحكومة الاعتراض على التعديلات المقدمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل سياسية و دستورية.

ج- التصويت Vote:

- تخول المادة (11/140) من القانون 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري للمجلس الشعبي الوطني حق "التصويت على ميزانية الدولة " .
- كما يقوم مجلس الأمة- لاحقا - بمناقشة والمصادقة على قانون الميزانية بابا بابا فإن المادة (70) من القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية، تشير إلى التصويت على الميزانية العامة بصفة إجمالية Globalement، خلافا لميزانيات الإدارة المحلية التي يصوت عليها، بابا بابا و فصلا فصلا و مادة مادة.
- والقاعدة أن يصوت ويصادق البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المالية الجديدة إحتراما لمبدأ السنوية Annualité.

كما أن الدستور قد قيد البرلمان من حيث الإختصاص الزمني في المصادقة على قانون المالية، حينما نص في الفقرتين التاسعة والعاشر من المادة (138 فقرة 01 ، 08 و 09) من القانون 01-16 على ما يلي:

- " يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة. وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر. "

3- تنفيذ الميزانية العامة:

- بعد المصادقة على ميزانية الدولة من طرف السلطة التشريعية، يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون المتعلق بالميزانية ونشره في الجريدة الرسمية، من أجل قيام الجهات و الهيئات الإدارية المختصة بتنفيذها في الميدان، أي الانتقال من مجال التقدير والتوقع للسنة المقبلة إلى مجال الواقع الملموس في وقت حاضر، سواء من حيث تحصيل الإيرادات وجبايتها أو من حيث صرف النفقات المعتمدة.

أ- تحصيل الإيرادات:

- يخول القانون المتعلق بالميزانية للجهات الإدارية المختصة تحصيل الإيرادات كأن تتولى وزارة العدل حيازة الرسوم القضائية، أو مصالح إدارة الجمارك بتحصيل الرسوم الجمركية أو تحصيل إدارة الضرائب عبر مختلف فروعها لمختلف الضرائب و الرسوم.

ب- صرف النفقات:

- إذا كانت مبالغ الإيرادات تبقى مبالغ محتملة ومتوقعة، فإن قانون الميزانية ينص على الحد الأقصى للمبالغ المصرح بإنفاقها لكل غرض، حيث لا يجوز للإدارة تجاوز الإعتمادات crédits المقررة، تطبيقا للمادة (75) من القانون 84-17 التي نصت على ما يلي:

" لا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الإعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، ما لم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك. "

- تحكم صرف النفقات العامة قاعدة " تخصيص الإعتمادات"، التي تعني أن توزع النفقات على مختلف الوزارات، وبالنسبة لمختلف الأبواب في صورة إعتمادات معينة و محددة لكل منها، عملا بمبدأ التخصيص، السالف الذكر.

كما يقصد بهذه القاعدة أيضا عدم رصد مبلغ إجمالي للنفقات تتصرف فيه الإدارة كما تشاء، مما يترتب عنه عدم تحويل إعتماد من باب أو مجال إلى آخر، على أن القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية يتضمن المرونة تتعلق بنقل الإعتمادات transfert des crédits و تحويلها، virement des crédits.

- الأمر بالصرف: Ordonnancement المادة (21)

بعد معرفة مبلغ النفقة تحديداً، يقوم الشخص المختص (الوزير، المدير...) بإصدار الأمر إلى المحاسب comptable بدفع ذلك المبلغ إلى شخص معين بموجب وثيقة مكتوبة تسمى الأمر بالصرف: **ordonnancement de paiement** أو **mandat de paiement**

– التمييز بين الأمر بالصرف الرئيسي و الثانوي:

الأمرون بالصرف الرئيسيون هم أساساً، مسؤولو الهيئات الوطنية، الوزراء، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية و كل مسؤول عن هيئة أو مرافق أخرى تتمتع بميزانية ملحقة.

أما الأمرون بالصرف الثانويين، فهم رؤساء المصالح الإدارية الأخرى، حينما يخول لهم التشريع ذلك.

–الصرف: Paiement: المادة (22)

يقصد بهذا الإجراء الدفع الفعلي للمبلغ المستحق لصاحبه عن طريق المحاسب comptable، بعد التأكد من المستندات، و المحاسبون هم موظفون موجودون بالإدارات العامة إلا أنهم لا يخضعون للسلطة الرئاسية للأمريين بالصرف بها، حتى يمكنهم مراقبة عمليات صرف النفقة، من حيث مطابقتها للقانون.

وإذا كانت المراحل السابقة توصف بأنها مراحل إدارية، فعملية الصرف هي المرحلة الحسابية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين الأمريين بالصرف و المحاسبين.

4- مراقبة الميزانية العامة:

يخضع تنفيذ الميزانية لأنواع متعددة من الرقابة حفاظاً على الأموال العامة و حسن إستعمالها بعيداً عن التبذير، التبديد و الإختلاس.

ولعل أهم صور الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة، يتمثل في الرقابة الإدارية ورقابة البرلمان و رقابة مجلس المحاسبة.

أ- الرقابة الإدارية: Contrôle administratif

هي تلك الرقابة التي تمارسها هيئات الإدارة العامة على بعضها البعض، فهي إذن رقابة تتم داخل السلطة التنفيذية، مما يجعلها داخلية و ذاتية، كما تكون سابقة أو لاحقة.

وعلى كل، فإن أهم صور الرقابة الإدارية عموما وفي مجال المالية العامة خصوصا يمكن أن تأخذ الأشكال التالية:

- الرقابة التلقائية (الذاتية) : Autocontrôle

حيث تقام آليات و قواعد داخل هيكل إداري معين من أجل البحث واكتشاف مواقع الخلل وإصلاحها في الوقت المناسب، مثل سجل الإقتراحات، التقييم الدوري والاجتماعات المنتظمة للهيئة الإدارية...الخ.

- الرقابة الرئاسية: Contrôle hiérarchique

- حيث تخول القوانين والأنظمة للرئيس الإداري (Supérieur) حق التدخل للتعقيب على أعمال مرؤوسيه (Subordonnés) من أجل المصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم أو طعن رئاسي Recours hiérarchique.

- الرقابة الوصائية: Tutelle

بالرغم من الإستقلال القانوني لبعض الهيئات الإدارية داخل السلطة التنفيذية بموجب إكتسابها للشخصية المعنوية (بلدية، ولاية، جامعة...الخ)، إلا أن ذلك الإستقلال ليس مطلقا ولا تاما، حيث تبقى تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة و الإشراف من طرف السلطة الوصية، مثل وصاية الوالي على أعمال البلدية، إذ تنص المادة (203) من القانون رقم 10/11 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 يتعلق بالبلدية على ما يلي:

" يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي الحوالات و يصدر سندات التحصيل. في حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بإعداد حوالة قصد تغطية نفقة إجبارية أو إصدار سند تحصيل، يتخذ الوالي قرارا يحل محل حوالة أو سند تحصيل رئيس المجلس البلدي طبقا للتشريع الساري المفعول. "

لعل أهم مظهر للرقابة الإدارية، هو الرقابة المالية le contrôle financier التي تمارسها وزارة المالية و مصالحها المختلفة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي بواسطة المفتشية العامة للمالية "I.G.F" أو المراقبين الماليين les contrôleurs financiers.

ب- رقابة البرلمان *contrôle législatif*

يتمتع البرلمان، زيادة على سلطته في وضع وسن القوانين، بإختصاص لا يقل أهمية ألا وهو مراقبة الإدارة العامة (الحكومة)، من حيث مدى إلتزامها بتطبيق برنامج الحكومة الذي كان قد وافق عليه من قبل.

- تمس الرقابة البرلمانية (أو التشريعية) مختلف أنشطة الحكومة ومجالات تدخلها ومنها المجال المالي، إضافة إلى الإختصاص بالمصادقة على قانون المالية وإعتماده (رقابة قبلية)، فإن مراقبته تمتد أيضا أثناء تنفيذ الميزانية (رقابة آنية)، بل و حتى نهاية السنة المالية (رقابة بعدية)، هي كالاتي:

- الرقابة أثناء تنفيذ الميزانية (الآنية):

يمكن البرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، أن يراقب النشاط والأداء الحكومي (الوزارات) في مختلف المجالات ومنها المجال المالي، بواسطة الآليات الأساسية التالية:

* الإستماع و الإستجواب:

طبقا للمادة (151) من القانون 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، يمكن للجان البرلمان بغرفتيه أو مجلسيه أن تستمع إلى أعضاء الحكومة في إحدى قضايا الساعة، كما يمكن لأعضاء أي مجلس إستجواب الحكومة.

* السؤال:

يمكن لأعضاء البرلمان، وفقا للمادة (152) من القانون رقم 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، أن يسألوا أي وزير كتابيا أو شفويا عن أي موضوع أو قضية، ومنها القضايا المتعلقة بتنفيذ الميزانية، طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان.

* مناقشة بيان السياسة العامة:

طبقا للمادة (98) من القانون 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016، تلتزم الحكومة بأن تقدم كل سنة، بيانا عن السياسة العامة، تعقبه مناقشة لعمل و أداء الحكومة، لمعرفة مدى تنفيذ برنامج الحكومة الذي كان البرلمان قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينها.

* لجنة التحقيق: commission d'enquête

- بموجب المادة (180) من القانون 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016، يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار إختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

وضمامنا لفعالية هذه الوسيلة في مراقبة عمل الإدارة العامة (الحكومة)، يحدد القانون والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، كيفية تشكيل هذه اللجان وإجراءات و وسائل أداء مهمتها في التحقيق والحماية المبسوطية على أعضائها والجزاءات المترتبة على نتائج التحقيق...الخ. كما تتجلى رقابة البرلمان، في مرحلة تنفيذ الميزانية، بصورة واضحة لدى مناقشة قانون المالية التكميلي الذي تقدمه الحكومة للبرلمان أثناء السنة المالية بغرض تكميلته أو تعديل بعض الأوضاع المستجدة.

- الرقابة اللاحقة (البعدية):

- قانون ضبط الميزانية العامة:

- تنص المادة (179) من القانون 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري على ما يلي:

" تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الإعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.

تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعينة من قبل كل غرفة من البرلمان".

في نفس السياق نصت المادة (05) من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية على ما يلي:

" يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية"، كما يلزم القانون الحكومة بتقديم البيانات و الوثائق التي تسمح للبرلمان بالقيام بالمراقبة.

ج- رقابة مجلس المحاسبة **contrôle de la cour des comptes**:

- قد تتم الرقابة على تنفيذ الميزانية عن طريق هيئة مستقلة تسمى مجلس المحاسبة **la cour des comptes** الذي صدر بموجب القانون 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بمجلس المحاسبة، الذي ألغي بموجب الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المعدل و المتمم بالأمر 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بمجلس المحاسبة.

- إختصاص مجلس المحاسبة:

يقوم إختصاص مجلس المحاسبة على معيار عضوي وآخر موضوعي، حيث نصت المادة (192) من الدستور على ما يلي:

" يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.

يعد مجلس المحاسبة تقريراً سنوياً يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.

يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علاقاته بالهيكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة و التفتيش. "

* من الناحية العضوية (الشكلية): المواد من (07 إلى 10) من الأمر 95-20.

- المادة (07):

" تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية بإختلاف أنواعها، التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية. "

- المادة (08):

" تخضع أيضاً لرقابة مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات والهيئات العمومية

التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها، كلها ذات طبيعة عمومية. "

- المادة (09):

"يوهل مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر بمراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى، جزءا من رأس مالها. "

- المادة (10):

"تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، الهيئات التي تقوم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بتسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعيين. "

* أما من الناحية الموضوعية: تمس مراقبة مجلس المحاسبة- في المجال القضائي- تقييم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، بما يترتب عن المعايينات من جزاءات قضائية (الغرامة)، كما تشير إلى ذلك الفقرة الثانية من المادة (06) منه.

- الإجراءات:

لإجراء التحريات والتدقيقات والمراجعات، يعين رئيس الغرفة مقرا لهذا الغرض يقوم رئيس الغرفة بإرسال التقرير إلى الناظر العام لتقديم إستنتاجاته، ثم يعرض الملف بكامله على التشكيلة المداولة للبت فيه، إما بقرار نهائي Arrêt définitif في حالة عدم إثبات وجود أية مخالفة، أو بقرار مؤقت Arrêt provisoire في الحالة العكسية.

- يبلغ القرار المؤقت إلى المحاسب للرد عليه خلال شهر، و بعد تقديم الناظر العام لإستنتاجاته الكتابية، و بعد المداولة، تبت التشكيلة المختصة (الغرفة)، في الملف بقرار نهائي بأغلبية الأصوات، مما يجعله خاضعا لفكرة القرار المزدوج Double arrêt.

يتمتع القرار النهائي بالصيغة التنفيذية، كما هو الشأن بالنسبة لقرارات الجهات القضائية الإدارية، كما يمنح مجلس المحاسبة بقراره النهائي الإبراء (quitus) إلى المحاسب الذي لم يتم تسجيل أية مخالفة على مسؤوليته، أو يجعله في حالة مدين إذا كان الأمر خلاف ذلك.

الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة

مقدمة:

لقد كان القانون الجبائي من أولى الصلاحيات السيادية للدولة، و مع تطور دور الدولة التي أخذت في التدخل أكثر فأكثر في تسيير النفقات العمومية، تمكنت الجباية من الإستحواذ على مكانة متميزة في تمويل نفقاتها من خلال الضريبة، فالمالية العامة تقوم بتحليل القواعد المنظمة لإعداد و تنفيذ الميزانية العامة للدولة من نفقات عامة وإيرادات عامة ولواحقتها، إن دراسة الإيرادات العامة تقتضي التطرق إلى أنواعها ومصادرها الرئيسية.

أولاً: الضرائب: les Impôts

1- تعريف:

تعرف الضريبة بأنها إقتطاع مالي، تأخذه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل بهدف تحقيق مصلحة عامة.

- إقتطاع مالي **prestation pécuniaire**، يعني ذلك، أن قيمتها تنتقل إنتقالا نهائيا من المكلف بها إلى الدولة.

2- الأساس القانوني للضريبة:

- في تحديده لأساس الضريبة وتكييفها القانوني، ذهب الفقه المالي في إتجاهين:

أ- نظرية العقد المالي:

يعتقد كثير من كتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أن الفرد يدفع الضريبة مقابل المنفعة التي تعود عليه من خدمات المرافق العامة، فهو يرتبط مع الدولة بعقد ضمني ذي طبيعة مالية يلزمه كمشتري بدفع ثمن هذه الخدمات في صورة ضرائب، إلا أنه يعاب على هذا التكييف صعوبة تحديد المنفعة التي تعود على كل دافع ضريبة خاصة بالنسبة لمنافع الخدمات العامة غير القابلة للإنقسام، حيث يختلف أصحاب هذا الإتجاه في تحديد نوع هذا العقد، كونه عقد إيجار أعمال (توريد خدمات) أو عقد تأمين أو عقد شركة إنتاج.

ب- نظرية التضامن الإجتماعي: يتجه الفكر المالي الحديث إلى تفسير أساس الضريبة بنظرية سيادة الدولة والتضامن الإجتماعي بعدما فشلت النظريات التعاقدية في تبريره، وتقوم

هذه النظرية، على اعتبار قيام و وجود الدولة ضرورة إجتماعية، وليست وليدة عقد إجتماعي أو نظام.

ومن تم، لا يمكن قيام الضريبة على أساس العقد المالي، حيث تقوم الدولة بتقديم كثير من الخدمات والمنافع العامة، تقتضي نفقات عامة لاغنى عنها لإستمرار الجماعة وإنتظامها، و الأفراد كونهم أعضاء في تلك الجماعة، ملزمون بالتضامن فيما بينهم بتحمل هذه النفقات.

وهكذا، فإن التضامن الواجب بين أعضاء الجماعة السياسية الواحدة التي تمثلها الدولة، هو الأساس القانوني الذي تستمد منه الدولة سلطتها في فرض الضرائب، والذي يرجع إليه الإلتزام بدفعها.

تتميز هذه النظرية، بأنها تتجنب فكرة المقابلة بين مقدار الضريبة ومقدار ما يحصل عليه من منافع وخدمات.

كما تفسر قيام الأجيال الحاضرة بخدمة القروض التي عقدتها أجيال سابقة بواسطة الضرائب، نتيجة لمبدأ التضامن الإجتماعي بين الأجيال الحاضرة والسابقة.

يتبين مما سبق، أن الدولة ليست تنظيماً تعاقدياً، ولكنها ضرورة تاريخية و إجتماعية ومن تم يتعين أن نجد أساس آخر للضريبة غير الأساس السابق الذي يقوم على فكرة التعاقد.

من البديهي، أن الدولة وهي تحقق التضامن تحتاج إلى إيرادات، لذلك تلجأ إلى فرض الضرائب على أفراد الجماعة بما لها من سيادة عليهم وتحقيقاً للتضامن الإجتماعي فالضريبة لاتعدو أن تشكل طريقة لتوزيع الأعباء العامة التي إقتضاها مبدأ التضامن الإجتماعي بين أفراد الجماعة.

يترتب على ذلك عدة نتائج هي:

- أن الضريبة فكرة سيادية، أي للدولة سلطة تحديدها وسلطة تنظيمها الفني.
- أن تفرض الضرائب على جميع أفراد الجماعة بصفتهم ملتزمين بواجب التضامن الإجتماعي، وهو مايعني " عمومية الضريبة".

- أن يكون تحديد العبء الذي يدفعه كل ممول من الضريبة ليس بقدر ما يعود عليه من نفع، ولكن وفقا لقدرته في تحمل أعباء الجماعة، وهو ما يعرف "بالقدرة التكليفية" للممول، كما أوردها " آدم سميث" في كتابه (ثروة الأمم).

3- القواعد الأساسية للضريبة:

- لقد وضع "آدم سميث" وعلماء المالية العامة مجموعة من المبادئ والقواعد هي:

أ- قاعدة العدالة (المساواة): *la règle de justice*

معناها، أن يساهم ويشارك جميع أفراد المجتمع في أداء الضريبة، حيث تستند القاعدة في الفكر المالي التقليدي على تحمل الممول عبء الضريبة تبعا لمقدرته النسبية (الضريبة النسبية)، أما الفكر المالي الحديث، فيقيمها على أساس القدرة التكليفية (الضريبة التصاعدية).

ب- قاعدة اليقين: *la règle de certitude*

يقصد بها، أن تكون الضريبة واضحة المعالم من مختلف الجوانب، القيمة الوعاء ميعاد الدفع، الجهة الإدارية المختصة بالتحصيل وطرق الطعن الإداري والقضائي يؤدي إحترام هذه القاعدة، وضوح التزامات الممول تجاه الخزينة العامة من جهة، وقيام الجهة الإدارية المختصة بالتقيد بالقانون و عدم التعسف في استعمال السلطة، من جهة أخرى.

ج- قاعدة الملائمة في الدفع: *la règle de commodité*

هدف إلى إقامة نظام جبائي، يستند إلى إقامة علاقة تنافرية بين الدولة ودافع الضريبة، وذلك من خلال تحديد ميعاد الدفع بما يتلاءم ويتناسب مع القدرة المالية للمكلف كأن تكون مباشرة بعد جني المحصول، أو عند المصدر بالنسبة للضريبة على الدخل، أو اعتماد نظام التقسيط في الدفع... الخ.

د- قاعدة الإقتصاد: *la règle d'économie*

يقصد بها، أن ما يصرف من نفقات وتكاليف من أجل تحصيل الضريبة، يجب أن تكون ضئيلة ومتدنية إلى أقصى حد ممكن، وهكذا فإن إقامة أجهزة إدارية ضخمة و توظيف عدد كبير من الموظفين في قطاع الجباية مخالف لقاعدة الإقتصاد، إذ لاخير في ضريبة تكلف جزءا كبيرا من حصيلتها.

4- تنظيم الضريبة:

إن دراسة عنصر تنظيم الضريبة، يستدعي التعرض للمواضيع الأساسية التالية، وعاء الضريبة، ازدواج الضريبة والمنازعات الضريبية.

4-1- وعاء الضريبة (أنواع الضرائب): assiette de l'impôt

يقصد بوعاء الضريبة، المادة التي تفرض وتقوم عليها الضريبة، مما يقتضي تقسيم وتصنيف الضرائب على أساسه إلى عدة أنواع، يمكن إجمالها في ما يلي:

أ- الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال :

- الضريبة على الأشخاص تفرض على الأفراد إعتبارا لوجودهم في الدولة وتحت حمايتها، وقد عرفت قديما بضريبة "الرؤوس" في جل الدول القديمة (فرنسا، روسيا القيصرية....)، ويذهب البعض إلى الإشارة هنا إلى "الجزية" التي عرفت في الدول الإسلامية المفروضة على أهل الذمة، وإن كانت أسسها ومبرراتها مغايرة لنظام الضريبة.

- تفرض الضريبة على الأموال، أي على الأشياء والممتلكات التي يحوزها الأشخاص، سواء كانت أموالا عقارية أو منقولة.

ب- الضريبة الواحدة والضريبة المتعددة:

* الضريبة الواحدة:

بمقتضاها، لا تفرض إلا ضريبة واحدة على الشخص، وهي تتسم بالبساطة، العدالة، سهولة أدائها وإقتطاعها.

* الضريبة المتعددة:

هي أن تفرض عدة ضرائب على الشخص، تنتوع بتنوع موارده وممتلكاته ونشاطه وهي محل إنتقادات.

ج- معايير التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة :

يمكن الإشارة إلى المعايير الأساسية التالية :

- المعيار الإداري: حيث تحدد طبيعة الضريبة بالإستناد على موقف الجهة الإدارية التي تقوم بتحصيل الضريبة أو طريقة تحصيل ذلك، و الأمر يختلف بطبيعة الحال من دولة لأخرى، لأن النظام الضريبي بها هو الذي يحدد طبيعة الضريبة.

- رجعية الضريبة:

المقصود بهذا المعيار هو معرفة وتحديد الشخص الذي يقع عليه عبئ الضريبة نهائياً، إذ أنه تفرض الضريبة على شخص يتمكن من تحويل و نقل عبئها إلى شخص آخر.

د- ثبات موضوع الضريبة:

تعتبر الضريبة مباشرة، إذا كانت منصبة ومفروضة على موضوع أو مادة تتميز بالثبات والاستمرار (ملكية عقار، ممارسة مهنة...الخ)، أما الضرائب غير المباشرة فإنها تتعلق بوقائع متقطعة وعارضة.

- الضرائب المباشرة تقتضي إتحاد الصفتين في الشخص الممول لها، الإلتزام القانوني والتسديد الفعلي.

هـ- تقدير الضرائب المباشرة وغير المباشرة:**- الضرائب المباشرة:***** المزايا:**

- ثابتة، مستقرة ومنتظمة نسبياً،
- واضحة المعالم،
- تحقق قاعدة الملاءمة،
- تحقق العدالة.

*** العيوب:**

- أقل مرونة من الضرائب غير المباشرة، حيث لا تتأثر بالانتعاش الإقتصادي أو الركود الإقتصادي،

- لا تتصف بصفة العمومية، مما يترتب عنه انخفاض حصيلتها،

- نظراً لأن الممول يدفعها - عادة - سنوياً، فهي قد تكون مرهقة له، مما يفتح المجال للتهرب الضريبي.

- الضرائب غير المباشرة:*** المزايا:**

- سهولة دفعها من طرف الشخص، لأنها تختفي في سعر السلعة،

- على خلاف الضريبة المباشرة، فإن الضريبة غير المباشرة تتسم بالمرونة، فميزتها أن حصيلتها تؤدي إلى الانتعاش الإقتصادي.

* العيوب:

- ضالة وقلة حصيلتها في وقت الركود الإقتصادي.
- مكلفة من حيث مراقبتها وتحصيلها، خاصة بالنسبة للضريبة على الإنتاج مثلا.
- عدم التناسب مع القدرة التكليفية للممول، فهي عادة ما تفرض على السلع الضرورية ولهذا تكون أكثر ثقلا على الطبقة الفقيرة.

ي- الضريبة على رأس المال والضريبة على الدخل والضريبة على الإنفاق:

يستند في هذا التقسيم على مدى إستمرارية وعاء الضريبة.

* الضريبة على رأس المال:

يقصد بالرأسمال «**capital**» من الناحية القانونية، ما يملكه الشخص من أموال وقيم في زمن ما، بغض النظر عن طبيعتها، كالعقارات، المنقولات، أدوات الإنتاج، الأسهم والمستندات.... الخ، و لتحديد رأس المال من الناحية الضريبية، يجب حصر وجرد وتقييم أصول وخصوم المكلّف بالضريبة، وعليه فإن رأسمال المكلّف هو عبارة عن الزيادة في قيمة الأصول على قيمة الخصوم، ومن أهم أشكال وصور الضريبة على رأس المال، يمكن ذكر:

- الضريبة على عملية و واقعة إمتلاك رأس المال: *prélèvement sur le*

capital

- الضريبة على زيادة قيمة رأس المال: *impôt sur le plus value* تفرض

لأسباب خارجة عن صاحبها، وإنها ترجع إلى ظروف أخرى " الأشغال العامة ".

- الضريبة على التركات: *impôt sur les successions* تقوم على إنتقال رأس

المال المتوفى إلى ورثته أو الموصى لهم، هناك نوعان لضريبة التركات ، وهما :

- الضريبة على مجموعة التركة: تفرض على مجموع التركة الصافي، أي بعد

خصم ديونها، حيث لا تركة إلا بعد تسديد الديون، ولهذا تكون أوفر حصيلة من النوع الثاني.

- الضريبة على نصيب الوارث (أو الموصى له): حيث تفرض على نصيب كل واحد من الورثة أو الموصى لهم.

* الضريبة على الدخل: **impôt sur le revenu**

- يقصد بالدخل، بمعناه الواسع، كل زيادة في القيمة الإيجابية للممول، أي كل زيادة في ذمته المالية، فهو عبارة عما يحصل عليه الشخص من مصدر معين، قد يكون ملكية وسيلة إنتاج (مصنع) أو عمله ومهنته أو هما معا، آخذا بذلك العديد من الصور و الأشكال (أجور، فوائد، أرباح...الخ)، كما يقصد به، في معناه الضيق، كل ما يحصل عليه الفرد من نقود أو خدمات بصورة منتظمة ومستمرة، طبقا لنظرية المنبع " **la source**".

- يمكن تقسيم الدخل إلى:

- دخل إجمالي (**global**)، يتمثل فيما يحصل عليه الممول من إيرادات دون خصم لتكاليفها.

- دخل صاف (**net**)، الذي يتحدد بعد خصم التكاليف اللازمة للحصول على ذلك الدخل وهو أكثر دلالة على القدرة التكاليفية للممول و أكثر عدالة.

* الضريبة على الإنفاق :

- تتمثل أساسا في الضرائب غير المباشرة، وهي تفرض على مختلف مظاهر استعمال وإستخدام الدخل، وتأخذ في الواقع الصور الرئيسية التالية:

- الضريبة على التداول: تتعلق بالتصرفات القانونية التي يقوم بها الأفراد فيما يخص نقل الملكية كضرائب الطابع والتسجيل.

- الضريبة على الإنفاق أو الإستهلاك: هي من أهم الضرائب غير المباشرة حيث تفرض على الدخل عند إنفاقه في شراء السلع، أو إنتاجها (الضريبة على الإنتاج أو القيمة المضافة أو رقم الأعمال « **chiffre d'affaires** »).

- الضرائب (الرسوم) الجمركية (التعرفة الجمركية): حيث تفرض لدى إجتياز السلعة لحدود الدولة، سواء إستيرادا أو تصديرا، وعادة ما تستعمل لحماية الإنتاج الوطني.

4-2- الأزواج الضريبي:

أ- الشروط:

- يشترط لقيام حالة الإزدواج الضريبي، توافر الشروط الأساسية التالية:
- أن يكون المكلف القانوني واحداً، ولا يثير هذا الشرط صعوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعية بخلاف الحال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، ففرض ضريبة على أرباح شركات المساهمة وضريبة أخرى على ما يوزع من أرباح تلك الشركات على المساهمين، لا يؤدي إلى الإزدواج من الوجهة القانونية لإختلاف شخصية المساهمين عن الشخصية المعنوية للشركة وإن أدى إلى ذلك من الوجهة الفعلية بسبب وحدة المصالح بين الشركة والشركاء حيث يتحمل المساهمون في النهاية الضريبتين، ما أدى إلى التمييز بين الإزدواج القانوني وما يعرف بالإزدواج الفعلي أو الإقتصادي.
 - يجب أن تفرض الضريبة على نفس المادة أكثر من مرة حتى يتحقق الإزدواج فإذا فرضت الضريبة على دخل نفس الشخص أو رأسماله مرتين أو أكثر تحقق الإزدواج وإذا لم تكن المادة الخاضعة للضريبة واحدة إنتفى الإزدواج.
 - يجب أن تكون الضريبتان أو الضرائب من نوع واحد أو متشابهة و إن اختلفت التسمية و نظرا لصعوبة تحديد الضرائب المتشابهة، فإن إتفاقيات منع الإزدواج الضريبي المبرمة بين الدول، تحدد الضرائب التي تعتبر متشابهة في الدول الموقعة عليها.
 - يشترط لتحقيق الإزدواج أن يكون فرض الضريبة مرتين أو أكثر في فترة زمنية واحدة فإذا فرضت ضريبة على دخل المكلف لسنة 2016، ثم فرضت نفس الضريبة على دخله لسنة 2017، فلا يكون إزدواجا لإختلاف المدة، بل إن شرط المدة لا يعدو أن يكون تطبيقا لشرط وحدة المادة الخاضعة للضريبة في صورة أخرى لأن دخل 2016 غير دخل سنة 2017.

ب- الأشكال:

- يأخذ الإزدواج الضريبي في الواقع، الصور التالية:
- **الإزدواج الضريبي الداخلي:** يتحقق إذا ما تحققت شروطه داخل دولة واحدة و يحدث في الدولة البسيطة (الموحدة)، نتيجة ممارسة هيئات إدارية عامة متعددة لسلطاتها في فرض

الضرائب على نفس الإقليم (ولاية، بلدية) أو حينما تفرض الإدارة المركزية أو المحلية ضريبة على نفس المال، كما يحدث داخل الدولة المركبة (الإتحادية) حينما تفرض الحكومة الإتحادية والدويلات ضريبة على نفس المادة.

- الإزدواج الضريبي الدولي:

نكون أمام هذا النوع من الإزدواج أو التعدد الضريبي، حينما تفرض أكثر من دولة ضريبة على نفس المادة أو الموضوع، حيث يستند بعضها إلى جنسية المكلف وبعضها إلى فكرة المواطن وآخر على موقع ومكان المال (العقار)، وتجدر الملاحظة، أن كلا من صورتى الإزدواج الضريبي قد تكون مقصودة أو غير مقصودة.

- الإزدواج الضريبي القانوني والإزدواج الضريبي الإقتصادي:

ينتج الإزدواج الإقتصادي، عندما يتم فرض نفس الضريبة أو ضريبة مشابهة لها أكثر من مرة على ذات الشخص وفي نفس الميعاد، كخضوع أرباح الشركة والأرباح الموزعة على الشركاء لنفس الضريبة، أما الإزدواج القانوني، يحدث نتيجة لصدور قوانين الضرائب في نصوص متفرقة، حيث تكون الضريبة جديدة أو من نفس النوع.

4-3- المنازعات الضريبية:

تجسيدا لخاصية العدالة التي يجب أن تسود الضريبة، فإن القانون الجزائري المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا قوانين المالية المتعاقبة، وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بالطعن في القرارات الصادرة عن مصالح الضرائب من طرف المكلفين في حالة عدم رضاهم بها، كما تمر المنازعة الضريبية بمرحلتين مترابطتين، المرحلة الإدارية و المرحلة القضائية.

أ- المرحلة الإدارية:

سعيًا منه لإيجاد تسوية بين مصلحة الضرائب المختصة والمكلف بالضريبة، عمد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب الأمر 76-101 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976، وقوانين المالية المتعاقبة على إنشاء وإحداث هيئات إدارية للطعن أمامها في قرارات المدير الولائي للضرائب من طرف المكلفين بالضريبة عند الإقتضاء.

- التظلم لدى المدير الولائي للضرائب:

يجب على المكلف بالضريبة قبل اللجوء إلى القضاء، أن يتظلم ويطعن أمام المدير الولائي للضرائب قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية، وذلك من أجل إصلاح وإستدراك الخطأ المرتكب في وعاء الضريبة أو للاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي حسب المادة (70) من قانون الإجراءات الجبائية، ويتمتع المدير الولائي للضرائب بسلطة واسعة بهذا الصدد، حيث له أن يقوم بالتحقيق اللازم ويتخذ القرار المناسب في مدة معينة إعتباراً من تاريخ تقديم الشكوى حسب المادة (71) من قانون الإجراءات الجبائية.

-لجان الطعن:

لتقريب وجهات النظر بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية ، لجأ القانون إلى إنشاء وإحداث هيئات إدارية هي لجنة الطعن البلدية، لجنة الطعن الولائية، لجنة الطعن المركزية المحدثة -تباعاً- بموجب المواد (80،81،81 مكرر) من قانون الإجراءات الجبائية.

***التشكيل:**

تتكون هذه اللجان من ممثلين عن المجالس الشعبية المنتخبة (البلدية والولائية) وممثلين عن المكلفين بدفع الضرائب تعينهم الإدارة، حيث يقوم تشكيلها على مبدأ تمثيل المصالح.

*** الإختصاص:**

بعد أن يرد المدير الولائي للضرائب على تظلم وطعن المكلف بالضريبة يمكن لهذا الأخير، في حالة عدم رضاه، أن يرفع طعنه إلى لجنة الطعن المختصة خلال مدة معينة شريطة أن لا يكون قد رفع دعوى أمام القضاء،تجتمع اللجنة، طبقاً للتشريع الساري المفعول، وتصدر رأياً avis غير ملزم يبلغ خاصة إلى مصلحة الضرائب.

ب- المرحلة القضائية:

إذا كان قرار المدير الولائي للضرائب، غير مرض للمكلف بدفع الضريبة، فإنه يمكنه أن يلجأ إلى القضاء.

- إن الإختصاص بالمنازعات الضريبية يعود عموماً إلى القضاء الإداري، تطبيقاً للمادة (01/804) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عملاً بالمعيار العضوي الذي إعتمدته، وذلك خلال مدة محددة من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي للضرائب، أو تاريخ تبليغ قرار الإدارة بعد أخذ رأي لجنة الطعن المختصة.

تكون قرارات المحكمة الإدارية قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة طبقاً للقانون العضوي 01-98 المؤرخ في 04 صفر عام 1419 الموافق لـ 30 ماي 1998 المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله.

القروض

مقدمة:

يشكل دخل الدولة من أملاكها (الدومين العام)، الضرائب والرسوم ما يعرف بالإيرادات العادية، أما القروض والإصدارات النقدية الجديدة، فهي تشكل ما يعرف بإسم الإيرادات الإستثنائية أو غير العادية أو المؤقتة.

أولا - تعريف القرض العام:

يمكن تعريف القرض العام على أنه: " إستدانة أحد أشخاص القانون العام (الدولة الولاية، البلدية...) أموالا من الغير مع التعهد بردها إليه بفوائدها "، بمعنى آخر هو عبارة عن مبلغ نقدي تستوفيه الدولة من الغير - سواءا كان هذا الغير من البنوك، الهيئات الخاصة أو الدولية أم الدول الأخرى - وتتعهد برده ودفع الفائدة عنه وفقا لشروط معينة.

ثانيا - أنواع القروض العامة:

تنقسم القروض العامة إلى عدة أنواع تبعا للمعيار المعتمد.

1- من حيث النطاق المكاني للإصدار:

تقسم القروض العامة إلى قروض داخلية (وطنية) وخارجية (أجنبية).

أ- الداخلية (Intérieur): يكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المقيمين داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته.

ب- الخارجية (Extérieur): فيكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من خارج الدولة، رعايا أجنب، دول، منظمات وهيئات دولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي).

يختلف القرض الداخلي عن الخارجي من عدة جوانب:

- القرض الداخلي لا يزيد عمليا في الثروة القومية، خلافا للقرض الخارجي،
- يضيف القرض الخارجي رصيدا من الثروة بالعملة الأجنبية، عكس القرض الوطني،

- يؤدي القرض الخارجي إلى تدخل الجهة المقرضة (دولة، صندوق نقد دولي) إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المقرضة،
- القاعدة أن القروض الخارجية عادة ما تكون إختيارية، بينما القروض الداخلية تكون إختيارية أو إجبارية.

2- من حيث حرية الإكتتاب في القرض:

طبقا لهذا المعيار، تنقسم القروض العامة إلى قروض إختيارية و أخرى إجبارية:

أ- القروض الإختيارية **Emprunts volontaires**: هي القروض التي يكون فيها الأشخاص أحرارا في الإكتتاب فيها دون إكراه من السلطة العامة (الدولة)، و هي حينئذ تقوم على أساس تعاقدية.

ب- القروض الإجبارية: هي القروض التي يجبر فيها الأشخاص على الإكتتاب فيها.

3- من حيث أجال القروض:

تنقسم القروض العامة من هذه الناحية إلى قروض مؤقتة و قروض مؤبدة.

أ- القروض المؤقتة (القابلة للإستهلاك **Amortissables**):

هي القروض التي تلتزم الجهة الإدارية المقرضة بالوفاء بها في الآجال و الأوضاع الواردة في قانون إصدارها، و يأخذ هذا النوع من القروض صورة قروض قصيرة، أو متوسطة، أو طويلة الأجل، تبعا للمعطيات و الظروف التي دفعت الدولة إلى الإقتراض.

ب- القروض المؤبدة **perpétuels**:

يقصد بالقروض المؤبدة، تلك التي لا تلتزم الدولة بالوفاء بها في أجل معين مع إلزامها بدفع فوائدّها إلى غاية الوفاء بهذا القرض، مع حرية الدولة في تحديد الوقت الأكثر ملائمة لظروفها الإقتصادية والمالية والوفاء بها.

وصفة التأييد أو الدوام هنا مقررة لصالح الدولة دون المقرضين، حيث يجوز لها الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يكون الدائنين في ذلك حق الإعتراض.

ثالثا- التكليف القانوني للقرض العام:

ما هو الأساس القانوني للقروض العامة؟ هل القانون أم العقد؟

- ذهب الفقه إلى رأيين:

الرأي الأول - القرض العام عقد:

يرى جانب من الفقه، إلى العلاقة القانونية بين الدولة (المقتضة) و الطرف الثاني (المقرض) تكيف على أنها عقد، وهو رأي منتقد خاصة بالنسبة للقروض الإجبارية التي تقتقر إلى عنصر الحرية و الرضا.

الرأي الثاني - القرض العام عمل من أعمال السيادة:

تنص معظم الدساتير على ضرورة إصدار القرض العام بموجب قانون من البرلمان، كما جاء في المادة (14/140) من القانون رقم 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، كما يثار من زاوية أخرى، مدى شرعيتها، وشروط وضوابط عملها و اللجوء إليها.

رابعاً: إصدار القرض العام: l'émission de l'emprunt

طبقاً للمادة (14/140) من القانون رقم 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، فإن إصدار القروض العامة يتطلب صدور قانون من البرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، ذلك أنها كالضرائب.

- يثير موضوع إصدار القرض العام التطرق إلى المسائل الأساسية التالية:

1- مبلغ القرض العام:

يصدر القرض العام إما محدد القيمة أو غير محدد القيمة.

أ- القرض محدد القيمة:

وذلك في حالة ما إذا حددت الدولة - مسبقاً - حداً أعلى للمبلغ الذي تريد أن تقتضيه، و يتوقف الإكتتاب عند بلوغ هذا المبلغ.

ب- القرض غير محدد القيمة:

و ذلك في حالة ما إذا لم تحدد الدولة أو الجهة الإدارية المقتضة مبلغاً لذلك وعادة ما تلجأ الدولة في هذه الحالة إلى تحديد مدة الإكتتاب ليتحدد مبلغ القرض لدى إنتهائها.

2- سندات القرض:

يأخذ القرض، عند إصداره شكل سندات تتمثل عادة في:

أ- **السندات الإسمية Titres nominatifs**: هي تلك السندات التي يقيد إسم مالكيها في سجل خاص للدين يحفظ في إدارة القروض العامة بوزارة المالية، و تسلم له شهادة بإسمه تثبت حقه إتجاه الدولة.

ب- **السندات لحاملها Titres au porteur**: هي تلك التي لا يقيد إسم مالكيها في السجل الخاص، بل القاعدة أن حائز السند هو مالكة ولا يتطلب نقل ملكيته القيام بإجراء قانوني.

و تختلف من حيث إمكانية نقل ملكيتها، ويتم الإكتتاب في سندات القروض العامة بإحدى الطرق التالية:

* الإكتتاب العام المطروح على الجمهور مباشرة.

* البيع للبنوك و المصارف نظير عمولة معينة.

* البيع في سوق الأوراق المالية (La bourse).

خامسا: آثار القرض العام:

يترتب على القروض العامة عدة آثار و نتائج:

1- بالنسبة للمقرض (مزايا القرض):

يترتب على القرض العام رد مبلغه كاملا إلى الجهة المقرضة وطنية كانت أم أجنبية، إضافة إلى حصول هذه الأخيرة على مجموعة من المزايا و الإمتيازات، و التي تعود إلى ما يلي:

- الحصول على فائدة القرض.

- إصدار السندات دون سعر التعادل.

- الإعفاء من الضرائب و غيرها من التحفيزات التي تلجأ إليها الدولة تبعا لظروفها، على الرغم مما يثار عن مدى شرعيتها.

2- بالنسبة للجهة المقرضة (الدولة):

عادة ما يميز بهذا الصدد بين آثار القروض الداخلية و آثار القروض الخارجية.

أ- بالنسبة للقروض الداخلية:

يختلف الأمر، حسب مجال استعمال تلك القروض، فإذا ما صرفت على إنفاق إستهلاكي فإنها تؤدي إلى تبديد للموارد الوطنية و إنتقاص من معدل الناتج القومي، أما إذا ما وجهت لإستثمارات إنتاجية (بناء مصنع)، فإنها تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للإقتصاد الوطني.

ب- بالنسبة للقروض الخارجية:

إذا كان للقروض الخارجية آثار إيجابية من حيث زيادة حصيللة الدولة من العملة الأجنبية لمواجهة متطلبات الإستثمار، فإنها لا تخلو من عيوب من حيث خضوع الدولة لإشترطات و ضغوط تمس من سيادة الدولة و ترهن مستقبلها.

3- التبديل:

يقصد بتبديل القرض العام، إستبدال قرض عام جديد ذي فائدة منخفضة بقرض عام قديم ذي فائدة مرتفعة، و مثال ذلك أن تستبدل الدولة دين سعر فائدته 4 % بدين آخر سعر فائدته 3 % .

سادسا: إنقضاء القرض العام:

ينقضي الإلتزام الواقع على عاتق الدولة جراء القرض العام بحالات و وسائل مختلفة، يمكن ردها إلى ما يلي:

1- الوفاء:

حيث يتم إنقضاء القرض العام بالوفاء به تماما إتجاه الجهة المقرضة، لدى حلول أجله بالنسبة للقروض العامة المؤقتة، أما القروض العامة المؤبدة فإن الوفاء بها يعود لإرادة الدولة، وغالبا ما يتم ذلك على أقساط و دفعات.

2- الإستهلاك:

يقصد بإستهلاك القرض العام سداد قيمته تدريجيا على عدة دفعات إلى حاملي سندات خلال فترة معينة وفقا لما تقضي به شروط الإصدار.